乙第１号証

国際連合 CRC/C/JPN/CO/4-5

（仮訳）

配布：一般
2019年3月5日
原文：英語

児童の権利委員会

日本の第4回・第5回政府報告に関する総括所見*

I. 序論

1. 委員会は，日本の第4回・第5回政府報告（CRC/C/JPN/4-5）を2019年1月16日及び17日に開かれた第2346回及び第2347回会合（CRC/C/SR.2346, 2347参照）において審査し，2019年2月1日に開かれた第2370回会合において本総括所見を採択した。

2. 委員会は，締約国における児童の権利の状況に関するより良い理解のために提出された，第4回・第5回政府報告，及び事前質問事項に対する書面による回答（CRC/C/JPN/Q/4-5/Add.1）を歓迎する。委員会は，多部門から構成された締約国の代表団との間で行われた建設的対話に，感謝の意を表する。

II. 締約国によるフォローアップ措置と進展

3. 委員会は，男女ともに婚姻開始年齢を18歳にすることとした2018年の民法改正，2017年の刑法改正，2016年の児童福祉法改正，児童ポルノの所持を犯罪化するに至った2014年の児童買春，児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律の改正等，締約国による様々な分野での進展を歓迎する。また，委員会は，2016年の子供・若者育成支援推進大綱，2018年の第4次青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画及び2014年の子供の貧困対策に関する大綱等，前回の審査以降に児童の権利に関連してとられた制度面及び政策面の措置の採択についても歓迎する。

III. 主要分野における懸念及び勧告

4. 委員会は，締約国が本条約にうたわれた全ての権利の不可分性及び相互依存性について締約国に対して注意を喚起し，本総括所見に含まれる全ての勧告の重要性を強調する。委員会は，緊急の措置がとられなければならない以下の分野に関する勧告に対し，締約国の注意を喚起したい。その分野とは，差別の禁止（パラ18），児童の意見の尊重（パラ22），体罰（パラ26），家庭環境を奪われた児童（パラ29），生殖に関する健康及び精神的健康（パラ35）並びに少年司法（パラ45）である。

* 第80回会期（2019年1月14～2月1日）において同委員会により採択された。

Please recycle

5. 委員会は，締約国が，持続可能な開発のための2030アジェンダの実施プロセス全体を通じ，本条約，武力紛争における児童の関与に関する児童の権利に関する条約の選択議定書及び児童の売買，児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書に従って児童の権利の実現を確保するよう勧告する。委員会はまた，締約国に対し，児童に関する限りにおいて，全17の持続可能な開発目標の達成を目的とする政策及びプログラムの策定並びに実施において児童の有意義な参加を確保することを要請する。

A. 一般的実施措置（第4条，第42条及び第44条(6)）

留保

6. 委員会は，前回の勧告（CRC/C/JPN/CO/3，パラ10）に則して，締約国が，本条約の完全な適用の障害となっている第37条(c)に付している留保を撤回することを検討するよう勧告する。

立法措置

7. 締約国から提供された様々な法改正に関する情報に留意しつつ，委員会は，締約国が，児童の権利に関する包括的な法律を採択し，また既存の法令を本条約の原則及び規定と完全に調和させるための措置をとるよう，強く勧告する。

包括的な政策と戦略

8. 委員会は，締約国が，本条約が対象とする全ての分野を包含し，政府機関間の調整及び相互補完性を確保する包括的な児童の保護に関する政策を策定するとともに，十分な人的資源，技術的資源及び財源に裏づけられた当該政策のための包括的な実施戦略を策定するよう勧告する。

調整

9. 委員会は，締約国が，分野横断的に，国，地域及び地方レベルで行われている本条約の実施に関連する全ての活動を調整するための明確な任務及び十分な権限を有する適切な調整機関，また，全ての児童及び本条約の全ての分野を対象とする評価及び監視のためのメカニズムを設置するよう要請する旨の前回の勧告（CRC/C/JPN/CO/3，パラ14）を改めて表明する。締約国は，当該調整機関に対し，その効果的な運営のために必要な人的資源，技術的資源及び財源が提供されることを確保すべきである。

資源の配分

10. 児童の相対的貧困率がこの数年高いままであることに鑑み，また，児童の権利実現のための公共予算編成に関する一般的意見第19号（2016年）を想起しつつ，委員会は，締約国が，児童の権利の視点を含み，児童に対する明確な配分額を定め，かつ本条約の実施のための資源分配の妥当性，有効性及び衡平性の監視及び評価を行うための具体的指標及び追跡システムを包含した予算策定手続を確立するよう，強く勧告する。その手段としては以下が含まれる。

(a) 児童に直接影響を与える全ての支出の計画，確定，補正及び実際の額について，詳細な予算科目及び予算項目を定めること。

(b) 児童の権利に関連する支出の報告，追跡及び分析を可能にする予算分類システムを活用すること。

(c) サービス提供のための予算配分額の変動または削減によって，児童の権利の享受に関する現在の水準が低下しないことを確保すること。

(d) 子供・若者育成支援推進大綱の実施のために十分な資源を配分すること。

データ収集

11. 締約国によるデータ収集の努力に留意しつつ，委員会は，なお不足が存在することにも留意する。本条約の一般的実施措置に関する一般的意見第5号（2003年）を想起しつつ，委員会は，締約国が，本条約の全ての分野，特に児童の貧困，児童に対する暴力，乳幼児期のケア及び発達の分野において，年齢，性別，障害，地理的所在，民族的出自及び社会経済的背景ごとに細分化されたデータ収集システムを改善するとともに，当該データを政策立案及びプログラム策定のために活用するよう勧告する。

独立した監視

12. 地方自治レベルで児童のための33のオンブズパーソン機関が設置されていることに留意する一方で，これらの機関には財政及び人的資源に関する独立性や救済メカニズムが欠けていると報告されている。委員会は，締約国が以下の措置をとるよう勧告する。

(a) 児童による申立てを児童に配慮した方法で受理，調査，及び対応することが可能な，児童の権利を監視するための具体的メカニズムを含む人権監視のための独立したメカニズムを迅速に設置すること。

(b) 人権の促進・保護のための国内機関の地位に関する原則（パリ原則）の完全なる遵守が確保されるよう，資金，任務及び免責との関連も含め，当該監視メカニズムの独立性を確保すること。

広報，意識啓発及び研修

13. 意識啓発プログラム及び児童の権利キャンペーンを実施するために締約国が行っている努力を認識しつつ，委員会は，締約国に対し以下のことを勧告する。

(a) 立法手続及び司法手続における本条約の適用を確保するため，特に児童，両親，国会議員及び裁判官を対象として，本条約に関する情報の広報を拡大すること。

(b) 教員，裁判官，弁護士，家庭裁判所調査官，ソーシャルワーカー，法執行官，メディア従事者，公務員及びあらゆるレベルの政府職員を含め，児童のために，及び児童と共に働く全ての者を対象として，本条約及び選択議定書に関する具体的な研修セッションを定期的に実施すること。

市民社会との協力

14. 締約国の報告書の作成過程における市民社会との会合及び意見交換を歓迎しつつ，委員会は，締約国が，市民社会との協力を強化し，本条約実施のあらゆる段階で市民社会組織の関与を系統的に得るよう勧告する。

児童の権利と企業部門

15. 企業部門が児童の権利に与える影響に関わる国の義務に関する一般的意見第16号（2013年）及び2011年に人権理事会が承認したビジネスと人権に関する基本原則を想起しつつ，委員会は，締約国に対し以下を勧告する。

(a) ビジネスと人権に関する国別行動計画を策定するに当たり，児童の権利が組み込まれること，また，企業に対し，定期的な児童の権利への影響に対するアセスメントや協議を行い，自社の事業活動が及ぼす環境面，健康関連及び人権面での影響並びにこれらに対処するための計画を完全かつ公に開示するよう義務づけることを確保すること。

(b) 児童の権利に関連する労働及び環境を含む国際基準の遵守について，企業部門が説明責任を負うための規則を採択し，実施すること。

(c) 旅行及び観光の文脈における児童の性的搾取の防止について，観光業界，メディア・広告企業，娯楽業界及び一般国民と協力して意識啓発キャンペーンを実施すること。

(d) 旅行代理店及び観光業界の間で世界観光機関の世界観光倫理憲章を広く普及させること。

B. 児童の定義（第1条）

16. 男女ともに婚姻開始年齢を18歳にすることとした民法改正に留意しつつ，委員会は，2022年にならなければ同改正が施行されないことを遺憾に思うと同時に，締約国が，それまでの間，本条約に基づく締約国の義務に則して児童の結婚を完全に廃絶させるために必要な暫定的措置をとるよう勧告する。

C. 一般原則（第2条，第3条，第6条及び第12条）

差別の禁止

17. 委員会は，嫡出でない子に同一の相続分を認めた「民法の一部を改正する法律」の改正（2013年），本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律の採択（2016年），及び対話の際に挙げられた意識啓発活動に留意する。委員会はまた，強姦罪の構成要件を見直し，男子にも保護を与えた刑法の改正（2017年）も歓迎する。しかしながら，委員会は以下を依然として懸念する。

(a) 包括的な反差別法が存在しないこと。

(b) 嫡出でない子の非嫡出性に関する戸籍法の差別的規定（特に出生届に関するもの）が部分的に維持されていること。

(c) 周縁化された様々な集団に属する児童に対する社会的差別が根強く残っていること。

18. 委員会は，締約国に対して以下を要請する。

(a) 包括的差別禁止法を制定すること。

(b) 嫡出でない子の地位に関するものを含め，根拠にかかわらず，児童を差別する全ての規定を廃止すること。

(c) アイヌを含む民族的少数者の児童，被差別部落出身の児童，韓国・朝鮮人（Korean）等の日本国籍以外の児童，移住労働者の児童，LGBTIの児童，婚外子並びに障害児に対する実質的な差別を減らし，防止するために，意識啓発プログラム，キャンペーン及び人権教育を含む措置を強化すること。

児童の最善の利益

19. 委員会は，最善の利益が第一次的に考慮されるべき児童の権利が，特に教育，代替的監護，家族争議及び少年司法において適切に取り入れられず，また，一貫して解釈及び適用されていないこと，並びに，司法，行政及び立法機関が，児童に関連する全ての決定において児童の最善の利益を考慮していないことに留意する。最善の利益が第一次的に考慮されるべき児童の権利に関する一般的意見第14号（2013年）を想起しつつ，委員会は，締約国が，児童に関連する全ての法律及

び政策の影響評価を事前又は事後に実施するための義務的手続を確立するよう勧告する。委員会はまた，児童に関わる個別の事案で，児童の最善の利益に関する評価が，多職種から成るチームによって，児童本人の義務的参加を得て必ず行われるよう勧告する。

生命，生存及び発達に対する権利

20. 委員会は，前回の勧告（パラ42）を想起し，締約国に対し，以下を要請する。

(a) 児童が幼少期及び発達を社会の競争的性質によって害されることなく享受できるよう確保するための措置をとること。

(b) 児童の自殺の根本的原因に関する調査研究を行い，防止措置をとり，学校にソーシャルワーカー及び心理的相談サービスを配置すること。

(c) 児童関連施設が適切な安全最低基準を遵守することを確保するとともに，児童の不慮の死亡または重傷事案が必然的で独立した立場から，公的に検証される制度を導入すること。

(d) 交通事故，学校における事故及び家庭内の事故を防止するために焦点を絞った措置を強化するとともに，交通安全，安全及び応急手当訓練の提供並びに小児緊急処置の拡大を確保するための手段を含む適切な対応を確保すること。

児童の意見の尊重

21. 2016年の児童福祉法の改正が児童の意見の尊重に言及していること，また，家事事件手続法が当該手続における児童の参加に関わる規定を統合していることに留意しつつ，委員会は，自己に関わるあらゆる事柄について自由に意見を表明する児童の権利が尊重されていないことを依然として深刻に懸念する。

22. 聴取される児童の権利に関する一般的意見第12号（2009年）を想起しつつ，委員会は，締約国に対し，児童に対する脅迫及び処罰を防止するための保護措置をとりつつ，意見を形成することのできるいかなる児童に対しても，年齢制限を設けることなく，その児童に影響を与える全ての事柄について自由に意見を表明する権利を保障し，また，児童の意見が正当に重視されることを確保するよう要請する。委員会はさらに，締約国が，聴取される権利を児童が行使できるようにする環境を提供するとともに，家庭，学校，代替的監護及び保健医療の現場，児童に関わる司法及び行政手続，並びに地域コミュニティにおいて，環境問題を含むあらゆる関連の問題に関して，全ての児童が影響力を持つ形で参加することを積極的に促進するよう要請する。

D. 市民的権利及び自由（第7条，第8条及び第13～17条）

出生登録及び国籍

23. 持続可能な開発目標（SDGs）ターゲット16.9を想起しつつ，委員会は，締約国に対し以下を勧告する。

(a) 両親の国籍を取得できない児童に対しても出生時に自動的に国籍を付与するため，国籍法第2条(3)の適用範囲を拡大することを検討するとともに，締約国に暮らしている全ての児童（非正規移住者の児童を含む）が適切に登録され，法律上の無国籍状態から保護されることを確保するよう国籍及び市民権に関わるその他の法律を見直すこと。

(b) 庇護を希望している児童をはじめ登録されていない全ての児童が，教育，保健その他の社会サービスを受けることを確保するために必要な積極的

措置をとること。

(c) 無国籍の児童を適切に特定し，保護するための無国籍認定手続を定めること。

(d) 無国籍者の地位に関する条約及び無国籍の削減に関する条約の批准を検討すること。

E. 児童に対する暴力（第19条，第24条3項，第28条2項，第34条，第37条(a)及び第39条）

虐待，放置，性的搾取

24. 委員会は，各県における性的虐待の被害者のためのワンストップセンター設置並びに18歳未満の者を監護する者による性交等及びわいせつ行為に関わる犯罪を新設した刑法第179条の改正を歓迎する。しかしながら，児童のあらゆる形態の暴力からの自由に対する権利に関する一般的意見第13号（2011年）を想起しつつ，またSDGs16.2に留意して，委員会は，児童に対する暴力，性的虐待及び搾取が高い水準で発生していることを懸念し，締約国が児童に対するあらゆる形態の暴力の撲滅を優先し，以下を勧告する。

(a) 被害児童特有のニーズに関して訓練された職員により支えられた，虐待（学校におけるものも含む）及び性的搾取の被害児童のための，児童にとって利用しやすい通報，申立て及び照会メカニズムの設置を速やかに進めること。

(b) そのような事件を捜査し，加害者を裁判にかける取組を強化すること。

(c) 性的搾取及び虐待の被害児童を非難する動きに対抗する意識啓発活動を実施すること。

(d) 児童虐待を防止し，及びこれに対処するための包括的戦略並びに被害児童の回復及び社会的統合に向けた政策の策定のため，児童の関与の下での教育プログラムを強化すること。

体罰

25. 委員会は，学校における体罰が法律によって禁止されていることに留意する。しかしながら，以下につき深刻に懸念する。

(a) 学校における体罰の禁止は，効果的に実施されていない。

(b) 家庭及び代替的監護環境における体罰は，法律によって完全に禁止されていない。

(c) 民法及び児童虐待防止法は，特に，適切なしつけの行使を許容し，体罰の許容性を明確にしていない。

26. 体罰及びその他の残虐な又は品位を傷つける形態の罰からの保護に対する児童の権利に関する一般的意見第8号（2006年）に留意し，委員会は，前回の勧告（CRC/C/JPN/CO/3，パラ48）を想起し，締約国に以下を要請する。

(a) 家庭，代替的監護及び保育環境，並びに刑事施設を含め，あらゆる環境において，法律，特に児童虐待防止法及び民法によって，どんなに軽いものであっても，全ての体罰を明示的かつ完全に禁止すること。

(b) 意識啓発キャンペーンの強化，並びに肯定的，非暴力的かつ参加型の形態の子育て及びしつけの推進によるものを含め，あらゆる環境において実質的な体罰を無くすための措置を強化すること。

F. 家庭環境及び代替的監護（第5条，第9～11条，第18条(1)及び(2)，第20条，第21条，第25条及び第27条(4)）

家庭環境

27. 委員会は，締約国が，以下を行うため，十分な人的資源，技術的資源及び財源に裏づけられたあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。

(a) 仕事と家庭生活との適切なバランスを促進すること等の手段によって家族の支援や強化を図り，また，とりわけ児童の遺棄や施設措置を防止するため，困窮している家族に対して十分な社会的援助，心理社会的支援や指導を提供すること。

(b) 児童の最善の利益である場合に，外国籍の親も含めて児童の共同養育を認めるため，離婚後の親子関係について定めた法令を改正し，また，非同居親との人的な関係及び直接の接触を維持するための児童の権利が定期的に行使できることを確保すること。

(c) 家庭争議（例えば児童の扶養料に関するもの）における裁判所の命令の法執行を強化すること。

(d) 子及びその他の親族の扶養料の国際的な回収に関する条約，扶養義務の準拠法に関する議定書，及び親等の責任及び子の保護措置に関する管轄権，準拠法，承認，執行及び協力に関する条約の批准を検討すること。

家庭環境を奪われた児童

28. 委員会は，家庭を基盤とする養育の原則を導入した2016年の児童福祉法改正，また，6歳未満の児童は施設に措置されるべきではないとする「新しい社会的養育ビジョン」（2017年）の承認に留意する。しかしながら，委員会は以下を深刻に懸念する。

(a) 家族から分離される児童が多数にのぼるとの報告がなされていること，また，児童が裁判所の命令なくして家族から分離される場合があり，かつ最長で２か月間児童相談所に措置され得ること。

(b) いまなお多数の児童が，基準に満たない施設に措置され，多数の児童虐待の事件が報告されており，そうした施設では外部者による監視や評価のメカニズムが設けられていないこと。

(c) 児童相談所がより多くの児童を受け入れることに対する強力な金銭的インセンティブを有する疑惑があること。

(d) 里親が包括的支援，十分な研修及び監視を受けていないこと。

(e) 施設に措置された児童が生物学的親との接触を維持する権利を剥奪されていること。

(f) 生物学的親が児童の分離に反対する場合，又は児童の措置に関する生物学的親の決定が児童の最善の利益に反する場合は，児童相談所が家庭裁判所に申し立てを行うとの明確な指示が与えられていないこと。

29. 児童の代替的監護に関する指針に対する締約国の注意を喚起しつつ，委員会は，締約国に対し以下を要請する。

(a) 児童を家族から分離するべきか否かの決定に関して義務的司法審査を導入すること，児童の分離に関する明確な基準を定めること及び親からの子の分離が最後の手段としてのみ，それが児童の保護のために必要かつ子どもの最善の利益に合致する場合に，子及びその親の意見を聴取した後に行なわれるよう確保すること。

(b) 明確なスケジュールに沿った「新しい社会的養育ビジョン」の迅速で効果的な執行，６歳未満の児童を手始めとする児童の速やかな脱施設化及び里親機関の設置を確保すること。

(c) 児童相談所において児童を一時保護する慣行を廃止すること。

(d) 代替的養護の現場における児童虐待を防止すること，こうした虐待に関する捜査及び責任者の訴追を行うこと，里親養育及び児童相談所等の児童を施設的環境に置くことが定期的に独立した外部監査を受けるよう確保すること，並びに，児童の不当な扱いの通報，監視及び是正のためにアクセス可能で安全な手段を用意する等の方法により，こうした環境における監護の質を監視すること。

(e) 財源を施設から里親家族等の家族的環境に振り直すとともに，全ての里親が包括的な支援，十分な研修及び監視を受けることを確保しながら，脱施設化を実行に移す自治体の能力を強化し，同時に家庭を基盤とする養育体制を強化すること。

(f) 児童の措置に関する生物学的親の決定が児童の最善の利益に反する場合には家庭裁判所に申し立てを行うよう，児童相談所に明確に指示するため，里親委託ガイドラインを改正すること。

養子縁組

30. 委員会は，締約国に対し以下を勧告する。

(a) 全ての養子縁組（直系親族によるもの又は後見人によるものを含む）が裁判所による許可の対象とされ，児童の最善の利益に従って行なわれることを確保すること。

(b) 養子とされた全ての児童の登録情報を維持し，国際養子縁組に関する中央当局を設置すること。

(c) 国家間にまたがる養子縁組に関する子の保護及び協力に関するハーグ条約の批准を検討すること。

不法な連れ去り・留置

31. 委員会は，締約国が，子の不法な連れ去り及び留置を防止し，及びこれに対処し，国内法を国際的な子の奪取の民事上の側面に関するハーグ条約と調和させ，子の返還及び面会交流権に関する司法決定の適正かつ迅速な実施を確保するために，あらゆる必要な努力を行うよう勧告する。委員会はまた，締約国が，関連諸国，特に締約国が監護又は面会権に関する協定を署名している国々との対話及び協議を強化するよう勧告する。

G. 障害，基礎的保健及び福祉（第6条，第18条3，第23条，第24条，第26条，第27条1～3及び第33条）

障害を有する児童

32. 委員会は，合理的配慮の概念を導入した2011年の障害者基本法改正及び2013年の障害者差別解消法の採択を歓迎する。障害を有する児童の権利に関する一般的意見第9号（2006年）に留意し，委員会は，前回の勧告（CRC/C/JPN/CO/3，パラ59）を想起し，締約国が，障害について人権を基盤とするアプローチをとり，障害を有する児童を包含するための包括的戦略を確立し，以下を勧告する。

(a) 障害を有する児童に関するデータを恒常的に収集し，効率的な障害診断システムを発展させること。これは，障害を有する児童のための適切な政策及びプログラムを整備するために必要である。

(b) 統合された学級における包摂的教育を発展させ実施するために適切な人的・技術的資源及び財源に支えられた施策を強化すること，また，専門教員及び専門家を養成し，学習障害のある児童に個別支援やあらゆる適正な配慮を提供する統合された学級に配置すること。

(c) 学童保育サービスの施設及び人員に関する基準を厳格に適用し，その実施を監視するとともに，これらのサービスが包摂的であることを確保すること。

(d) 障害を有する児童が早期発見介入プログラムを含む保健サービスにアクセスできることを確保するための即時措置をとること。

(e) 教員，ソーシャルワーカー，保健，医療，治療やケアに従事する人材等，障害を有する児童とともに働く専門スタッフを養成し，増員すること。

(f) 障害を有する児童に対する汚名及び偏見に対処し，こうした児童の肯定的なイメージを促進するために，政府職員，公衆及び家族を対象とする意識啓発キャンペーンを実施すること。

健康及び保健サービス

33. 到達可能な最高水準の健康を享受する児童の権利に関する一般的意見第15号（2013年）及びSDGsターゲット2.2を想起しつつ，委員会は，締約国に対し，以下を勧告する。

(a) 高い低体重出生率の根本的原因を分析するとともに，「健やか親子21（第2次）」キャンペーン等を通じ，新生児の出生体重，並びに，新生児，児童及び母親の栄養状態を効果的に向上させるための根拠に基づいた措置を導入すること。

(b) 柔軟な勤務形態及びより長い期間の産後休暇を奨励する等の手段によって，少なくとも産後6か月間の完全母乳育児を促進し，母性保護に関するILO第183号条約の批准を検討し，かつ「母乳代替品の販売促進に関する国際基準」を全面的に実施するとともに，病院，診療所及びコミュニティにおける相談体制を通じて母親に適切な支援を提供し，全国で「赤ちゃんにやさしい病院」イニシアティブを実施するための包括的キャンペーンを実施するため，あらゆる必要な措置をとること。

生殖に関する健康及び精神的健康

34. 委員会は以下を深刻に懸念する。

(a) 思春期の子どもの間でHIV/AIDS，及びその他の性感染症の感染率が高まっており，学校において，性と生殖に関する健康や家族計画に関するサービス及び教育が限られていること。

(b) 10代女子の妊娠中絶率が高く，刑法で堕胎が違法とされていること。

(c) 思春期の児童の精神的健康に対する関心が不十分であること，精神的健康の問題に対する社会の態度が否定的であること，また，児童心理学者やその他の専門的人材が不足していること。

(d) 児童が注意欠如・多動性障害（ADHD）を伴う行動上の問題を有している旨の診断や，精神刺激薬を原因とする児童の治療が増加している一方で，社会的決定要因及び非医学的形態の治療は軽視されていること。

35. 児童の権利条約の文脈における思春期の健康と発達に関する一般的意見第4号（2003年）及び思春期における児童の権利の実施に関する一般的意見第20号（2016年）を想起しつつ，SDGsターゲット5.6に留意し，委員会は，締約国に対し，以下のことを要請する。

(a) 思春期の児童の性と生殖に関する健康について包括的政策をとるとともに，早期妊娠及び性感染症の防止に特に焦点を当て，思春期の女子及び男子を対象とした性と生殖に関する教育が学校の必修カリキュラムの一部として一貫して実施されることを確保すること。

(b) 質の高い年齢に応じたHIV/AIDS関連のサービス及び学校における教育へのアクセスを向上させ，妊娠しているHIV陽性の女子を対象とする抗レトロウィルス治療および予防治療へのアクセス及びその受療率を向上させ，エイズ治療・研究開発センター及び14か所に設置された地域の拠点病院に十分な支援を提供すること。

(c) あらゆる状況における中絶の非犯罪化を検討するとともに，思春期の女子を対象とする，安全な中絶及び中絶後のケアのサービスへのアクセスを高めること。

(d) 根本的原因の分析，意識啓発及び専門家の増員を含む学際的アプローチを通じ，児童や思春期の青少年の情緒的及び心理的健康への対処を進めること。

(e) ADHDを有する児童の診断が徹底的に吟味され，医薬品の処方が最後の手段として，個別化されたアセスメントを経た後に初めて行われること，また児童やその親に対してそのような処置の副作用の可能性及び医療ではない代替的手段について適切に情報提供が行われることを確保するとともに，ADHDの診断及び精神刺激薬の処方が増加している根本的原因についての研究を実施すること。

環境保健

36. 委員会は，子ども被災者支援法，福島県民健康管理基金，及び被災した子どもの健康・生活対策等総合支援事業の存在に留意する。しかしながら，SDGsターゲット3.9を想起しつつ，委員会は，締約国に対し，以下を勧告する。

(a) 避難指示区域における放射線被ばく量が，児童にとってのリスク要因に関する国際的に受け入れられた知見に一致していることを再確認すること。

(b) 帰還が許されていない区域からの避難者，特に児童に対して，財政面，住居面，医療面及びその他の支援を継続すること。

(c) 福島県において放射線の影響を受けた児童に対する医療及びその他のサービスの提供を強化すること。

(d) 年間1mSvを超える被ばく線量の区域の児童のための包括的かつ長期の健康診断を実施すること。

(e) 全ての避難者及び住民，特に児童のような脆弱な立場に置かれた集団に対する精神的健康のための施設，物資及びサービスの利用を確保すること。

(f) 教科書及び教材において，放射線被ばくのリスクや，児童が放射線に対する感受性が高いことについて，正確な情報を提供すること。

(g) 到達可能な最高水準の身体的及び精神的健康を享受する全ての人々の権利に関する特別報告者による勧告（A/HRC/23/41/Add.3参照）を実施すること。

10

気候変動が児童の権利に与える影響

37. 委員会は，SDGs目標13及び同ターゲットに対する注意を喚起する。特に，委員会は，締約国に対し，以下を勧告する。

(a) 気候変動及び災害リスク管理の問題を扱う政策またはプログラムの策定に当たり，児童の特別な脆弱性やニーズ，並びに児童の意見が考慮されることを確保すること。

(b) 学校のカリキュラムや教員の研修プログラムに気候変動や自然災害の内容を組み込むことを通じて，気候変動や自然災害に関する児童の意識と準備を向上させること。

(c) 国際的，地域的及び国内的な政策，枠組及び協定を然るべく策定するため，様々な災害の発生に対して児童が直面するリスクの諸態様を特定する細分化されたデータを収集すること。

(d) 児童の権利，特に健康，食料及び十分な生活水準に対する権利の享受を脅かすレベルの気候変動を回避するための国際的誓約に則して温室効果ガスの排出量を削減すること等により，気候変動緩和政策が本条約と両立することを確保すること。

(e) 他国の石炭火力発電所に対する締約国の資金拠出を再検討するとともに，これらの発電所が持続可能なエネルギーを用いた発電所に徐々に置き換わることを確保すること。

(f) 上記勧告の実施に当たり，二国間協力，多国間協力，地域協力及び国際協力を求めること。

生活水準

38. 社会的移転やひとり親家庭の児童への手当といった様々な措置に留意しつつ，委員会は，SDGsターゲット1.3に対する注意を喚起し，締約国に対し，以下を勧告する。

(a) 家族給付及び児童への手当の制度を強化する等の手段により，親に対して適切な社会的援助を与えるための努力を強化すること。

(b) 児童の貧困及び社会的排除を低減させるための戦略や措置を強化するため，家族及び児童と的を絞った協議を実施すること。

(c) 子供の貧困対策に関する大綱を実施するために必要なあらゆる措置をとること。

H. 教育，余暇及び文化的活動（第28条～31条）

職業訓練及び指導を含む教育

39. SDGsターゲット4.a，特にいじめを経験している生徒の割合に関する指標4.a.2に留意しつつ，委員会は，前回の勧告（CRC/C/JPN/CO/3，パラ71，73，及び75～76）を想起し，締約国に対し，以下を勧告する。

(a) いじめ防止対策推進法及びいじめ対策プログラムの下での効果的ないじめ対策措置並びに学校におけるいじめ防止キャンペーンを実施すること。

(b) 過度に競争的な制度を含むストレスの多い学校環境において児童のストレス緩和を目的とした措置を強化すること。

(c) 高等学校等就学支援金制度を朝鮮学校にも適用しやすくするために基準を見直すこと及び大学入学試験へのアクセスが差別的でないことを確保すること。

乳幼児期の発達

40. 委員会は，保育所等における保育の質の確保・向上に関する検討会の設置（2018年）及び子育て安心プラン（2017年）を歓迎する。SDGsターゲット4.2に留意しつつ，委員会は，前回の勧告（パラ71，73，及び75～76）を想起し，締約国に対し，以下を勧告する。

(a) 3～5歳の幼児を対象とする幼稚園，保育所及び認定こども園等の無償化を効果的に実施すること。

(b) 質の向上を図りながら，2020年末までに不足を減らし，新たな受入れの余地を設けて，大都市部における保育施設の受入れ可能人数を拡大するための努力を継続すること。

(c) 保育を，手に届き，アクセスしやすく，保育施設の設備及び運営に関する最低基準に合致したものにすること。

(d) 保育の質を確保し向上させるための具体的措置をとること。

(e) 上記(a)~(d)の措置のために十分な予算を配分すること。

休息，余暇，レクリエーション並びに文化的及び芸術的活動

41. 休息，余暇，遊び，レクリエーション活動，文化的生活及び芸術に対する児童の権利に関する一般的意見第17号（2013年）を参照しつつ，委員会は，締約国が，十分かつ持続可能な資源をともなった遊び・余暇政策の採用及び実施を図り，余暇及び自由な遊びのために十分な時間を配分する等の手段により，休息及び余暇についての児童の権利並びに児童の年齢に適した遊び及びレクリエーションの活動に従事する児童の権利を保障するための努力を強化するよう勧告する。

I. 特別な保護措置（第22条，第30条，第32条，第33条，第35条，第36条，第37条(b)～(d)，第38～40条）

児童の庇護希望者，移民・難民の児童

42. 国際移住の文脈において児童の人権に関する合同一般的意見である，全ての移住労働者及びその家族構成員の権利の保護に関する一般的意見第3号及び第4号（2017年），また，児童の権利委員会の一般的意見第22号及び第23号（2017年）を想起しつつ，委員会は，前回の総括所見（CRC/C/JPN/CO/3，パラ78）を想起し，締約国に対し，以下を勧告する。

(a) 児童に関する全ての決定において児童の最善の利益が第一次的に考慮され，ノン・ルフールマン原則が維持されることを確保すること。

(b) 庇護希望者である親が収容されて子から分離されることを防止するための法的枠組を確立すること。

(c) 庇護希望者又は移住者であって保護者のいない児童又は養育者から分離された児童の収容を防止し，こうした全ての児童が入管収容施設から直ちに放免されることを確保し，かつこれらの児童に居住場所，適切な監護及び教育へのアクセスを提供するため，公式なメカニズムの設置等も通じた即時的措置をとること。

(d) 庇護希望者及び難民（特に児童）に対するヘイトスピーチに対抗するためのキャンペーンを進展させること。

12

売買，取引及び誘拐

43. 委員会は，締約国に対し，以下を勧告する。

(a) 児童の人身取引の加害者を裁判にかけるための努力を強化し，児童の人身取引の犯罪に対する刑罰を重くし，そのような犯罪に対して選択刑として罰金を認めないこと。

(b) 人身取引の被害を受けた児童が適切に特定され，サービスに付託されることを確保するため，被害者のスクリーニングを強化すること。

(c) シェルター，並びに身体的・心理的な回復及びリハビリテーションのための児童に優しい包括的な支援を含め，人身取引の被害を受けた児童に特化したケア及び支援のためのリソースを増加させること。

少年司法の運用

44. 委員会は，再犯防止推進計画（2017年）に留意する。しかしながら，委員会は以下を深刻に懸念する。

(a) 「刑事処罰可能年齢」が16歳から14歳に引き下げられたこと。

(b) 弁護人選任権が制度的に実施されていないこと。

(c) 重大な犯罪を行った16歳を超える年齢の児童が成人刑事裁判所に送致され得ること。

(d) 14～16歳の児童が矯正センターに拘禁され得ること。

(e) 「罪を犯すおそれがある」とされた児童の自由が剥奪される場合があること。

(f) 児童が無期刑を科されており，仮釈放までに必要な最低期間よりも相当程度長く拘禁されるのが一般的であること。

45. 委員会は，締約国に対し，少年司法制度を本条約その他関連基準に完全に則したものとするよう要請する。特に，委員会は，前回の総括所見（CRC/C/JPN/CO/3，パラ85）を想起し，締約国に対し，以下を要請する。

(a) 児童犯罪の根本的原因を研究し，防止措置を至急実施すること。

(b) 「刑事処罰可能年齢」を16歳に戻すことの再検討の参考とするため，2000年以降の児童犯罪の傾向を研究すること。

(c) 法律に抵触した児童に対し，早期段階から，かつ法的手続全体を通じて，有資格で独立した存在からの法的支援が提供されることを確保すること。

(d) いかなる児童も成人刑事裁判所による審理の対象とされないことを確保すること，また，ダイバージョン，保護観察，調停，カウンセリング又は社会奉仕活動等，罪に問われた児童の事件における非司法的措置の利用を増やし，可能な場合において拘禁を伴わない刑を用いること。

(e) 審判前及び審判後の自由の剥奪が，最後の手段として，かつ可能な限り最短期間で用いられ，その取消しを目的として定期的に再審査されることを確保するとともに，特に以下を行うこと。

i. 児童が「罪を犯すおそれがある」旨の認定について再検討し，こうした児童の拘禁を終了させること。

ii. 児童が犯した犯罪について無期刑及び不定期刑を用いることを再検討し，拘禁が適切な最短期間で用いられることを確保するために特別な仮釈放制度を適用すること。

児童の売買，児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書の実施についての委員会の前回の総括所見及び勧告のフォローアップ

46. 児童の売買等に関する児童の権利に関する条約の選択議定書の下での締約国の政府報告に関する2010年の勧告（CRC/C/OPSC/JPN/CO/1参照）を実施するための締約国の取組を評価とともに留意しつつ，委員会は，締約国に対し，以下を勧告する。

(a) あからさまな性的活動に従事する児童若しくは主に児童として描かれた人物の画像若しくは描写，又は性的目的のための児童の性的部位の何らかの描写の，製造，流通，頒布，提供，販売，アクセス，閲覧及び所持を犯罪化すること。

(b) 女子高生サービス（JKビジネス）や児童エロチカ等，児童買春及び児童の性的搾取を促し，またはそれにつながる商業活動を禁止すること。

(c) 加害者の説明責任及び被害を受けた児童の救済を確保するため，オンライン及びオフラインにおける児童の売買，児童買春及び児童ポルノに関連する犯罪を捜査，訴追し，処罰するための取組を強化すること。

(d) 性的虐待及び搾取の被害を受けた児童に焦点を当てた質の高い統合的なケア及び支援を提供するため，ワンストップ・クライシスセンターへの資金拠出及び支援を引き続き強化すること。

(e) 生徒，親，教員及びケアに従事する者を対象とした，新たな技術に関連するリスク及びインターネットの安全な利用に関するキャンペーンを含む意識啓発プログラムを強化すること。

(f) 児童の売買，児童買春及び児童ポルノに関する特別報告者による勧告（A/HRC/31/58/Add.1，パラ74）を実施すること。

武力紛争における児童の関与に関する児童の権利に関する条約の選択議定書の実施についての委員会の前回の総括所見及び勧告のフォローアップ

47. 委員会は，武力紛争における児童の関与に関する児童の権利に関する選択議定書に基づく締約国の政府報告に関する2010年の勧告（CRC/C/OPAC/JPN/CO/1参照）を実施するための締約国の取組を評価とともに留意しつつ，締約国が，特に自衛隊が国連平和維持活動に参加する際に，選択議定書の規定に関する自衛隊への研修を引き続き強化するための具体的措置をとるよう勧告する。

J. 通報手続に関する選択議定書の批准

48. 委員会は，締約国が，児童の権利の実現をさらに強化するため，通報手続に関する選択議定書を批准するよう勧告する。

K. 人権についての国際文書の批准

49. 委員会は，締約国が，児童の権利の実現をさらに強化するため，締約国が未だ締結していない以下の人権についての中核的な文書の批准を検討するよう勧告する。

(a) 市民的及び政治的権利に関する国際規約の第一選択議定書

(b) 死刑の廃止を目的とする市民的及び政治的権利に関する国際規約の第二選択議定書

(c) 経済的，社会的及び文化的権利に関する国際規約の選択議定書

(d) 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の選択議定書

14

(e) 拷問及び他の残虐な，非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約の選択議定書

(f) 全ての移住労働者及びその家族の構成員の権利の保護に関する国際条約

(g) 障害者の権利に関する条約の選択議定書

L. 地域機関との協力

50. 委員会は，締約国が，特に女性と児童の権利の促進及び保護に関するASEAN委員会と協力するよう勧告する。

V. 実施及び報告

A. フォローアップ及び広報

51. 委員会は，締約国が，本総括所見に含まれる勧告が完全に実施されるよう確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。委員会はまた，第4回・第5回政府報告，事前質問に対する書面回答及び本総括所見を同国の言語で広く入手できるようにすることも勧告する。

B. 報告及びフォローアップのための国内機構

52. 委員会は，締約国が，国際的及び地域的人権機構への報告書の調整や作成，並びにこれらの機構への関与，また，条約上の義務やこれら機構による勧告・決定の国内におけるフォローアップ，実施の調整及び追跡を任務とする，常設の国内機構を設置するよう勧告する。委員会は，こうした機構は専任のスタッフによって十分かつ継続的に支えられ，市民社会と組織的に協議する能力を持つべきであることを強調する。

C. 次回報告

53. 委員会は，締約国に対し，第6回・第7回政府報告を2024年11月21日までに提出するよう，また，本総括所見のフォローアップに関する情報を含めるよう慫慂する。報告書は，2014年1月31日に採択された委員会の条約別調和化報告ガイドライン（CRC/C/58/Rev.3）に沿って作成され，21,200語を超えるべきではない（総会決議68/268，パラ16）。語数制限を超えた報告書が提出された場合，締約国は，上述決議に則して報告書を短縮するよう求められることになる。締約国が報告書を見直し，再提出する立場にないときは，条約体による審査のための報告書の翻訳は保証できない。

54. 委員会はまた，締約国に対し，国際人権条約に基づく報告に関する調和化ガイドライン（共通コア文書及び条約別文書に関するガイドラインを含む）に含まれる共通コア文書に関する要件（HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I参照）及び総会決議68/268のパラ16に沿って，最新のコア文書を，42,400語を超えない範囲で提出することも慫慂する。

[redacted]

書記官送達
令和５年１月25日受領

[redacted]

乙第２号証

令和５年１月２５日判決言渡．同日原本領収　裁判所書記官

[redacted]　損害賠償請求事件

口頭弁論終結日　令和４年１０月５日

判　　決

当事者の表示　別紙当事者目録記載のとおり

主　　文

１　原告らの請求をいずれも棄却する。

２　訴訟費用は原告らの負担とする。

事　実　及　び　理　由

第１　請求

被告は、原告らに対し、それぞれ１１万円及びこれに対する令和２年３月１７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

第２　事案の概要等

１　事案の概要

原告らは、国会が婚姻中の一方親による他方親の同意を得ない未成年の子の連れ去り（引き離し）を防ぐための立法措置（以下「子の連れ去りを防ぐ法規制」という。）を正当な理由なく長期にわたって怠っていることにより自らの親権、監護権等が不当に制約され、精神的苦痛を受けたなどと主張して、被告に対し、国家賠償法（以下「国賠法」という。）１条１項に基づき、それぞれ、慰謝料等１１万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めている。

遅延損害金の起算日は、不法行為の後の日である令和２年３月１７日であり（訴状送達の日の翌日）、その利率は年５分である（平成２９年法律第４４号による改正前の民法）。

２　前提事実

以下の事実は、当事者間に争いがないか、弁論の全趣旨から容易に認められる。

(1) 原告らは、いずれも未成年の子の親である。

(2) 原告らの配偶者は、各原告との婚姻中に、その同意を得ずに子を連れて別居した。そのため、各原告は、現在も、子及び配偶者と別居している。

原告らは、本件訴え提起の時には、配偶者との間で婚姻関係にあったが、原告らの一部は、本件の係属中に、配偶者と離婚した。

3 争点

(1) 子の連れ去りを防ぐ法規制に係る国会の立法不作為の違法性（争点１）

(2) 原告らの損害（争点２）

4 争点１（子の連れ去りを防ぐ法規制に係る国会の立法不作為の違法性）に関する当事者の主張

（原告らの主張）

下記(1)のとおり、日本には、子の連れ去りを防ぐ法規制が存在せず、国会は、かかる立法を怠っている（以下「本件立法不作為」という。）。

そして、下記(2)のとおり、本件立法不作為は、国民に憲法上保障されている権利を制約している。さらに、下記(3)のとおり、本件立法不作為は、国民に憲法上保障されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に明白に違反するものであり、そうであるにもかかわらず、国会は、正当な理由なく長期にわたって立法措置を怠っている。

したがって、本件立法不作為は、国賠法１条１項の適用上、違法である。

(1) 子の連れ去りを防ぐ法規制が存在しないこと

ア 刑事法

日本には、子の連れ去りを処罰する刑事法が存在しない。

なお、未成年者拐取罪（略取又は誘拐罪。刑法２２４条）は、暴行、脅迫等を伴わず、かつ両親と同居している子を単に連れ去る行為には適用されないと解されており、子の連れ去りを処罰する刑事法には当たらない。

イ 民事法

日本には、子の連れ去りを違法とする民事法が存在しない。民法上、子の親権及び監護権を定める際に子を連れ去った者が不利になる規定、その他一方親による子の連れ去りを違法とする旨の規定はなく、民法７６６条１項には、面会交流が拒否された場合の執行規定や罰則規定が設けられていない。

裁判実務上も、離婚後単独親権制度の下、親権者又は主たる監護者の選択に際し、別居後の監護の継続性を重視する判断がされており、連れ去られた側が親権・監護権の獲得に際して不当に不利な立場におかれている。

ウ　親権の行使に係る手続規定

民法８１８条３項本文は、「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。」と規定する一方で、父母の意見が一致しない場合の手続規定を何ら設けていない。仮に、その手続規定が設けられていれば、子の連れ去りが発生しても手続規定により問題が解決されることになるため、子の連れ去りを行う意味が失われることになる。そうすると、その手続規定を設けることは、子の連れ去りを防ぐ法規制であるといえる。

エ　小括

したがって、日本には、子の連れ去りを防ぐ法規制が存在しない。

なお、子の連れ去りを一律に違法とする立法が相当でないのであれば、例えば、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約（以下「ハーグ条約」という。）１３条ｂと同様に、子の虐待や配偶者間の暴力がある場合の連れ去りを例外的に適法とするなどの規定を設ければ足りる。逆にいえば、ハーグ条約が上記例外を除いた子の連れ去りを一律に違法としていることからすると、国内法において、子の連れ去りを原則違法とする立法を行うことには何の問題もないし、ハーグ条約が定める例外の範囲を超えて子の連れ去りが適法となる場面を認めるのは相当でない。

(2)　本件立法不作為が、憲法上保障されている原告らの権利を制約すること

ア　原告らは、自らの子を育て又は教育する権利、すなわち、①子を産み育てるかどうかを意思決定する権利（リプロダクティブ権）、②親権、③監護権、④教育権及び⑤面会交流権を有する（以下それぞれ「権利①」から「権利⑤」という。）。

権利①～⑤は、いずれも憲法上保障される基本的人権である。すなわち、権利①は、子を産み育てることが人の幸福の源泉となり得るものであり、人格的生存の根源に関わるから、憲法１３条及び２４条１項により保障される。権利②～④は、諸外国においても自然権などとして保障されており、日本でも、子に対する責務であるのと同時に、婚姻や子との関わりにより発生する自然権として、憲法１３条、２４条１項、２項、２６条１項、２項等により保障される。権利⑤は、諸外国においても憲法上の権利とされており、日本でも、親子関係から当然に認められる自然権的な権利として、憲法１３条、２６条１項及び同条２項により保障される。

イ　原告らは、本件立法不作為により、配偶者に対して子の連れ去りに係る違法性を追及することができず、配偶者との間で子をめぐって従属する地位におかれ、子をそれまでのように育て又は教育することができなくなったから、権利①～⑤が制約されている。

なお、被告は、法規制により直ちに法律違反の行為がなくなるものではないと主張するが、国会が子の連れ去りを防ぐ法規制（裁判所主導の下、早期に、両親の合意又は審判により、主たる監護者や養育費等を定める制度を含む。）を制定することにより、不当な子の連れ去りを防ぐことができる。

(3)　本件立法不作為が憲法の規定に明白に違反し、国会が立法義務を負っているにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠っていること

以下の事情に照らせば、本件立法不作為は、明白に、憲法１３条、１４条

１項、２４条１項及び同条２項に違反するから、国会は、子の連れ去りを防ぐ法規制を制定する義務を負う。ところが、国会は、正当な理由なく長期にわたってこれを怠っている。

ア　諸外国は、子の連れ去りを違法とする法制度や、親権の行使に係る父母の意見が一致しない場合の手続を定める法制度を制定している。

イ　ハーグ条約に基づいて子の返還を請求するためには、連れ去り直前の子の常居所の国内法において、同意のない子の連れ去りが違法とされていることが必要であるが、日本は、ハーグ条約の締約国でありながら、子の連れ去りを違法とする国内法を制定しておらず、当該連れ去りは適法であるのに、日本側から外国側に対して子の返還を請求することができるという矛盾が生じている。

ウ　児童の権利に関する条約は、締約国は児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保するなどと定め、市民的及び政治的権利に関する国際規約（以下「自由権規約」という。）も、締約国は配偶者の権利及び責任の平等を確保するため必要な措置をとる旨定めるところ、本件立法不作為は、各規定の内容に違反している。

なお、条約は国内法に優先するから、国会は、条約と矛盾する国内法があれば、これを改正する義務を負う。

エ　子どもの権利委員会は、平成３１年２月１日、総括所見において、日本に対し、子の不法な移送の防止、国内法のハーグ条約との調和、子の返還等に関する司法決定の適正かつ迅速な実施のため、あらゆる必要な努力を行うことなどを勧告した。

オ　欧州議会は、令和２年５月２８日付け決議及び同年７月１日付け決議において、日本に対し、日本が子の連れ去りや面会について国際法を遵守していないように見え、これにより欧州連合市民である親が日本に居住する子と有意義な関係を形成できていないとして、国際法に適合する国内法規

制の制定を求めた。

カ　日本の国会、政府機関、政党等は、子の連れ去りによって生じる問題を取り上げて議論しており、国会及び政府において、子の連れ去りを防ぐ法規制の制定が必要である旨の共通認識が形成されている。

（被告の主張）

下記(1)のとおり、日本には、子の連れ去りを防ぐ法規制が存在する。

そして、下記(2)のとおり、原告らの主張する権利が国民に憲法上保障されているとはいえず、本件立法不作為によりこれが制約されているともいえない。さらに、下記(3)のとおり、本件立法不作為が憲法の規定に明白に違反するとはいえない。

したがって、本件立法不作為は、国賠法１条１項の適用上、違法ではない。

(1)　子の連れ去りを防ぐ法規制が存在すること

ア　刑事法

未成年者拐取罪は、行為主体が被害者の親権者であっても適用され得るから、子の連れ去りを処罰する刑事法の規定であるといえる。

イ　民事法

民法上、父母間における子の連れ去りを違法とする明文の規定は存在しないが、裁判実務において、連れ去りの具体的経緯、態様、子の年齢や意思等により、子の連れ去りが民法上の不法行為となり、違法と評価されることはあり得る。

さらに、民法７６６条１項は、離婚の際、子の利益の観点から面会交流を定めるべきことを明文化している上、いわゆるハーグ条約実施法は、ハーグ条約に基づく子の返還の強制執行に係る規律を設けている。

したがって、子の連れ去りを防ぐ民事法の規定が存在する。

ウ　親権の行使に係る手続規定

日本の法制度上、親権行使に係る父母の意見が一致しない場合の手続規

定は存在しないが、かかる規定の制定によって子の連れ去りを防ぎ得るわけではないから、かかる規定は、子の連れ去りを防ぐ手続規定に当たらない。

エ　小括

したがって、日本には、子の連れ去りを防ぐ法規制が存在する。

(2)　原告らの主張する権利が国民に憲法上保障されているとはいえず、本件立法不作為によりこれが制約されているともいえないこと

ア　権利①～⑤は、いずれも、憲法上保障されているものではないか、本件とは無関係の権利である。

すなわち、権利①は、憲法上保障されていない上、親の子に対する権利ではないから、本件で問題となるものではない。権利②～④は、子の学習権を保障するための親の職分又は社会的責務であり、憲法上の基本的人権ではない。権利⑤は、憲法上保障されるとする根拠がない。

イ　子の連れ去りを防ぐ法規制が存在しても、これに反して子を連れ去る親が生じることは避け難く、立法によっては、必ずしも子の連れ去りを防ぐことができないから、本件立法不作為により、原告らの主張する権利が制約されているわけではない。

また、権利②及び③について、子を連れ去られた親は、引き続き、当該子に対してこれらの権利を有しているのであり、本件立法不作為によって各権利を失うことはない。権利⑤についても、別居後の面会頻度の制限や面会拒絶の理由が子の連れ去りであるか否かは不明であり、本件立法不作為による権利の制約はない。

(3)　本件立法不作為が憲法の規定に明白に違反するとはいえず、国会は立法義務を負わないこと

以下のとおり、現在の日本の法制度は、個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠くものとはなっておらず、本件立法不作為が憲法

の規定に明白に違反するとはいえないから、国会は、原告らが主張する立法義務を負わない。

ア　婚姻中の一方親が他方親の同意を得ずに子を連れて転居する事情には、子を置いて家を出ることで子の監護に支障を生ずるなど様々なものがあり、その場合、子の連れ去りは家庭内暴力や虐待から逃れる有効な手段とも評価し得る。また、親権行使に係る父母の意見が一致しない場合の手続規定が設けられていないのは、子の利益という観点からみて、そのような場合に親権が行使されない方がよいことが多いと考えられたためであり、かかる手続規定が存在しないことにも一定の合理性がある。

また、裁判実務では、親権者の指定に当たり、現状の監護者がいずれであるかだけでなく、父母の監護能力や居住・教育環境等諸般の事情を総合的に考慮し、子の利益を最も優先することとされており、別居後の監護の継続性を偏重するような考え方は採用されていないし、子を無断で連れ去ったことを不利な事情とする例もある。しかも、前記(1)のとおり、連れ去り行為は、その経緯や態様等、個別の事情により違法と評価され得るのであるから、原告らが主張する立法措置を講じなくても、現行法上、大きな不都合が生じているわけではない。

そうすると、他方親の同意を得ない子の連れ去りを防ぐ規定を制定するのは、相当でない。

イ　原告らは、ハーグ条約に基づく子の返還請求に当たり、子の連れ去りを違法とする規定の整備が必要であると主張するが、前記(1)のとおり、日本における子の連れ去りが常に適法になるわけではない。

また、ハーグ条約は、異なる言語・環境の下での生活による有害な影響から子を国際的に保護するという理念に基づき、国境を超えて連れ去られた子を元の居住国に戻すべきことを規定するにすぎず、締約国内における子の連れ去りの法規制の在り方に何ら言及していない。そうすると、同条

約の締約国になったからといって、国内における子の連れ去りを違法とする立法義務が生じることにはならない。

ウ　原告らは、児童の権利条約及び自由権規約の規定を挙げるが、両条約は、権利の実現の確保の在り方について具体的に規定するものではなく、その在り方は各締約国に委ねられている。

すなわち、各条約の規定は、直ちに子の連れ去りを防ぐ法規制を設けることを締約国に求めるものではないから、被告がかかる立法義務を負う根拠とはならない。

エ　原告らは、子どもの権利委員会による総括所見を挙げるが、日本における子の連れ去りを防ぐ立法を求める内容ではない。また、総括所見は飽くまで勧告にとどまり、これによって被告に立法義務が生じるものではない。

オ　原告らは、欧州議会の決議を挙げるが、同決議は、日本に対しては無論のこと、欧州連合理事会や欧州委員会に対してすら法的拘束力を有するものではないから、被告が同決議に係る立法義務を負う根拠とはならない。

カ　国会や政府の議論は、専ら離婚後の親子間の交流についてのものであり、国会及び政府内において、子の連れ去りを防ぐ法規制の制定が必要である旨の共通認識が形成されているとはいえない。

5　争点２（原告らの損害）に関する当事者の主張

（原告らの主張）

(1)　原告らは、本件立法不作為により、基本的人権を不当に制約され、多大な精神的苦痛を受けた。かかる苦痛を慰謝するに足りる金額は、各原告について、１０万円を下らない。

(2)　原告らは、本件訴訟の追行を弁護士に依頼せざるを得なかった。本件と相当因果関係のある弁護士費用は、各原告について、１万円を下らない。

（被告の主張）

いずれも否認又は争う。

第３　当裁判所の判断

１　認定事実

前記前提事実に加え、括弧内に記載した書証（特に断らない限り枝番を含む。以下同じ。）及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

(1)　諸外国の法制度等

ア　ドイツには、策略等によって１８歳未満の者を親の一方から引き離した者に刑事罰を科するとの規定があり（同国刑法２３５条１項１号）、かかる規定は、一方の親が他方の親の配慮権や面会交流権を侵害して子を引き離した場合にも適用されると解されている（甲Ａ１２）。

同国には、親権の行使に係る父母の意見が一致しない場合、裁判所にその決定をゆだねるとの規定がある（甲Ａ２０）。

イ　フランスには、尊属が親権者等から未成年の子を奪取したときは刑事罰を科するとの規定があり（同国刑法２２７－７条）、かかる規定は、共同親権者の一方が他方のもとから子を奪取した場合にも適用されることがある（甲Ａ１０、１３、１７）。

同国には、ドイツと同様、親権の行使に係る父母の意見が一致しない場合、裁判所にその決定をゆだねるとの規定がある（甲Ａ１７、２０）。

ウ　イギリスには、１６歳未満の児童と一定の関係性を有する者が、児童に対して権限を有する者全員の同意なく又は裁判所の許可なく、児童をイギリス国外に連れ去ったときは、刑事罰を科するとの規定がある（同国児童奪取法１条。甲Ａ１４）。

エ　カナダやアメリカには、両親が親権又は監護権を共同で有する場合において、一方の親が他方の親の同意を得ないで子を連れ去ったときは刑事罰を科するとの規定がある（甲Ａ１５）。

(2)　日本が批准する条約の規律

日本が批准する条約には、大要、以下の規定がある。

ア　ハーグ条約

3条　子の連れ去り又は留置は、次のａ及びｂに該当する場合には、不法とする。

ａ　当該連れ去り又は留置の直前に当該子が常居所を有していた国の法令に基づいて個人、施設又は他の機関が共同又は単独で有する監護の権利を侵害していること。

ｂ　当該連れ去り若しくは留置の時にａに規定する監護の権利が共同若しくは単独で現実に行使されていたこと又は当該連れ去り若しくは留置がなかったならば当該権利が共同若しくは単独で現実に行使されていたであろうこと。

ａに規定する監護の権利は、特に、法令の適用により、司法上若しくは行政上の決定により、又はａに規定する国の法令に基づいて法的効果を有する合意により生ずるものとする。

１３条　（前略）要請を受けた国（略）は、子の返還に異議を申し立てる個人、施設又は他の機関が次のいずれかのことを証明する場合には、当該子の返還を命ずる義務を負わない。

ｂ　返還することによって子が心身に害悪を受け、又は他の耐え難い状態に置かれることとなる重大な危険があること。

（後略）

イ　児童の権利に関する条約

3条　児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。

2　締約国は、児童の父母、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者の権利及び義務を考慮に入れて、児童の福祉に必要な保

護及び養護を確保することを約束し、このため、すべての適当な立法上及び行政上の措置をとる。

4条　締約国は、この条約において認められる権利の実現のため、すべての適当な立法措置、行政措置その他の措置を講ずる。（略）

9条　締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りでない。（略）

3　締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。

ウ　自由権規約

23条（略）

4　この規約の締約国は、婚姻中及び婚姻の解消の際に、婚姻に係る配偶者の権利及び責任の平等を確保するため、適当な措置をとる。（略）

(3)　国際機関による勧告等

ア　子どもの権利委員会は、平成31年2月1日、日本の第4回・第5回政府報告を審査し、同報告に関する総括所見を採択した（甲A25、乙1）。上記総括所見には、大要、以下の内容が含まれている。

27　委員会は、締約国が、以下を行うため、十分な人的資源、技術的資源及び財源に裏付けられたあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。

(b)　非同居親との人的な関係及び直接の接触を維持するための児童の権利が定期的に行使できることを確保すること。

31　委員会は、締約国が、子の不法な連れ去り及び留置を防止し、及びこれに対処し、国内法をハーグ条約と調和させ、子の返還及び面会交流権に関する司法決定の適正かつ迅速な実施を確保するために、あら

ゆる必要な努力を行うよう勧告する。委員会はまた、締約国が、関連諸国、特に締約国が監護又は面会権に関する協定を署名している国々との対話及び協議を強化するよう勧告する。

イ　欧州連合は、令和２年１月３１日、日本に対し、児童の権利条約やハーグ条約等の国際的な約束を確保するため、国内の法的枠組み及びその効果的な実施を改善するよう求めた（甲Ａ５８、５９）。

ウ　欧州議会の請願委員会は、令和２年５月２８日及び同年７月１日、日本における欧州連合の子の連れ去りについて、大要、以下の内容の決議を採択した。（甲Ａ５８、５９）

(ア)　欧州連合の戦略的パートナーたる日本が、子の連れ去り事件において国際的なルールを遵守していないように見えることに遺憾を表明し注目する。

(イ)　日本の当局に対し、日本の国内法を国際公約と整合させ、訪問権と面会権が児童の権利に関する条約の下での義務を反映していることを確保するために、日本の法制度に必要な変更を導入することを求める。

(4)　子の連れ去りに関する国内の議論等

ア　日本の学者や国会議員等の一部は、令和元年頃以降、現在の日本の法制度において、子の親権者となることを希望する親が監護実績を作るために実力を行使して子を連れ去るという事態が生じ得る、最初に子を連れ去った側が親権者の指定において有利になる旨の指摘をしている（甲Ａ１８、４０の２、甲Ａ４１、４２、５１）。

公益社団法人商事法務研究会は、令和３年２月頃、家族法研究会報告書において、両親が別居する際に子の養育や面会計画を定める手続規定を設置することを更に検討してはどうかと提言した。併せて、同意なき連れ去りがあった場合の事実状態を無条件に追認することは相当でないとの立場があることを紹介し、そのような立場からは、別居後の環境に対する子の

適応状況を重視してはならないという規律を設ける方向性も考えられると述べた。（甲Ａ１４５の１２７～１３１頁）

イ　超党派共同養育支援議員連盟は、令和４年４月２７日頃、国の関係機関に対し、いわゆる「連れ去り勝ち」を防ぐために、親権を定めるに当たり、正当な理由なく子を連れ去った事実を十分考慮することなどを求める書面を提出した（甲Ａ１５３）。

自由民主党の政務調査会法務部会は、令和４年６月２１日、法務大臣に対し、ハーグ条約及び児童の権利に関する条約との整合性を確保する観点から、国内法の再検討をすべきである旨申し入れた（甲Ａ１６５）。

2　争点１（子の連れ去りを防ぐ法規制に係る国会の立法不作為の違法性）

(1)　判断枠組み

国賠法１条１項は、国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個々の国民に対して負担する職務上の法的義務に違反して当該国民に損害を加えたときに、国又は公共団体がこれを賠償する責任を負うことを規定するものであるところ、国会議員の立法行為又は立法不作為が同項の適用上違法となるかどうかは、国会議員の立法過程における行動が個々の国民に対して負う職務上の法的義務に違反したかどうかの問題であり、立法の内容の違憲性の問題とは区別されるべきものである。そして、上記行動についての評価は原則として国民の政治的判断に委ねられるべき事柄であって、仮に当該立法の内容が憲法の規定に違反するものであるとしても、そのゆえに国会議員の立法行為又は立法不作為が直ちに国賠法１条１項の適用上違法の評価を受けるものではない。もっとも、法律の規定が憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反するものであることが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠る場合などにおいては、国会議員の立法過程における行動が上記職務上の法的義務に違反したものとして、例外的に、そ

の立法不作為は、国賠法１条１項の規定の適用上違法の評価を受けることがあるというべきである（最高裁平成２５年（オ）第１０７９号同２７年１２月１６日大法廷判決・民集６９巻８号２４２７頁参照）。

この理は、法律の規定が存在しないことにより、憲法上保障され又は保護されている権利利益が合理的な理由なく制約され、それが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたってその立法措置を怠る場合にも、妥当すると解すべきである。

そこで、前提として、本件立法不作為が認められるか（下記(2)）を検討した上で、原告らが主張する権利が憲法上保障され、本件立法不作為により制約されているといえるか（下記(3)）、本件立法不作為が、原告らの主張する権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反するものであることが明白であるか（下記(4)）を検討する。

(2) 本件立法不作為が認められるか

ア 刑事法

刑法２２４条は、「未成年者を略取し、又は誘拐した者」について刑罰を科しており、未成年者の親権者や監護者も、同条の行為主体となり得ると解されている。

しかし、同条に規定する犯罪が成立するためには、暴行、脅迫、欺罔又は誘惑を手段とすることを要し、これらの手段を用いない行為は不可罰とされている。親権者による子の連れ去りには様々な態様があり得るところ、配偶者の不在等の際に、暴行、脅迫、欺罔又は誘惑を手段とせず、単に子を連れて住居を離れるといった態様のものも想定され、同条は、このような態様による連れ去りには、適用されないものと解される。

原告らの主張する刑事法の規定は、諸外国の法律の規定（認定事実(1)）にみられるように、手段を問わず、他方親の同意のない子の連れ去りを処罰するものであると解されるが、刑法２２４条は、上記のとおり、本件で

問題となっている子の連れ去りの一部に適用し得るにすぎず、手段を問わずに他方親の同意のない子の連れ去りを処罰するものではないから、同条をもって、原告らの主張する刑事法の規定が存在するとはいえない。

イ　民事法

民法その他の民事法において、他方親の同意のない子の連れ去りを違法とする旨定める明文の規定はない。そして、上記の子の連れ去りが他方親に対する不法行為を構成するか否かは、行為態様に加え、経緯、目的等を総合考慮して判断されるものであり、裁判実務上、違法と評価することを原則とするとの運用が定着しているとまではいえない。

そうすると、原告らの主張する民事法の規定が存在するとはいえない。

これに対し、被告は、民法が、離婚の際、子の利益の観点から面会交流を定めるべきことを明文化している上、いわゆるハーグ条約実施法は、ハーグ条約に基づく子の返還の強制執行に係る規律を設けているから、原告らが主張する民事法の規定が存在すると主張する。しかし、被告が主張する各規定は、子の連れ去りを違法とする旨明言するものではないし、いわゆるハーグ条約実施法は、外国から日本に連れ去られた子の返還に係る規定にとどまり、日本から外国に連れ去られた子の返還について規定するものではないから、原告らが主張する民事法の規定には該当しない。

ウ　親権の行使に係る手続規定

民法その他の民事法において、親権行使に係る父母の意見が一致しない場合の手続（子を連れ去られた場合における事後処理のための手続を含む。）を定める明文の規定はない。そして、子の監護者指定の調停・審判制度や子の引渡しの調停・審判制度が上記の手続規定に当たるとはいえない。

そうすると、原告らが主張する親権行使に係る手続規定が存在するとはいえない。

これに対し、被告は、親権行使に係る父母の意見が一致しない場合の手続規定の制定によって子の連れ去りを防ぎ得るわけではないから、かかる規定は、子の連れ去りを防ぐ手続規定に当たらないと主張する。しかし、諸外国の法制度には、子の連れ去りを違法とした上で、親権行使に係る父母の意見が一致しない場合の手続規定が設けられているものがあるところ（認定事実(1)）、子の連れ去りが行われるケースには、親権行使に係る父母の意見が一致しないことを背景とするものも含まれているのであり、かかる手続規定の制定によって子の連れ去りを一切防ぎ得ないとまで断ずることはできない。

エ　小括

したがって、原告らが主張する刑事法，民事法及び親権の行使に係る手続規定が現に存在するとはいえず、本件立法不作為が認められるというべきである。

(3)　権利①～⑤が憲法上保障され、本件立法不作為によりこれらが制約されているか

ア　権利②～④（親権、監護権及び教育権）について

原告らは、権利②～④が、憲法上保障されると主張する。

親権の主たる内容は、子の監護及び教育であって（民法８２０条）、監護権や教育権は、親権の一内容とみるべきであり、原告らが本件で問題とする監護権や教育権も、親権と独立する内容をいうものであるとは解されない。親権が憲法上保障されるか否かが明らかになれば、監護権や教育権が憲法上保障されるか否かも自ずと明らかになるというべきであるから、以下では、親権が憲法上保障されるか否かについて検討する。

(ア)　原告らは、親権は、婚姻や子との関わりにより発生する自然権であるから、日本においても憲法上保障されると主張する。

親権には、子の居所の指定、懲戒、職業の許可、財産の管理などが含

まれる（民法８２１条～８２４条）。親権の行使は、子の監護及び教育を通じて次世代の人格の形成や発展に寄与する営みであり、かかる営みは、子の人格形成のみならず、親権者自身の自己実現にも資するものということができる。その意味で、親権は、子の出生により当然に行使し得るものとして、自然権に類似する側面を有することは否定し難い。

しかし、親権の行使は、いずれも、子の利益のためにされなければならず（同法８２０条、８３４条～８３５条参照）、そうであるからこそ、親権は、権利であると同時に親権者の義務であるとされているのであって（同法８２０条）、例えば、信教の自由（憲法２０条１項）が宗教を信仰する自由を保障するのと同時に、信仰しない自由を保障しているのと異なり、親権については、これを行使しないという事態は、原則として許容されていない。そうすると、親権は、本来的には、親権者に対して子の利益となる監護及び教育を行わせるという、いわば利他的な行為を要求し、その中で、監護及び教育の内容等について一定程度の裁量を与えたものにすぎないといえ、上記のとおり、その営みが親権者自身の自己実現にも資するものであって、単なる機械的な利他行為にとどまらないという点を考慮したとしても、憲法上の他の人権とは性質を異にするものといわざるを得ない。このような性質を有する親権が、憲法上保障された基本的人権であると解することはできない。

(イ) 原告らは、親権が諸外国においても憲法上保障されていると主張するが、諸外国の制度が日本の憲法の解釈に直ちに影響を与えるということはできず、前記(ア)の結論を左右する事情には当たらない。

(ウ) そうすると、権利②～④が憲法上保障されているということはできない。

イ 権利①（リプロダクティブ権）について

リプロダクティブ権は、主として性及び生殖に関する自己決定権を意味

する用語であり、第一次的には、子の出産に焦点を当てた権利であると解される。権利①が人の幸福の源泉となり得るとしても、出産それ自体と子の連れ去りとの関連性が乏しく、本件立法不作為によって権利①が直接制約されているとはいい難い。

なお、子を産むという点のみを権利①の対象とし、出産に引き続く子の養育をその対象外としたのでは、性及び生殖に関する自己決定権の保護として不十分であるとして、権利①には、出産に関する事項に加え、第二次的に、子の養育に関する事項も含まれていると解する余地もある。しかし、そのように解したとしても、権利①のうち子の養育に関する事項は、権利②～④の内容と実質的に重なるものであり、権利②～④が憲法上保障されるといえないことは、前記アのとおりである。

そうすると、権利①のうち、出産に関する事項は、本件立法不作為によって制約されている権利であるとはいえず、養育に関する事項は、憲法上保障されているとはいえない。

ウ　権利⑤（面会交流権）について

原告らは、面会交流権が憲法上保障されると主張する。しかし、面会交流をどのような内容及び方法で実現すべきかについては、子の利益ないし福祉に配慮して検討されるべきものであって、その観点から、面会交流を全面的に制限すべき場合もある。このような性質に照らすと、面会交流権の実質は、それが親自身の自己実現にも資するものである点を含め、権利②～④の内容と重なるというべきである。そして、権利②～④が憲法上保障されるとはいえないことは、前記アのとおりである。

原告らは、面会交流権が諸外国においても憲法上保障されていると主張するが、前記ア(イ)のとおり、諸外国の制度が日本の憲法の解釈に直ちに影響を与えるということはできない。

そうすると、権利⑤が憲法上保障されているとはいえない。

エ　原告らは、子を連れ去られた親は権利①～⑤を行使し得ず、子を連れ去った親のみが権利①～⑤を行使し得るから、本件立法不作為は憲法１４条１項に違反することが明白であるとも主張するようである。

しかし、憲法１４条１項は、事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づくものでない限り、法的な差別的取扱いをすることを禁止する趣旨と解すべきである（最高裁昭和３７年（オ）第１４７２号同３９年５月２７日大法廷判決・民集１８巻４号６７６頁等参照）。子を連れ去られたとしても、その時点における法的地位には何ら影響がなく、権利①～⑤を法的に主張又は行使し得なくなるわけではないから、子を連れ去った親との間で法的な差別的取扱いがされているということはできない。

そうすると、本件立法不作為が憲法１４条１項に違反するということはできない。

(4)　本件立法不作為が原告らの権利を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反することが明白であるか

ア　日本において、一方親の同意を得ない子の連れ去りを違法とする規定、その他原告らが主張する法規制は存在しないところ（前記(2)）、学者や国会議員等の一部から、遅くとも令和元年頃以降、現行の法制度の下で、不当な子の連れ去りが発生し得ることが指摘されるようになった。令和３年には、公益財団法人商事法務研究会により、両親が別居する際に子の養育計画等を定める手続規定を創設することなどの提言をまとめた報告書が公表されているが、その報告書には、同意なき連れ去りがあった場合の事実状態を無条件に追認することは相当でないとの見解があることを前提に、別居後の環境に対する子の適応状況を重視してはならないという規律を設ける方向性についても言及されている。さらに、ハーグ条約及び児童の権利に関する条約との整合性を確保する観点からの国内法の再検討も、提案されている。（認定事実(4)）

また、国際機関は、遅くとも平成３１年以降、日本に対し、複数回にわたり、日本法を児童の権利条約やハーグ条約等と整合させるよう勧告している（認定事実(3)）。国際機関が指摘する各条約（認定事実(2)）が、子の常居所国の法令によれば個人の監護権を侵害するなどの場合、子の連れ去りが原則として違法になる旨規定するほか（ハーグ条約）、締約国に対して、児童の意思に反する父母からの分離を防ぐための立法措置等を講ずること（児童の権利に関する条約）、及び婚姻に係る配偶者の権利等の平等を確保するための適当な措置をとることを求めていること（自由権規約）に照らすと、国際機関によるこれらの勧告が、日本の家族法制度に一定の問題提起をするものであることは明らかである。

以上の事情によれば、日本の家族法制度については、国内でその在り方が議論されているにとどまらず、国際的にみても、条約の規定との整合性という観点等から問題視する立場があり、憲法９８条２項が定める条約遵守義務に照らしても、他方親の同意なき子の連れ去りを違法とする規定、その他原告らが主張する法規制の制定は、今後の国内法の在り方についての一つの選択肢として、議論されるべきものということができる。

イ　しかし、前記アで指摘した条約の規定や国際機関の勧告は、「締約国は、（略）児童の福祉に必要な保護及び養護を確保することを約束し、このため、すべての適当な立法上及び行政上の措置をとる。」、「日本の国内法を国際公約と整合させ、訪問権と面会権が児童の権利に関する条約の下での義務を反映していることを確保するために、日本の法制度に必要な変更を導入することを求める。」など、抽象的なものにとどまっている。加えて、子の連れ去りを防ぐ法規制を制定するか否か、また仮に制定するとした場合の立法の具体的内容をどのように定めるかについては、締約国の伝統、親子・婚姻関係に係る国民の価値観等を総合的に考慮すべきであり、立法の是非の判断やその具体的内容は、各締約国の裁量に委ねられている

といえるから、これらの条約の規定や国際機関の勧告が、直ちに憲法違反の明白性を基礎付けるものとはいい難い。

また、家庭裁判所は、親権者や監護者の指定に当たり、現状の監護者がいずれであるかのみならず、父母の監護能力、居住・教育環境、子の年齢・性別・心身の発育状況・意向、従来の環境への適応状況など、親側の事情及び子側の事情を総合的に考慮しており、別居後の監護状況を特に重視する判断をしているわけではない。このことについて、旧来重視していたとされるいわゆる継続性の原則（別居後の監護状況の継続性を重視する考え方）は、現在の裁判実務において限定的に考えられ、むしろ子の出生から現在までの生活環境及び監護の状況を重視しているとの指摘もされている（乙７）。

上記の各状況を踏まえると、日本国内において、子の連れ去りを防ぐ法規制が必要であることにつき、国民に共通認識が形成されているとはいい難く、立法の具体的内容についても、なお検討すべき事項が多数存在するものといえ、国民の議論が十分にされている状態であるとはいえない。

原告らは、そのほか、両親が離婚した子は愛情ホルモンであるオキシトシンが少ないことや、片親との交流の断絶が子の心理的、人格的成長にも悪影響を及ぼすことなど、多数の事実を指摘するが、これらの事実及び認定事実の内容を精査しても、子の連れ去りを防ぐ法規制が必要であることについて、国民に共通認識が形成されているとまではいえず、本件の結論を左右しない。

ウ　そうすると、仮に、本件立法不作為が、原告らの憲法上保障され又は保護されている権利利益を制約するものであるとしても、憲法の規定に違反するものであることが明白であるということはできない。

(5)　争点１の総括

以上によれば、原告らの主張する権利が憲法上保障されているとはいえず、

又は本件立法不作為により制約されているとはいえず（前記(3)）、本件立法不作為が、原告らの権利を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反することが明白であるともいえない（前記(4)）。

したがって、その余の点を検討するまでもなく、本件立法不作為が国賠法１条１項の適用上違法になるとはいえない。

第４　結論

よって、争点２を判断するまでもなく、原告らの請求はいずれも理由がないから棄却する。

東京地方裁判所民事第５０部

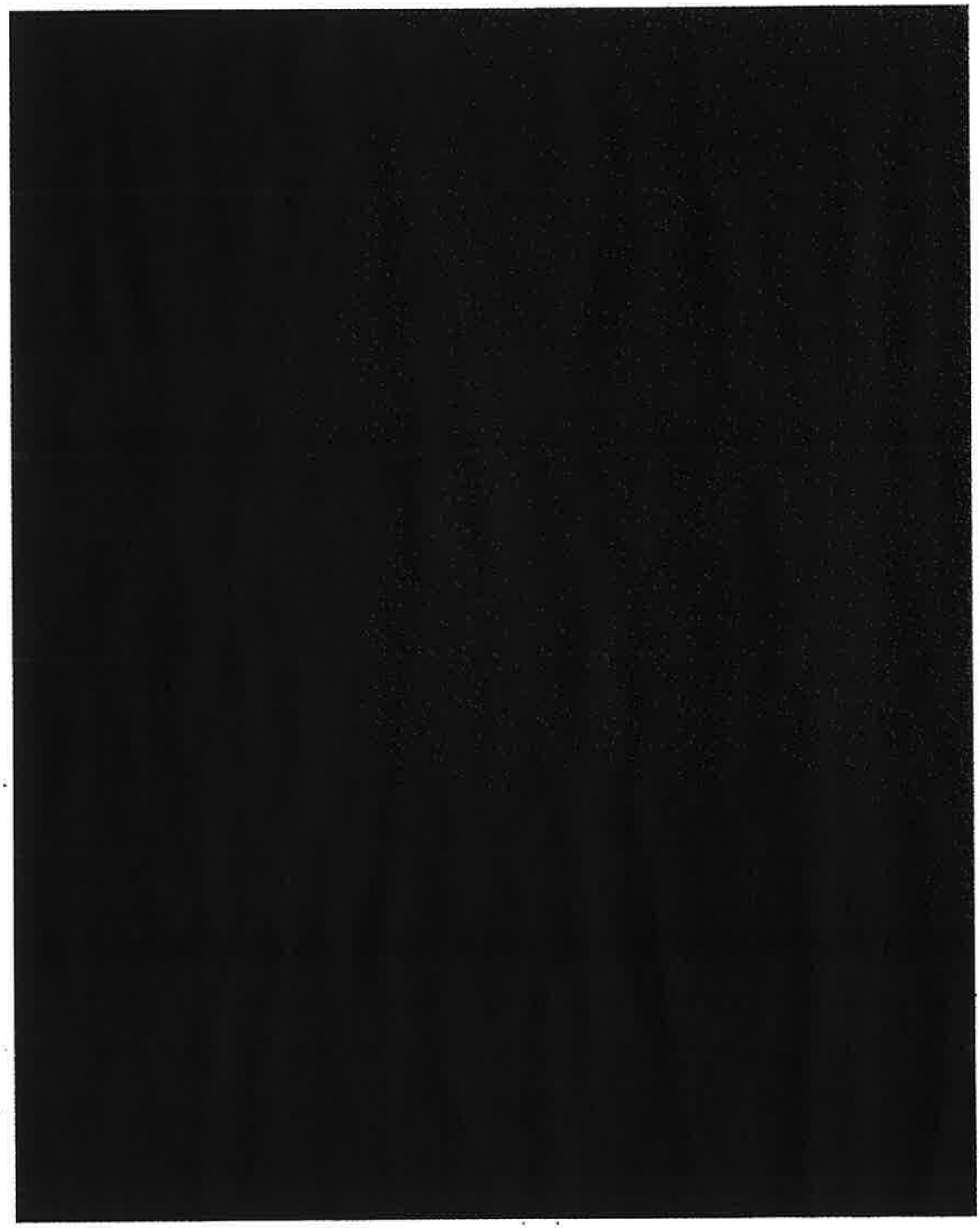
裁判長裁判官　野口宣大

裁判官　小川恵[redacted]

裁判官　大野志[redacted]

別紙

当 事 者 目 録



[redacted]

東京都千代田区霞が関１－１－１

被　　告　　国

同代表者法務大臣　　齋　藤　　健

同指定代理人　　[redacted]

同

同

東京 21-011250

COPY COPY COPY COPY COPY

これは正本である。

令和５年１月２５日

東京地方裁判所民事第５０部

裁判所書記官　　間　部　早　苗

[redacted]

書記官送達 [redacted]
令和5年9月11日 午前/後 12時3分

令和5年9月27日
判決言渡
同日原本領収
裁判所書記官

乙第3号証

令和[redacted]年（[redacted]）第[redacted]号　損害賠償請求控訴事件（原審・東京地方裁判所令和[redacted]年（[redacted]第[redacted]号）

口頭弁論終結日　令和5年6月19日

判　　決

当事者の表示　別紙当事者目録記載のとおり

主　　文

1　本件控訴をいずれも棄却する。

2　控訴費用は控訴人らの負担とする。

事　実　及　び　理　由

第1　控訴の趣旨

1　原判決を取り消す。

2　被控訴人は、控訴人らに対し、それぞれ11万円及びこれに対する令和2年3月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2　事案の概要（以下、略称は、本判決において新たに定めるもののほかは、原判決の例による。）

1　本件は、控訴人らが、国会が婚姻中の一方親による他方親の同意を得ない未成年の子の連れ去りを防ぐための立法措置（子の連れ去りを防ぐ法規制）を執ることを正当な理由なく長期にわたって怠っていることにより、控訴人らの親権等憲法上保障された権利が合理的な理由なく制約され、精神的苦痛を受けたなどと主張して、被控訴人に対し、国家賠償法（国賠法）1条1項に基づき、それぞれ、慰謝料等11万円及びこれに対する不法行為後の日（訴状送達の日の翌日）である令和2年3月17日から支払済みまで民法（平成29年法律第44号による改正前のもの）所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

2　原審は、控訴人らが主張する親権等は憲法上保障されているとはいえず、子の連れ去りを防ぐ法規制がないことにより、控訴人らの権利を合理的な理由な

東　京　高　等　裁　判　所

く制約し憲法に違反していることが明白であるとはいえないなどとして、控訴人らの請求をいずれも棄却する旨の判決をした。

控訴人らは、原判決の上記判断を不服として控訴した。

3. 前提事実、争点及び争点に関する当事者の主張は、以下のとおり補正するほかは、原判決「事実及び理由」中の「第２　事案の概要等」の２から５までに記載のとおりであるから、これを引用する。

(1) 原判決５頁１９行目の「子どもの権利委員会」を「国連・子どもの権利委員会（以下、単に「子どもの権利委員会」という。）」と改める。

(2) 原判決９頁７行目、同頁１１行目及び同頁１４行目の「被告」をいずれも「国会」と改める。

第３　当裁判所の判断

1　当裁判所も、控訴人らの請求はいずれも理由がないと判断する。その理由は、以下のとおり補正するほかは、原判決「事実及び理由」中の「第３　当裁判所の判断」１及び２に記載のとおりであるから、これを引用する。

(1) 原判決１５頁２行目の「いうべきである。」の次に「そして、国民に憲法上保障されている権利利益等を保護するための立法措置を執ることが必要不可欠であり、それが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠るときは、上記の例外的な場合に当たるものと解するのが相当である。」を、同頁３行目の「２４２７頁」の次に「、最高裁昭和６０年１１月２１日第一小法廷判決・民集３９巻７号１５１２頁、最高裁平成１７年９月１４日大法廷判決・民集５９巻７号２０８７頁（以下「平成１７年最判」という。）、最高裁令和４年５月２５日大法廷判決・民集７６巻４号７１１頁」をそれぞれ加える。

(2) 原判決１５頁８行目及び１３行目の各「本件立法不作為が認められるか」をいずれも「子の連れ去りを防ぐ法規制が存在しないといえるか」と、同頁９～１０行目の「原告らが主張する権利が憲法上保障され、本件立法不作為

東　京　高　等　裁　判　所

により制約されているといえるか」を「権利①～⑤が憲法上保障されているといえるか」と、同頁１０～１２行目の「本件立法不作為が、原告らの主張する権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反するものであることが明白であるか」を「子の連れ去りを防ぐ法規制を設けることが必要不可欠であり、それが明白といえるか」とそれぞれ改める。

(3) 原判決１７頁１２行目の「本件立法不作為」から同頁１３行目末尾までを「子の連れ去りを防ぐ法規制があるとはいい難い。」と改める。

(4) 原判決１７頁１４行目冒頭から同頁１５行目末尾までを「(3) 権利①～⑤が憲法上保障されているといえるか」と改める。

(5) 原判決１８頁１９行目の「基本的人権」の次に「ないし権利利益」を加える。

(6) 原判決１８頁２２行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

「 また、控訴人らは、親権が親権者の権利であると同時に義務であるとされていることは、親権が基本的人権であることを直ちに否定する理由とはならない旨主張し、平成１７年最判が、選挙権につき、公務としての性格を併せ持つとしつつ、立法不作為による損害賠償責任を肯定したことを指摘する。しかし、選挙権は憲法１５条１項に明記された国民の権利である一方、前記説示のとおり、親権は、飽くまで子のための利他的な権利であり、それを行使するか否かについての自由がない特殊な性質を有するものであることに照らせば、親権を選挙権と同列に論ずることは相当とはいえない。

したがって、控訴人らの上記主張は採用することができない。」

(7) 原判決２０頁１２行目末尾に、改行の上、次のとおり加える。

「オ もっとも、権利①～⑤が憲法上保障された権利とまではいえないとしても、これらの権利、殊に親権は、家族制度の根幹に関わる重要な人格的利益であり、憲法２４条２項の「婚姻及び家族に関するその他の事項」

東 京 高 等 裁 判 所

に含まれると解されることに照らせば、それが合理的な理由なく制約されているため、所要の立法措置を執ることが必要不可欠であり、それが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠るときは、立法不作為による損害賠償責任の発生を肯定する余地がある。そこで、以下において、子の連れ去りを防ぐ法規制が存在しないことにより、控訴人らの親権が合理的な理由なく制約されているため、これを保護するための立法措置を執ることが必要不可欠といえるかなどについて検討を加える。」

(8) 原判決２０頁１３～１４行目を「(4) 子の連れ去りを防ぐ法規制を設けることが必要不可欠であり、それが明白といえるか」を改める。

(9) 原判決２１頁４行目の「常居所国」を「常居所地国」と改める。

(10) 原判決２２頁１行目の「から、」から同頁２行目の「いい難い」までを削除する。

(11) 原判決２２頁１２行目冒頭から２３頁５行目末尾までを次のとおり改める。

「 そして、そもそも婚姻中の一方親が他方親の同意を得ることなく子を連れ去るのは様々なケースがあるのであり、他方親が一方親や子に対し、暴力や虐待を加えているなど、一方親が他方親の同意を得ることなく子を連れ去ることについて、やむを得ない事由があるといえることも少なからずある。このような場合において、上記連れ去りを違法であるとするのは相当とはいえないし、違法であるとする共通認識が形成されている事実もない。この点、家庭裁判所においても、婚姻中の一方親が他方親の同意を得ることなく子を連れ去ったとして、他方親から申し立てられた子の監護者指定及び子の引渡しを求める審判等において、他方親の同意を得ることなく子を連れ去ったことを一律違法又は原則として違法とするのではなく、従前の子の監護状況、一方親が他方親の同意を得ることなく子を連れ去るに至った経緯、手段及び方法、子の年齢及び意向等を総合考慮した上、子

の連れ去りが違法であるか否かを判断しているところ、このような家裁実務に対し、強い批判があることはうかがわれない。そうすると、我が国において、上記連れ去りを違法又は原則として違法とした上で、これを防ぐ法規制を設けることが必要不可欠であるとはいえない。

もっとも、上記のとおり、婚姻中の一方親が他方親の同意を得ることなく子を連れ去ることが違法と評価される場合はあり得るのであり、このようにして子を連れ去られた他方親の置かれた立場や心情等には十分な配慮を要するものといえる。しかし、上記のとおり、婚姻中の一方親が他方親の同意を得ることなく子を連れ去るのは様々なケースがあるのであり、これが違法とされる個別事案については、家庭裁判所に対し、子の引渡しを求める審判や審判前の保全処分を求める申立てをすることができるのであり、こうした審判等を始めとする司法的救済のほかに、子の連れ去りを防ぐ法規制を設けることが必要不可欠であるとまでは直ちには認め難いし、当該法規制が必要不可欠であるとの共通認識が形成されているともいえない。

(5) 以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、国会において、子の連れ去りを防ぐ法規制として所要の立法措置を執らないことが国賠法１条１項の適用上違法であるとはいえない。」

２ 控訴人らは、当審においても、権利①～⑤が憲法上保障されているなどと種々主張するが、原判決を補正の上引用して説示したところによれば、いずれも採用することができない。

第４ 結論

以上の次第で、控訴人らの請求をいずれも棄却すべきものとした原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、これをいずれも棄却することとして、主文のとおり判決する。

東 京 高 等 裁 判 所

東京高等裁判所第１民事部

裁判長裁判官 志田原信三

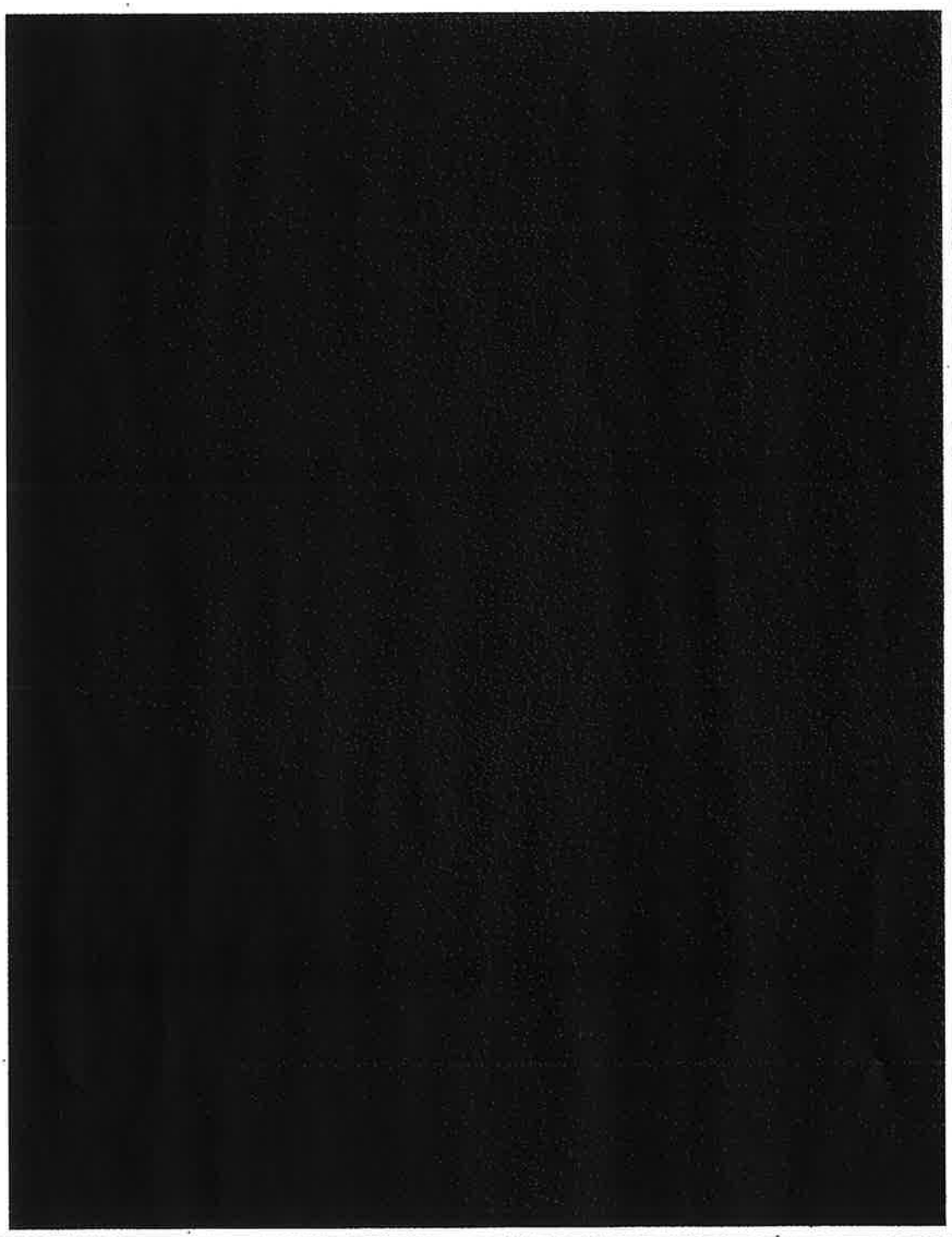
裁判官 瀬戸啓子

裁判官 吉田純一郎

東 京 高 等 裁 判 所

別紙

当 事 者 目 録



東 京 高 等 裁 判 所

[redacted]

東京都千代田区霞が関１－１－１

被控訴人　国

同代表者法務大臣　小泉龍司

同指定代理人　[redacted]

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

東京高等裁判所

東京(高) 19-012276

これは正本である。

令和５年９月２７日

東京高等裁判所第１民事部

裁判所書記官　熊　沢　宣之

[redacted]

書記官送達
令和5年6月22日受領　印 [redacted]

乙第4号証

令和5年6月22日判決言渡　同日原本領収　裁判所書記官

令和[redacted]年([redacted])第[redacted]号　損害賠償請求事件

口頭弁論終結日　令和5年3月2日

判　　決

当事者の表示　別紙当事者目録記載のとおり

主　　文

1　原告らの請求をいずれも棄却する。

2　訴訟費用は原告らの負担とする。

事　実　及　び　理　由

第1　請求

別紙請求目録記載のとおり

第2　事案の概要等

1　事案の概要

本件は、法律上又は事実上の配偶者及び子と別居する原告らが、被告である国が「養育権」を保障する法制度を整備しないことが憲法13条又は14条1項に違反することが明白であり、正当な理由なく長期にわたって立法措置を怠っていることが国家賠償法（以下「国賠法」という。）1条1項の違法を構成し、これにより原告らが精神的苦痛を被ったと主張して、被告に対し、国賠法1条1項に基づく損害賠償として、別紙請求目録記載の各損害賠償金及びこれに対する不法行為の後の日である令和元年12月26日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで民法（平成29年法律第44号による改正前のもの。以下、単に「民法」と記載する場合には、これを指す。）所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

2　前提事実（当事者間に争いのない事実並びに括弧内に記載した証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実。以下、単に「前提事実」という。）

(1) [redacted]

[redacted]並びに[redacted]は、配偶者と婚姻中に子を設けた後に離婚をし（同人らの子らの親権者はそれぞれ他方配偶者である。）、現在配偶者であった者及び子と別居している。（弁論の全趣旨）

なお、[redacted]は、本件訴訟の係属中である令和３年１０月２６日に死亡し、その相続人である[redacted]が訴訟承継人となった。（当裁判所に顕著）

(2) 原告[redacted]は、事実婚の関係にあった者との間で子を設けた後に同関係を解消し、現在事実上の配偶者であった者及び子と別居している。（弁論の全趣旨）

(3) 原告[redacted]は、配偶者との婚姻中に子を設け、現在も配偶者との法律婚の関係は継続しているものの、配偶者及び子と別居している。（弁論の全趣旨）

(4) 民法は、法律婚の関係にある父母は、原則として共同して親権を行うものとする（同法８１８条３項）一方、法律婚の関係にない父母（離婚後の父母及び一度も法律婚の関係にあったことのない父母）は、必ずその一方が単独で親権を行うものとしている（同法８１９条１項～５項。以下、同法８１８条３項と合わせて「本件各規定」という。）。

3　争点

(1) 被告が本件各規定につき改廃しないことが、立法不作為として国賠法１条１項所定の「違法」を構成するか（争点１）

(2) 損害の発生及びその数額（争点２）

4　争点に関する当事者の主張

(1) 争点１（被告が本件各規定につき改廃しないことが、立法不作為として国賠法１条１項所定の「違法」を構成するか）について

（原告らの主張）

ア　憲法１３条違反について

(ｱ) 「養育権」が憲法１３条に基づき保障されること

子を養育する意思と能力を有する親が子を監護・養育する権利（以下「養育権」ということがある。）は、憲法１３条に基づく幸福追求権として憲法上保障され、不当な侵害を受けないことは当然のことである。

上記の理は、最高裁昭和４３年（あ）第１６１４号同５１年５月２１日大法廷判決・刑集３０巻５号６１５頁において、親子の自然的関係に基づいて親が子の監護・養育を行うことが当然の前提とされていること、諸外国の法制度等を検討すれば、親の子の監護・養育は、国、民族、文化等に左右されない普遍的な人権として保障されるべきであると解されること、児童の権利に関する条約（平成６年条約第２号）においても、子が父母から養育を受ける権利を基本的人権として保障していることなどからみても明らかである。

(ｲ) 現行の親権に関する規律が原告らの養育権を侵害すること

原告らは、それぞれの子に対して、養育権を有するところ、現行法上の親が子の監護・養育する権利としての親権は、前提事実(4)のとおり、法律婚の関係にある父母においては共同して行う一方、法律婚の関係にない父母（一度も法律婚の関係にあったことのない父母、離婚後の父母、事実婚の状態にある父母を含む。以下「非婚の父母」ということがある。）はその一方が単独で親権を行うこととされている（この制度全体を「非婚時単独親権制」ということがある。）。非婚時単独親権制は、父母間に子の養育に関する意見の対立があったとしても、これを調整するための法的な仕組みを一切用意せず、父母間の事実上の力関係に解決を委ねるか、親権を共同で行わせないこととして養育に関する決定権自体を一方の親に集中させるかによって解決を図ろうとするものである。以下の諸点を考慮すれば、非婚時単独親権制は、原告らの養育権を不当に侵害するものである。

a　親は子に対する養育権を有するところ、本件各規定は、父母の婚姻中以外は、父母間の意見の調整の規定を置かずに、非親権者は親権を行使することができないとしていることから、非親権者の養育権を不当に侵害する。

b　親は子に対する養育権を有するところ、１５歳未満の者を養子とする縁組に関する規定を定めた民法７９７条１項、２項及び関連する最高裁判例によれば、養子となる者が１５歳未満であるときには、親権者の代諾によって縁組をすることができる一方、監護者ではない非親権者は縁組について同意をする権利を持たず、その意思によることなく親権者変更の申立てをする機会を失ってしまうのであり、監護者ではない非親権者の養育権を不当に侵害する。

c　親は子に対する養育権を有するところ、面会交流や子の監護者の指定に関する民法７６６条（類推適用も含む。）の規定は、非監護親・非親権者への配慮を欠くものであり、非親権者の養育権を不当に侵害する。

d　このように、非婚時単独親権制として規律される現行の法制度は、裁判所が不適切な運用をする原因となる点においても、非親権者及び非監護親の養育権を侵害するものである。

(ｳ) 上記(ｲ)の養育権侵害が憲法１３条に違反すること

a　非婚時単独親権制の立法目的が正当ではないこと

被告は、現行の非婚時単独親権制の目的を、子の利益の確保及び両性の本質的平等を図ることにあると主張する。

しかしながら、被告の主張する「子の利益の確保」とは、親権の行使に関する合意が適時適切に得られないおそれを避けることにあると解されるが、このおそれが現実化して子が不利益を受けることがあるのは、父母の意見が一致しない場合における規律を用意しないことが

原因であるにすぎない。また、上記(イ)において主張したとおり、非婚の父母においては、代諾による養子縁組のような子の身分にかかる重大な決定がされる場合でも、親権者でも監護者でもないときは何ら関与することができないなど、子の福祉よりも慎重熟慮を図らずに適時適切に親権を行うことを優先させているといえるから、このような立法目的は正当とはいえない。そして、諸外国の立法例をみれば、父母が適時適切に親権を行うことができるか否かは、親権が父母に共同して帰属するか否かの問題によるものではないことが分かる。したがって、非婚時単独親権制の目的として「子の利益の確保」を据えることは正当ではない。

また、現行法の非婚時単独親権制においては、本来的に養育権を有している親の一方が、親としての能力や資質を全く問題にされることなく子の養育に関する決定権者から除外されるものであり、「両性の本質的平等」を達成するものではない。

b　立法目的との関係で非婚時単独親権制が合理性を欠くこと

仮に、立法目的が子の利益の確保及び両性の本質的平等を図ることであるとしても、非婚時単独親権制は、目的達成のための合理性を欠く制度である。

すなわち、非婚時単独親権制の下においては、子の監護養育に関する父母の意見が一致せず離婚に至る場合もあり、離婚が成立するまでに相当の時間を要することを踏まえると、父母の間で適時に親権を行うことは期待できず、さらに、非婚時単独親権制の下においては、親権の帰属についての父母の対立を生み、増長させる効果があることは論を待たないから、結果として、子は、成長するまでの過程のほとんどを、親権の帰属も決まらない父母の対立状態で過ごすことも少なくない。

また、非婚の父母においては、一律に、共同して親権を行えないこととされているが、これは、父母が法律婚の関係にないということから、父母の協力関係が存しないであろうという、生活等の実態を類型的に推測するとの立場に依拠するものであり、乱暴な議論であって合理性は見出せない。

さらに、戦前の民法（昭和２２年法律第２２２号による改正前の明治３１年法律第９号。以下「明治民法」という。）においては、父の親権に服するとされていたところ、憲法の改正に伴う民法の改正において、家制度の打破と両性の本質的平等の達成が目指された。しかしながら、この改正において、父母間の意見調整の方法についての立法の必要性が認識されたにもかかわらず、かかる方法についての立法が現在においてもされていないことは、非婚時単独親権制の不合理性を基礎付けるものである。

イ　憲法１４条１項違反について

(ｱ) 差別の存在について

本件各規定は、法律婚の関係にある父母と非婚の父母との間に、次のような差別を生じさせている。すなわち、法律婚の関係にある父母は、原則として共同して親権を行うこととされており、その意に反して親権を喪失又は停止される場合は、親権喪失又は停止の審判に限られる一方、非婚の父母は、その一方だけが親権を行うこととされる。

そして、上記差別は、父母が法律婚の関係にあるか否かという「社会的身分」によって、親権の帰属につき区別を設けるものである。

(ｲ) 上記(ｱ)の差別が憲法１４条１項に違反すること

前記ア(ｳ)において述べた各要素に照らせば、上記(ｱ)の差別が事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づくものではないことは明らかである。

加えて、上記(ｱ)の不合理な差別によって侵害を受ける者は、取扱い

において区別を受ける片側の身分・地位にある者にとどまらないことがある。非婚時単独親権制の下においては、自らの「養育権」が他方の親により侵害された親は、適切にこれを回復する手段を持たないが、これは、根本的にみて、国が全ての親に「養育権」を認めていないことの現れでもある。

したがって、上記(ア)の差別は、憲法１４条１項に違反する。

ウ　立法不作為について

我が国においては、司法に対し、父母間の「養育権」を調整する判断基準や仕組みが法律で与えられておらず、父母間の養育権に関して適切に調整することができないところ、この点について、立法上の手当てをすべき必要性があった。憲法の改正に伴って改正された民法が施行された当時は、父が子の監護・養育についての決定権を有する実態があることを前提に、非婚時単独親権制とすることも事務処理上の理由からやむを得なかったが、両性が子育てに関与するべき時代となり、遅くとも離婚後に母が親権を行う家庭の割合が父が親権を行う家庭の割合を超えた昭和４１年には、非婚時単独親権制につき立法上の手当てをすべき必要性があった。

しかしながら、国は、非婚時単独親権制が、憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に反することが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠ってきた。したがって、かかる立法不作為は、国賠法１条１項所定の「違法」を構成する。

(被告の主張)

ア　憲法１３条違反について

(ア)　「養育権」が憲法１３条に基づき保障された権利ではないこと

原告らが主張する「養育権」の具体的な内容や親権との関係は、判然

としない。また、親権は、親の職分や社会的責務であると理解されており、基本的人権であることを前提とした権利であるとはいえない。

したがって、「養育権」が憲法１３条に基づき保障された基本的人権であるとはいえない。

(イ) 現行法の規定が憲法１３条に違反しないこと

a 法律婚の関係にある父母について

民法の関連する諸規定をみれば、親権制度は、子の利益の確保を重視していることが明らかである。また、同法は、法律婚の関係にある父母について、嫡出推定の規定を設け（民法７７２条）、同居協力扶助義務を負わせていること（同法７５２条、７６０条）などからすれば、法律婚の関係にある父母は、共同生活を営むなどして相互に協力扶助しながら、夫婦間に出生した子を育てる関係にあるとともに、実際上も、夫婦及び子が同居する等、相互に協力して子の養育に関与し、慎重熟慮の上、子の養育に関する事項に必要な判断を適時適切に行うことを期待することができる一般的な状況にあるものということができる。

また、明治民法においては、父の単独親権に服することが原則とされていたが、戦後の同改正により、両性の本質的平等という基本原則に基づき、父母が共同して親権を行使するものとされた。

以上のとおり、民法８１８条３項本文は、両性の本質的平等という基本原則の下、子の利益を確保することを目的としており、父母の双方に親権を認めて子の養育に関与させることが子の利益に資するといえるから、法律婚の関係にある父母について共同親権を認めることは、上記立法目的との関係で合理性を有することは明らかである。

b 法律婚の関係にない父母について

前記ａのとおり、民法において、親権制度が子の利益の確保を重視

していることからすれば、法律婚の関係にない父母について単独で親権を行使することを定めることの立法目的も同様に、子の利益の確保にあると考えられる。そして、明治民法においては、父の親権に服すると解されていたところ、昭和２２年法律第２２２号による改正により、父母の協議又は協議に代わる審判によって子の親権者を定めることとされたものであり、上記立法の目的は両性の本質的平等にもある。

そして、法律婚の関係にない父母においては、同居して共同生活を営むなどして互いに協力扶助しながら子を育てるべき法律関係にはない。また、事実婚の関係から単に子を設けたにすぎない男女まで多様であり、特に離婚後の父母は別居することが通常であって父母間の関係が良好ではないことからすると、一般的に、父母の双方が同居するなどして良好な関係を保ちつつ協力して子の養育に関与し、慎重熟慮の上、子の養育に関する事項に必要な判断を適時適切に行うことを期待することができるという状況にあるとはいえず、かえって子の利益が害されるおそれがある。更に、法律婚の関係にない父母について一定の場合に共同して親権を行使するとした場合、父母の関係性が多様である上、外部からその関係性が明確でないことも踏まえれば、いかなる関係の場合に共同親権とすることが相当か、共同親権とする基準として明確か、また共同親権とした場合に子の利益が害されるおそれがないかといった問題が生じると考えられる。

以上のとおり、民法の諸規定は、両性の本質的平等という基本原則の下、子の利益を確保することを目的としており、父母の一方を親権者とすることにより、子の監護に関わる事項について適時に適切な決定がされることになり、子の利益につながるといえるから、法律婚の関係にない父母について単独で親権を行使するとの規定が上記立法目的との関係で合理性を有することは明らかである。

イ　憲法１４条１項違反について

(ｱ)　憲法１４条１項が規定する法の下の平等とは、個人と個人の間の平等をいい、同項が禁止する不合理な差別も、個人と他の個人との間の不合理な差別をいうものと解される。原告らは、法令上の区別として「法律婚の関係にある父母」との人的関係と「非婚の父母」との人的関係との間の差異について述べるところ、これが憲法１４条１項の禁止する不合理な差別に該当し得ること及びその理由については明らかにされていない。

(ｲ)　仮に原告らが個人を主体とする法令上の区別について主張するものと解したとしても、法律婚の関係にある父母とそれ以外の父母とでは、その置かれている状況が法律上も事実上も異なるから、親権について区別を設ける本件各規定には合理性がある（前記ア(ｲ)参照）。

また、現行法においても、親権の有無にかかわらず、法律上、親子であることに変わりがなく、親は子に対する扶養義務を負い、子は扶養を受け得るものであり、子と同居していない親でも、監護に要する費用について、少なくとも抽象的な支払義務は原則として負っているものと解される。さらに、たとえ父母の一方しか親権を有していない状態であっても、父母が相互に協力し合って養育に関与することが現行法上禁止されるものでもない。仮に、父母が婚姻中であるか否かを問わず、上記のような父母間の協力が見込めない場合も含めて父母双方が親権を有することとすると、親権行使に関する父母の合意が適時適切に得られないおそれがあり、子の利益の確保に重大な支障が生じることが想定されるものであり、このような事態を防止するという点でも、本件各規定は合理性を有している。

ウ　立法不作為について

本件各規定は、裁判所が後見的立場から親権者としての適格性を吟味し、

その一方を親権者と定めることで、子に関する事項について適時に適切な決定がされ、子の利益を保護することにつながるものであり、十分な合理性を有するものである。

そして、原告らのいう「養育権」を保障する立法が一般的な意味で子の福祉を促進する場合が仮にあり得るとしても、具体的な制度設計はなお明らかとはいえない上、その導入のデメリットや、現行の調停・審判手続や民事執行手続との整合性を含め多くの検討を要することからすれば、我が国の現行制度が不合理とはいえない現状にあって、原告らが主張する共同親権者たる父母の「養育権」を保障する法整備をしないことが、憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反するものであることが明白であるとはいえない。

したがって、被告が原告らの主張する所要の立法をしないことは、国賠法１条１項所定の「違法」を構成しない。

(2) 争点２（損害の発生及びその数額）について

（原告らの主張）

原告らは、子を養育する意思を有するにもかかわらず、民法の諸規定に係る立法不作為によって、幼い子と突然会えなくなったままとなって行方が知れなくなったり、公的機関において親として扱われることなく傷ついたり、親子としての自然な養育関係とはほど遠い状態に置かれたりしている。原告らは、自らの人生において大事なものを奪われるという精神的苦痛を被っており、その被害は甚大で回復困難である。

原告らの上記苦痛を慰謝するための慰謝料は、１００万円（本件訴訟係属中に死亡した[redacted]の訴訟承継人である原告[redacted]及び[redacted]については、それぞれ５０万円）を下らない。

（被告の主張）

不知ないし争う。

第３　当裁判所の判断

１　争点１（被告が本件各規定につき改廃しないことが、立法不作為として国賠法１条１項所定の「違法」を構成するか）について

(1) 立法不作為に係る国賠法１条１項所定の「違法」について

国賠法１条１項は、国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個々の国民に対して負担する職務上の法的義務に違反して当該国民に損害を加えたときに、国又は公共団体がこれを賠償する責任を負うことを規定するものであるところ、国会議員の立法行為又は立法不作為が同項の適用上違法となるかどうかは、国会議員の立法過程における行動が個々の国民に対して負う職務上の法的義務に違反したかどうかの問題であり、立法の内容の違憲性の問題とは区別されるべきものである。そして、上記行動についての評価は原則として国民の政治的判断に委ねられるべき事柄であって、仮に当該立法の内容が憲法の規定に違反するものであるとしても、そのゆえに国会議員の立法行為又は立法不作為が直ちに同項の適用上違法の評価を受けるものではない。もっとも、法律の規定が憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反するものであることが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠る場合などにおいては、国会議員の立法過程における行動が上記職務上の法的義務に違反したものとして、例外的に、その立法不作為は、同項の適用上違法の評価を受けることがあるというべきである。そして、国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するための立法措置をとることが必要不可欠であり、それが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠るときは、上記の例外的な場合に当たるものと解するのが相当である（最高裁昭和５３年(オ)第１２４０号同６０年１１月２１日第一小法廷判決・民集３９巻７号１５１２頁、最高裁平成

１３年(行ツ)第８２号、第８３号、同年(行ヒ)第７６号、第７７号同１７年９月１４日大法廷判決・民集５９巻７号２０８７頁、最高裁平成２５年(オ)第１０７９号同２７年１２月１６日大法廷判決・民集６９巻８号２４２７頁、最高裁令和２年(行ツ)第２５５号、同年(行ヒ)第２９０号、第２９１号、第２９２号同４年５月２５日大法廷判決民集７６巻４号７１１頁参照）。

そこで、本件においては、本件各規定が、憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反するものであることが明白であるか否か、国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠っているといえるか否かを検討する。

(2) 憲法１３条に違反するとの主張について

ア　原告らは、本件各規定が、憲法１３条後段に基づき保障される「子を養育する意思と能力を有する親が、子を監護及び養育する権利」（養育権）を、合理的な理由なく制約するものであることが明白であると主張する。

イ　原告らは、非婚時単独親権制、すなわち、法律婚の関係にない父母の一方に親権を認めないことが憲法１３条に違反する旨を主張することから、まず、親権の法的性質について検討する。

民法は、親権の効力として、監護及び教育（同法８２０条）、居所の指定（同法８２１条）、懲戒（同法８２２条）、職業の許可（同法８２３条）、財産の管理及び代表（同法８２４条）などを定めるが、同法８２０条は、「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」と規定して、子の監護及び教育をする権利は、「子の利益のために」行使されなければならないこと及び親権者の義務でもあることを明記している。また、財産管理に関しても、子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には子の同意を要するものとし（同法８２４条但書）、親権者と子との利益が相反する行為には特別代理人の選任請求を義務付ける（同法８２６条１項）など、子の利益に反するおそれのある行

為については親権の効力を制限している。さらに、家庭裁判所は、「親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより『子の利益を著しく害するとき』」は親権喪失の審判（同法８３４条）を、「親権の行使が困難又は不適当であることにより『子の利益を害するとき』」は親権停止の審判（同法８３４条の２）を、「管理権の行使が困難又は不適当であることにより『子の利益を害するとき』は管理権喪失の審判（同法８３５条）をそれぞれできるものとして、親権が適切に行使されないことにより子の利益が害されることを防ぐ制度を設けている。

このように、親権は、専ら子の利益を図るために行使することが予定されている上、権利であると同時に義務であるともされており、これを行使しないという事態は予定されていない。そうすると、親権は、子のための利他的な権限であり、その行使をするか否かについての自由がない特殊な法的地位であるといわざるを得ず、親権者自身の自己実現に資するものであることを考慮しても、憲法上の他の人権とは性質を異にするものというほかない。このような親権の特質によれば、親権が憲法１３条で保障されているものと解することはできない。

また、原告らの主張する養育権という基本的人権を保障することを文言上明らかにした憲法の規定は見当たらず、原告らの主張する養育権という権利の内容を直ちに一義的に特定することは困難である。

以上のとおり、子の監護及び教育をする権利をその中核的な内容とする親権について、憲法１３条で保障されているものと解することはできない上、原告らの主張する「子を養育する意思と能力を有する親が、子を監護及び養育する権利」であるという養育権という権利の外延が明らかでなく、その権利の内容を直ちに一義的に特定することが困難であることからすれば、原告らの主張する養育権が憲法１３条で保障されているものと解することは困難である。

ウ　以上によれば、非婚時単独親権制を定めた本件各規定が養育権を侵害するものとして憲法１３条に反するものとは認められない。

(3) 憲法１４条１項に違反するとの主張について

ア　次に、原告らは、非婚時単独親権制が憲法１４条１項に違反すると主張する。具体的には、法律婚の関係にある父母が原則として共同して親権を行うことができるのに対し、法律婚の関係にない父母は、必ずその一方が単独で親権を行うものとされていることから、原告らのうち法律婚の関係にない父母（離婚をした者及び一度も法律婚の関係にあったことがない者であり、いずれも親権を有しない。）は、法律婚の関係にある父母との間で差別されており（以下「本件差別的取扱い」という。）、本件差別的取扱いが憲法１４条１項に違反する旨を主張するものと解される。

イ　憲法１４条１項は、法の下の平等を定めており、問題となる規定が、事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づくものでない限り、法的な差別的取扱いを禁止する趣旨のものであると解すべきである（最高裁昭和３７年(オ)第１４７２号同３９年５月２７日大法廷判決・民集１８巻４号６７６頁、最高裁昭和４５年(あ)第１３１０号同４８年４月４日大法廷判決・刑集２７巻３号２６５頁等参照）。

ウ　婚姻及び家族に関する事項は、国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断を行うことによって定められるべきものであるから、憲法２４条２項は、婚姻及び家族に関する事項について、具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに、その立法に当たっては、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請、指針を示すことによって、その裁量の限界を画したものといえる（最高裁平成２５年(オ)第１０７

９号同２７年１２月１６日大法廷判決・民集６９巻８号２４２７頁参照）。

また、国家が親権制度を構築するに当たっては、子の利益、特にその人格を発展させ、その手段として教育を受ける環境の整備を求める利益と、子が自律的人格として有する尊厳の確保という要請を調和的に達成することが求められているが、これに加えて、親が子を監護し養育することは、子の最善の利益に従って行動すると推定される親の監督下に置かれることによって、子の利益となるだけでなく、子との親密な人的結合を通じた相互作用により、自らの究極的な価値観を吟味する契機ともなり得る点において、親自身の人格的利益の一部を構成するともいうことができる。そこで、このような人格的利益をいたずらに害することがないようにすべきことも、上記立法裁量の限界を画する一要素であると解される。

そうすると、本件差別的取扱いが憲法１４条１項に反するか否かは、本件差別的取扱いの立法目的に合理的な根拠があり、かつ、その区別の具体的内容が上記の立法目的との関連において合理性を有するものであるかどうかという観点から判断するのが相当である。

エ　前記(2)のとおり、民法は、親権に関し、子の監護及び教育をする権利は、「子の利益のために」行使されなければならないこと及び親権者の義務でもあることを明記し、財産管理についても、子の利益に反するおそれのある行為については親権の効力を制限し、「子の利益を著しく害するとき」又は「子の利益を害するとき」は、親権喪失、親権停止、管理権喪失の審判ができるものとして、専ら子の利益を図るために親権が行使されることを確認している。そして、親権を行う者は、専ら子の利益を図るために、子の日常的な世話に関する側面から、成年に達するまでの長期的な教育方針の決定に関する側面まで、軽重様々の判断を適時

かつ適切にすることが求められる。また、民法は、法律上の夫婦については、嫡出推定の制度を設け、妻が婚姻中に懐胎した子を夫の子と推定するほか（同法７７２条１項）、同居協力扶助義務（同法７５２条）や婚姻費用分担義務（同法７６０条）などを規定して（以下、これらの規定を「夫婦関係諸規定」という。）、法律婚の関係にある父母は、共同生活を営むなどして相互に協力扶助しながら、夫婦間に生まれた子を育てるべき法律関係（以下「本件法律関係」という。）にあるものとしている。

以上の民法の諸規定や親権行使の性質等に照らすと、本件差別的取扱いの趣旨は、夫婦関係諸規定の適用がない法律婚の関係にない父母の関係は多様であり、本件法律関係と同様の関係を類型的に期待することはできず、実際にも、離婚した父母は通常別居し、両名の人間関係も必ずしも良好なものではない状況となることが想定されるものの、そのような父母の人間関係が良好でない場合であっても、法律婚の関係にない父母の一方を親権者として、親権者が適時に適切な判断をすることを可能とし、もって子の利益を確保しようとする点にあると解される。このような本件差別的取扱いの趣旨に照らすと、本件差別的取扱いの立法目的は、親権者が実効的に親権を行使することにより、子の利益を図る点にあるといえ、合理的な根拠に基づくものと認められる。

オ　前記エのとおり、法律婚の関係にある父母については、夫婦関係諸規定が適用され、本件法律関係にあるものとされており、実際上も、夫婦及び子が同居して、相互に協力して子の養育に関与し、子の養育に関する事項に必要な判断を適時かつ適切に行うことが合理的に期待される状況にあるものということができる。他方、子の父母が離婚するに至った場合には、父母が別居し、両名の人間関係も必ずしも良好なものではない状況となることが通常想定されることから、そのような両名が共同で親

権を行使し、子の養育に関する事項を決するものとしたときは、類型的に、両名の間で十分な意思の疎通をし、的確な検討を踏まえて、適時に適切な合意を形成することができず、子の利益を損なうおそれがあるものと認められる。また、法律婚に至らない父母については、父母間・親子間において良好な関係を築いており、法律婚の関係にある父母に合理的に期待される状況と同様の状況にある者から、父母の関係が破綻し、日常的なコミュニケーションが図れない者まで、多様な関係性が想定されるところ、夫婦関係諸規定の適用がなく、本件法律関係と同様の関係を類型的に期待することはできないから、そのような父母が共同で親権を行使し、子の養育に関する事項を決するものとしたときは、両名の間で十分な意思の疎通をし、的確な検討を踏まえて、適時に適切な合意を形成することを類型的に期待することはできない。そこで、親権者が適時に適切な判断をすることができず、子の利益が損なわれる事態を回避するために、法律婚の関係にある父母は原則として共同して親権を行うことができるとする一方、法律婚の関係にない父母は必ずその一方が単独で親権を行うものとする本件差別的取扱いの内容は、実効的な親権の行使による子の利益の確保という立法目的との関連において合理性を有するものと認められる。

たしかに、前記ウのとおり、親が子を監護し養育することは、親自身の人格的な利益の一部を構成し、このことは、法律婚の関係にない父母についても変わらないから、法律婚の関係にない父母が子の養育のためにその関係性を一定の範囲で維持し、父母のいずれもが子の養育に関与し続けることができるようにすることが、子にとっても、法律婚の関係にない父母にとっても望ましいと考えられるところ、法律婚の関係にない父母の一方にのみ親権を認めたとしても、父母間にこのような関係性が維持されている場合には、非親権者である親の人格的な利益の制約は限

定的なものに止まるものと考えられる。他方、法律婚の関係にない父母において、このような関係性が維持できない場合に、共同して親権を行うものとすると、父母の一方からの同意が適時に得られないことにより適時に親権を行使することが妨げられたり、同意が得られないことにより親権を行うこと自体ができないといった事態が生じ、子の利益が損なわれるおそれがあるといわざるを得ない。そうすると、本件差別的取扱いにより、法律婚の関係にない父母の一方は親権者となることができず、その人格的な利益が制約されることがあり得るとしても、子の利益を確保するためにやむを得ないものであって、法律婚の関係にない父母の一方の人格的な利益をいたずらに害するものではないというべきである。

カ　以上によると、本件差別的取扱いは、事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づくものであって、憲法１４条１項に違反しない。

キ　原告らは、民法が、法律婚の関係にない父母の法律上又は事実上の配偶者であった親権者が、自らの監護する子につき代諾による養子縁組を行うなど重大な決断を行うに際して、非監護親の関与を排除することにより慎重熟慮を図らずに適時適切に親権を行うことを優先させていることや、諸外国において、我が国と異なり、法律婚の関係にない父母にも共同して親権を行うことを認める立法例がみられることなどから、本件差別的取扱いの立法目的として「子の利益の確保」を措定することは正当ではないと主張し、これに沿う証拠を提出する（甲４８、[redacted]）。

たしかに、民法第四編親族のうち、第四章親権ではなく、第三章親子第二節養子に設けられた民法７９７条１項は、養子となる者が１５歳未満であるときの代諾権者を法定代理人とし、この法定代理人には親権者も含まれるものの、同条２項は、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときはその同意を得なければならないものとして、親権者ではない監護者にも養子縁組が子の利益に合致するかどうか

の判断の機会を与え、親権者のみの意思で子の監護に関する父母の合意が変更されるのを防止することとしている。このように、同条は、１５歳未満の者を養子とする縁組という具体的局面における関係者の利益状況を踏まえて、所要の手続を定めたものと認められ、同条の規定内容をもって、親権の帰属に係る本件差別的取扱いの立法目的の認定が左右されるものとは認められないし、本件差別的取扱いの立法目的が、親権者が実効的に親権を行使することにより、子の利益を図る点にあるという前記エの認定と矛盾するものとも認められない。

また、諸外国において、法律婚の関係にない父母にも共同して親権を行うことを認める立法例がみられることは、法律婚の関係にない父母と親権との関係については、本件差別的取扱いとは異なる立法政策があり得るものであり、国民的な合意が形成されれば本件差別的取扱いを変更することも考えられることを示唆するものではあるものの、前記エのとおり、本件差別的取扱いの立法目的が、親権者が実効的に親権を行使することにより、子の利益を図る点にあることと矛盾するものとはいえないし、前記オのとおり、本件差別的取扱いの内容が、立法目的との関連において合理性を有することと直ちに矛盾するものということもできない。

ク　原告らは、仮に本件差別的取扱いが「子の利益の確保」を意図して立法されているものであるとしても、子の監護又は養育についての意見が一致しない父母の下においては、父母が意思決定のために離婚をすることとなると相当の時間を要すること、子は対立状態にある父母のもとで成長するまでの過程のほとんどを過ごすことになることなどから、本件差別的取扱いは上記目的との関係で合理性を欠く制度であるとも主張する。

しかし、仮に離婚後の父母にも共同親権を認める制度を採ったとしても、別居することが通常である離婚後の父母のいずれが子と同居して監護を行うのかが争われ得るのであるから、離婚の条件をめぐる交渉が有意に

短縮するかは定かではないし、原告らが指摘する子に対する悪影響は、親権制度につきいかなる立法をするかによらず、高葛藤状態にある父母の下で成長期を過ごす子には一般的に発生し得る事態であると解されるから、本件差別的取扱いが不合理であるということはできない。

ケ　原告らは、本件差別的取扱いは、父母が法律婚の関係にあるか否かによって、生活等の実態を類型的に推測するとの立場に依拠するものであり、不合理であると主張する。

しかし、本件差別的取扱いが制定されて以降の家族の在り方に関する社会状況等の変化を踏まえ、立法論としては、父母が法律婚の関係にあるか否かを基準とする本件差別的取扱いを見直すことの当否を含め議論の余地があり得るとしても、父母が法律婚の関係にあるか否かによって、夫婦関係諸規定の適用の有無が異なり、本件法律関係又はこれと同様の関係を類型的に期待することができるか否かが異なることからすると、実効的な親権の行使による子の利益の確保の観点から、父母が法律婚の関係にあるか否かを基準として、親権の帰属の在り方を異ならせることにはなお合理性があるということができる。

コ　原告らは、明治民法の改正において、父母間の意見調整の方法についての立法の必要性が認識されたにもかかわらず、父母間の意見調整の方法についての立法が現在においてもされていないことは、本件差別的取扱いの不合理性を基礎付けるものと主張する。

しかし、現行法においても、婚姻中の父母について親権の共同行使が事実上困難であるような場合には、父母の一方は、民法７６６条の類推適用により、家庭裁判所に対し、子の監護権者を指定するための調停・審判を申し立てることができ、父母の一方による親権行使が子の利益を侵害するものである場合には、親権停止・親権喪失等の申立てを行うことができるし、婚姻中の父母の意見が一致しない場合を直接規律する定め

を欠くことが、父母が法律婚の関係にあるか否かを基準として親権の帰属を定める本件差別的取扱いの合理性を失わせるものと認めることはできないから、原告らの主張は理由がない。

サ　原告らは、現行の親権制度が子の成長・発育や家庭環境を悪化させるものと主張し、これに沿う証拠として、父母の一方が他方と別居する場合における子の成長等に関する研究をした[redacted]の陳述書及び研究結果（甲６１、６２）並びに同人の証言がある。

しかし、同人の研究によっても、現行の親権制度が子の成長・発育や家庭環境の悪化に及ぼす因果関係は必ずしも明らかではなく、原告らの主張は理由がない。

シ　なお、原告らは、父母の間に生じる子の養育に関する意見の対立を調整する仕組みを一切用意しないという意味において、法律婚の関係にある父母を規律する仕組みも含めた非婚時単独親権制そのものが不合理な差別であるとも主張する。しかし、かかる主張は、法律婚の関係にある父母と法律婚の関係にない父母との間の本件差別的取扱いとは異なる対立項を主張するものと解されるが、いかなる差別的取扱いを主張するものかが不明瞭であり、これにより現行の親権制度が憲法１４条１項に違反するものとは認められない。

２　小括

以上によれば、現行の親権制度が憲法１３条又は１４条１項に違反するとの原告らの主張は、いずれも採用することができない。

第４　結論

以上によれば、原告らの請求は、その余の点について判断するまでもなく、いずれも理由がないからこれらを棄却することとし、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第４３部

裁判長裁判官 古庄 研[redacted]

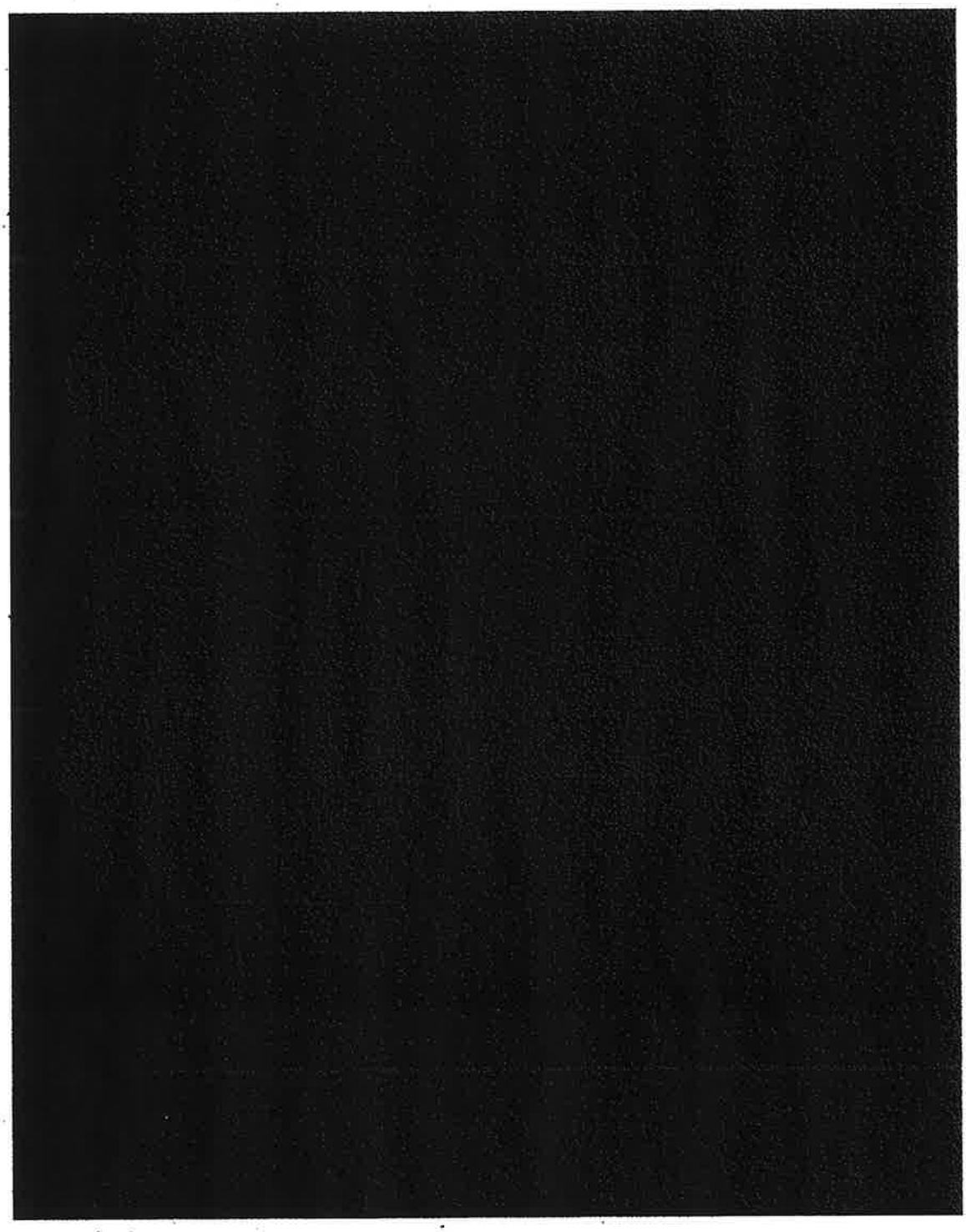
裁判官 石原 拓[redacted]

裁判官伊藤康博は、転補につき、署名押印することができない。

裁判長裁判官 古庄 研[redacted]

（別紙）

当事者目録



[redacted]

東京都千代田区霞が関１－１－１

被　　告　　国

同代表者法務大臣　　齋　藤　　健

同指定代理人　[redacted]

同

同

同

同

同

同

同

同

以　上

（別紙）

請求目録

1　被告は、原告[redacted]に対し、１００万円及びこれに対する令和元年１２月２６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

2　被告は、原告[redacted]に対し、１００万円及びこれに対する令和元年１２月２６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

3　被告は、原告[redacted]に対し、１００万円及びこれに対する令和元年１２月２６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

4　被告は、原告[redacted]に対し、１００万円及びこれに対する令和元年１２月２６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

5　被告は、原告[redacted]に対し、１００万円及びこれに対する令和元年１２月２６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

6　被告は、原告[redacted]に対し、１００万円及びこれに対する令和元年１２月２６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

7　被告は、原告[redacted]に対し、１００万円及びこれに対する令和元年１２月２６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

8　被告は、原告[redacted]に対し、５０万円及びこれに対する令和元年１２月２６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

9　被告は、原告[redacted]に対し、５０万円及びこれに対する令和元年１２月２６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

10　被告は、原告[redacted]に対し、１００万円及びこれに対する令和元年１２月２６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

11　被告は、原告[redacted]に対し、１００万円及びこれに対する令和元年１２月２６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

12　被告は、原告[redacted]に対し、１００万円及びこれに対する令和元年１２月２６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

以　上

東京 22-009518

これは正本である。

令和５年６月22日

東京地方裁判所民事第４３部

裁判所書記官　川　上　陽　子

[redacted]

書記官送達
令和6年1月25日受領　印 [redacted]

乙第5号証

令和6年1月25日判決言渡　同日原本領収　裁判所書記官

令和[redacted]年（[redacted]）第[redacted]号　損害賠償請求控訴事件

（原審・東京地方裁判所令和[redacted]年（[redacted]）第[redacted]号）

口頭弁論終結の日　令和5年11月2日

判　　決

当事者の表示　別紙当事者目録記載のとおり

主　　文

1　本件控訴をいずれも棄却する。

2　控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実及び理由

第1　控訴の趣旨

別紙控訴の趣旨目録記載のとおり

第2　事案の概要（略語は、特に断りのない限り、原判決の例による。以下同じ。）

1　本件は、その子と別居するなどしている控訴人らが、被控訴人が養育権を保障する法制度を整備しないことが憲法13条又は14条1項に違反するとした上で、被控訴人が正当な理由なく長期にわたってその立法措置を怠っているために、精神的損害を被ったとして、被控訴人に対し、国賠法1条1項に基づき、原判決別紙請求目録記載の各損害賠償金及びこれに対する不法行為の後の日である令和元年12月26日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

原審は、控訴人らの請求をいずれも棄却したところ、控訴人らは、これを不服として控訴した。

2　前提事実、争点及び当事者の主張は、後記3のとおり当審における控訴人らの主張を付加するほかは、原判決の「事実及び理由」中の第2の2ないし4に記載のとおりであるから、これを引用する。ただし、原判決3頁19行目から20行目にかけての「この制度全体」を「本件各規定を中心として規律されるこの制度全体」

に改める。

3　当審における控訴人らの主張

(1)　原判決は、親権の人権性を論じてこれを否定し、親権が人権でないことを養育権が憲法上の権利でないことの理由としているが、養育権は、具体的な法制度以前に存在する自然権であり、その人権性は現行民法が規定する具体的な法的地位である親権の人権性とは関係がない。親権の人権性判断は、原告の主張する養育権の人権性判断の前提でもない。

結局、原判決は、控訴人らの主張する養育権の外延が明らかでないこと、その権利の内容が具体的に特定できないことだけを理由に、養育権の人権性を否定していることになるが、人権性の判断において、そのような要件は存在せず、「外延」や「一義性」によって人権の範囲自体を限定する議論自体が的外れである。例えば、基本的人権である表現の自由も、憲法１３条で保障されるとされるプライバシー権もその概念には広い幅があり、一義的とは言い難く、外延は極めて曖昧である。親が子を養育するという行為自体は誰もが理解できるものであり、これらの人権に比しても、容易に理解しやすい。養育権の人権性は、端的に、親が子を養育する行為が親の人格的生存に関連する利益であるか否かで判断すべきである。

(2)　人格的利益を制約する立法の違憲審査については、立法目的に合理的な根拠があるか、具体的内容が上記の立法目的との関連性において合理性を有するものであるかどうかのそれぞれの判断において、その内実を厳密に吟味すべきである。

ア　立法目的に合理性がないこと

戦後、日本国憲法が施行され、家制度の打破と両性の本質的平等が目指されたものの、我が国の当時の実態として子の養育を家や氏と結び付ける実態や父親が事実上決定する実態があり、これに追従する意識や時間的制約の中で、立法における議論が煮詰まらず、事務上の便宜のために、父母間の意見の調整規定を欠き、非婚の場合を一律に単独親権とする現行法が立法された。この立法過程において、子の福祉実現の議論や両性の平等実現の議論はどこにもなく、また、人権制約とトレード

オフの関係になるものとして子の利益が議論された形跡は一切ない。すなわち、本件各規定の立法目的は、事務上の便宜にあり、子の利益を図る点にあるのではない。

イ　手段に合理性がないこと

仮に本件各規定に「法律婚の関係にない父母の一方を親権者として、親権者が適時に適正な判断をすることを可能とし、もって子の利益を確保しようとする」との立法目的があると措定しても、民法７５２条等の夫婦関係諸規定が婚姻中の父母の間で十分に機能していない現行法の下では、たとえ婚姻中の共同親権の状態であっても、他方の親の事実行為の前では、親としての対等な地位を失うことになっているのだから、真に適時・適切な判断による子の利益の確保という機能は果たされていない。したがって、父母の地位の調整規定が整備されていない現行法の下では、本件各規定には目的達成の手段としての合理性がない。

原判決は、法律婚の関係にない父母である場合は、子の養育に関する事項について十分な意思を疎通し、的確な検討を踏まえて、適時に適切な合意を形成することが類型的に期待できないとしているが、そのような類型論により非婚の父母のみを一律単独親権とするのは、典型的な不当差別であり合理性がない。

親権は子の利益のために行使されるものであり、子にとっては父母がそれぞれ親としての責務を果たし親権を行使する状況が基本的に望ましいことに照らすと、親子の具体的状況や父母間の具体的状況や意思に関係なく、非婚である点のみをもって一律に子が父母の一方から養育を受ける利益を奪う本件各規定は、親にとっても子にとっても過度に広汎なものであり、合理性がない。

第３　当裁判所の判断

１　当裁判所も、控訴人らの請求をいずれも棄却すべきと判断するものであり、その理由は、後記２のとおり原判決の補正（当審における控訴人らの主張に対する判断も含む。）をし、後記３のとおり当審における控訴人らの主張に対する判断を加える他は、原判決の「事実及び理由」中の第３に記載のとおりであるから、これを引用する。

２　原判決の補正

原判決１３頁８行目の「国会が正当な理由なく」を「これが明白である場合に国会が正当な理由なく」に、１５頁４行目「次に」から７行目「ことから」までを「控訴人らは、本件各規定の定める非婚時単独親権制においては」に、９行目から１０行目にかけての「法律婚の関係にある父母」を「共同親権を行うことができる法律婚の関係にある父母」にそれぞれ改め、１１行目から１２行目にかけての「ものと解される」を削り、１６頁１０行目から１１行目にかけての「人格的利益の一部を構成するともいうことができる」を「重要な利益であることは否定できない」に、同行目の「人格的利益」を「親の利益」に、１７頁１１行目の「類型的」を「一般的」に、２４行目から２５行目にかけての「子の父母が離婚するに至った場合には、父母が別居し」を「離婚するに至った父母については、別居しているだけでなく」にそれぞれ改め、同行目の「両名の」及び「必ずしも」、２６行目の「状況となる」並びに１８頁１行目から２行目にかけての「類型的に、」をいずれも削り、１２行目の「類型的」を「一般的」に、２０行目の「人格的な利益の一部を構成し」を「重要な利益であり」にそれぞれ改め、２６行目、１９頁８行目及び１０行目の各「人格的な」をいずれも削り、２０頁１７行目末尾の次に行を改めて「　さらに、控訴人らは、本件各規定の立法過程において子の利益が議論された形跡はなく、事務上の便宜から非婚時単独親権制が立法されたと主張するが、証拠（甲３４）によれば、本件各規定の立法過程において、子の利益の観点から離婚時には単独親権とすべきことが積極的に議論されていたことが認められることから、控訴人らの上記主張はあたらない。」を加え、２２頁１９行目冒頭から２１行目末尾までを次のとおりに改める。

「　(4)　以上によれば、本件各規定について、憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反するものであることが明白であるとは認められないから、その改廃等の立法措置の不作為については、国賠法１条１項の適用上違法の評価を受けない。

２　以上によれば、控訴人らの請求は、その余の点について判断するまでもなく、いずれも理由がない。」

３　当審における控訴人らの主張に対する判断

(1)　控訴人らは、親がその子を監護及び養育する権利である養育権が憲法１３条により保障されているとした上で、本件各規定はこの養育権を侵害するものであり、憲法１３条に違反する旨を主張する。

しかしながら、控訴人らは、控訴人らが主張する養育権の外延が明らかでないことを原判決により明確に指摘されているにもかかわらず、依然として「子を養育する意思と能力を有する親が、子を監護及び養育する権利」というだけで、その外延を明らかにできない。

子の監護及び養育といっても、その具体的内容については、子と同居し生活を共にすること、子に毎日の食事を与え、睡眠をとらせること、子に教育を受けさせること、子の生活のために必要な費用を負担すること、子の日々の生活に必要な事項を決定すること、子の進学先や医療方針を選択決定すること、子の財産を管理することなど、幅広く多様なものが想定できるところ、一般的に子の監護及び養育といった場合の中核部分が何であるのかについて世間一般の共通認識があるものとは解されない。控訴人らの主張内容から帰納的に考察すれば、非婚時単独親権制によって侵害が観念されることとなる非親権者の利益一般を指しているようにも解されるが、そのように理解をしてみてもその具体的な範囲が直ちに明らかになるものではないし、他方で、控訴人らが、父母が婚姻中であっても子の監護及び養育について父母間の意見の調整規定がないために養育権が侵害されているとも主張していることを考慮すれば、養育権がいかなる権利であるかについての控訴人らの主張は判然としないといわざるを得ない。そうすると、控訴人らが主張する養育権の外延は明らかでないという他なく、そのような権利が憲法上の権利であるということはできない。

この点について、控訴人らは、表現の自由や憲法１３条で認められるプライバシ

一権もその内容が一義的でなく、その外延が極めて曖昧であるから、外延が曖昧であること等を理由に養育権の人権性を否定することはできない旨を主張するが、人がみだりに公開されることを欲しない私事が何であるかについては社会通念上一定の共通認識が形成されているものと解されるから、プライバシー権の内容が一義的でなく、その外延が極めて曖昧であるなどとはいえず、また、表現の自由についても同様に解されるから、上記主張は当たらない。

しかも、子の監護及び養育は、本来的には子の人格的な生存を確保するために行われるべきものであり、親にとって義務的な側面が強い事柄である。親自身にとっても重要な価値であり、権利的な側面が存在するとしても、その両面は密接に関連して不可分というべきものであり、少なくとも、その権利的な側面（しかもそれは従的な側面である。）のみを取り出して、その性質を論じることは相当でない。子の監護及び養育をすることについて親の利益を認めるとしても、それは他者（子）の利益を考慮することなしに存在することがありえない利益であり、そのような他者に対する義務的側面を併せ持つという点においても、一般的な憲法上の権利と性質を異にするものという他ない。

以上の検討に加えて、子の監護及び養育はけっして今日的な問題ではないにもかかわらず、これに関する親の権利について憲法に明文の規定がないこと、憲法２４条２項は、婚姻及び家族に関する事項について、具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるものとしていることをも踏まえれば、控訴人らの主張する養育権が憲法１３条で保障されているものと解することはできず、本件各規定が憲法１３条に違反するとの控訴人らの主張はその前提を欠くものであり、理由がない。

(2) 以上のほか、当審における控訴人らのその余の主張も、実質的に原審における主張を繰り返すもの又はその前提を欠くものであるなど、前記１及び上記(1)の認定判断を左右するものに足るものとは認められない。

４ 結論

以上によれば、控訴人らの請求をいずれも棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所第１６民事部

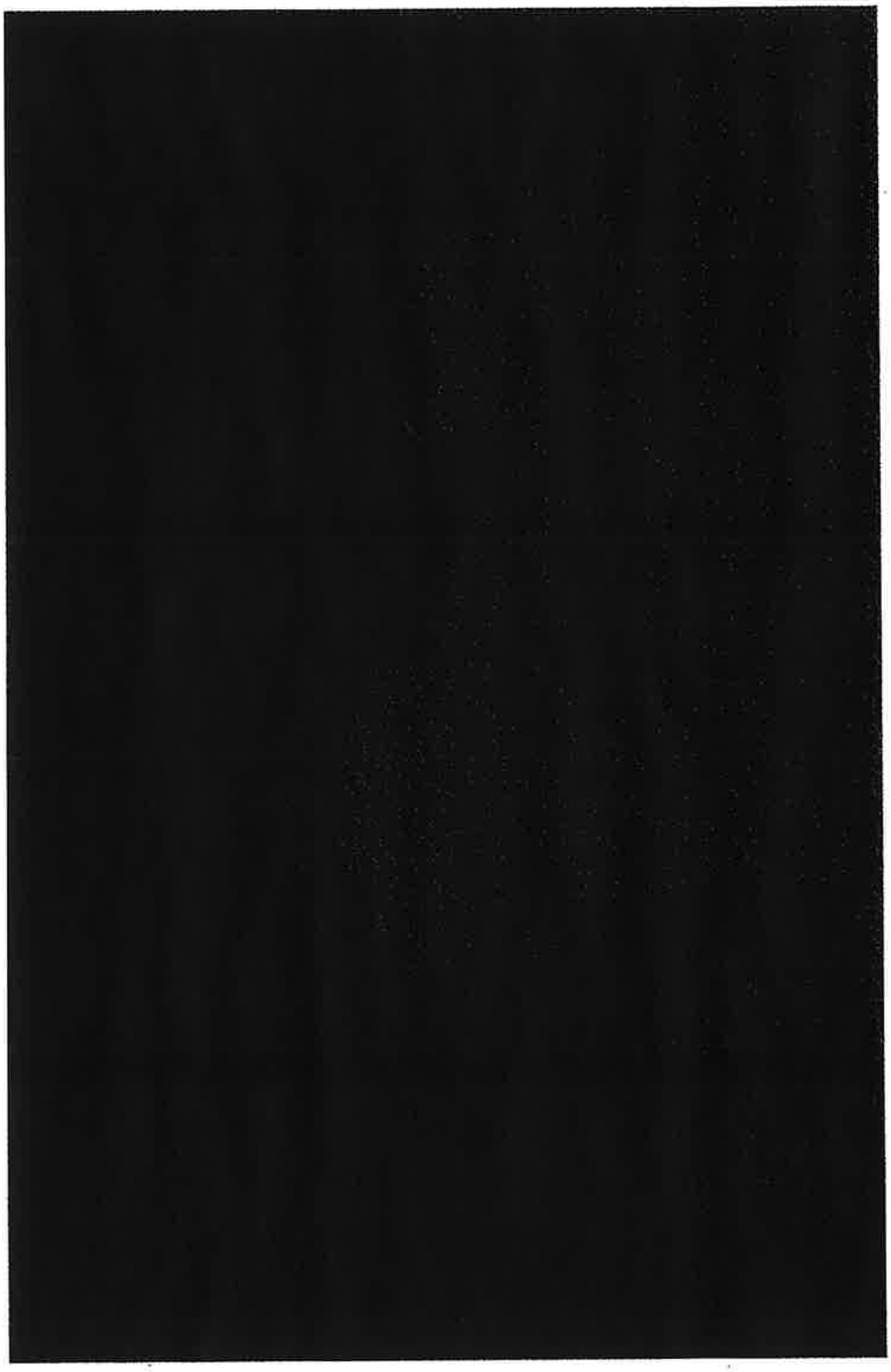
裁判長裁判官　土田昭彦

裁判官　大寄久

裁判官　園部直子

（別紙）

当事者目録



[redacted]

被控訴人（1審被告） 国

同代表者法務大臣 小泉龍司

同指定代理人 [redacted]

（別紙）

控訴の趣旨目録

１　原判決を取り消す。

２　被控訴人は、控訴人[redacted]に対し、１００万円及びこれに対する令和元年１２月２６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

３　被控訴人は、控訴人[redacted]に対し、１００万円及びこれに対する令和元年１２月２６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

４　被控訴人は、控訴人[redacted]に対し、１００万円及びこれに対する令和元年１２月２６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

５　被控訴人は、控訴人[redacted]に対し、１００万円及びこれに対する令和元年１２月２６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

６　被控訴人は、控訴人[redacted]に対し、１００万円及びこれに対する令和元年１２月２６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

７　被控訴人は、控訴人[redacted]に対し、１００万円及びこれに対する令和元年１２月２６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

８　被控訴人は、控訴人[redacted]に対し、５０万円及びこれに対する令和元年１２月２６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

９　被控訴人は、控訴人[redacted]に対し、５０万円及びこれに対する令和元年１２月２６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

１０　被控訴人は、控訴人[redacted]に対し、１００万円及びこれに対する令和元年１２月２６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

１１　被控訴人は、控訴人[redacted]に対し、１００万円及びこれに対する令和元年１２月２６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

１２　被控訴人は、控訴人[redacted]に対し、１００万円及びこれに対する令和元年１２月２６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

東京(高) 21-001472

これは正本である。

令和６年１月２５日

東京高等裁判所第１６民事部

裁判所書記官　沼　田　慎　平

Q11

父又は母が親の責務等の規定に違反した場合には、どのような効果が生じるか。

A

父母の一方が新民法第817条の12第1項の責務や同条第2項の人格尊重義務や協力義務に違反した場合には、当該父母による親権行使等が不適当であるとして、親権者の指定・変更（新民法第819条第2項及び第5項から第8項まで）や親権喪失・停止（民法第834条及び第834条の2）の裁判の際に、その違反の内容及び程度が考慮される場合があると考えられる。

このほか、濫用的な審判・調停の申立てをすることも、個別具体的な事情によっては、この人格尊重義務や協力義務に違反すると評価される場合がある。家事事件手続法第271条によれば不当な目的でみだりに調停の申立てがされた場合には調停手続をしないものとして事件を終了させることができることとされているが、個別の事案において同条の適用を検討するに当たっても、父母が人格尊重義務や協力義務を負っていることを踏まえた判断をすることが考えられる。

第3章　親権

Q12

親権とは何か。また、親権の性質についての改正の趣旨は何か（新民法第818条第1項関係）。

A

1　親権の内容

親権には、身上監護権（民法第820条から第823条まで）と財産管理権（同法第824条）が含まれると解されている。このうち、身上監護権には、子の身の回りの世話をすることや、子の教育や居所等に関する事項の決定をすることなどが含まれ、財産管理権には、子の財産を管理することや、子を代理して契約を締結することなどが含まれる。

改正法は、このような親権の内容そのものに変更を加えるものではない。

2　親権の性質

親権は、親の権利のみでなく義務としての性質も有し、これを子の利益のために行使しなければならないと解されている。こうしたことを明らかにするため、平成23年の民法改正の際には、民法第820条に「子の利益のために」との文言が追加され、令和4年の民法改正の際には、民法第821条に親権者の監護及び教育における行為規範を示す規定が新設された。

もっとも、旧民法第818条第1項は、成年に達しない子が父母の親権に「服する」と表現していたため、親権が専ら父母の権利（子に対する支配権）であるかのように誤解されているとの懸念が示されていた。

そこで、新民法第818条第1項は、「服する」という表現を改め、親権は、子の利益のために行使しなければならないことを明確化している〈注1〉〈注2〉。

（注1）「親権」という用語に関する議論の経過

「家族法制の見直しに関する中間試案」では、「親権」という用語について、これに代わるより適切な表現があれば、その用語の見直しも含めて検討すべきであるとの考

乙第6号証

From:03 3515 7308　2026/09/18 16:57　#178 P.152/180

Q86　改正後は、家庭裁判所の審判等で定められた親子交流について、どのように履行確保が図られることになるか。

A

1　既存の履行確保手段

親子交流についての定めに関する調停・審判がされたにもかかわらず、父母の一方がこれに応じない場合にその履行を確保する方策としては、改正前から、①民事執行法に基づく強制執行（間接強制）と、②家事事件手続法に基づく履行状況の調査及び履行の勧告の制度があった。

これらの方策は、改正法による改正後においても用いることができる。

2　改正法による履行確保

新民法第817条の12第2項は、父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使又は義務の履行に関し、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならないこととしている。

どのような場合に父母相互の人格尊重義務や協力義務に違反したと評価されるかは、個別具体的な事情に即して判断されるべきであるものの、一般論としては、例えば、父母の協議や家庭裁判所の調停・審判により親子交流についての定めがされたものの、父母の一方が特段の理由なくこれを履行しない場合には、個別具体的な事情によっては、父母相互の人格尊重義務や協力義務に違反すると評価されることがある。そして、父母の一方がこの義務に違反した場合には、親権者の指定・変更（新民法第819条第2項及び第5項から第8項まで）や親権喪失・停止（民法第834条及び第834条の2）の裁判の際に、その違反の内容及び程度が考慮される場合があると考えられる。

Q87　親子交流を親又は子の権利として規定しなかったのはなぜか。

A

親子交流の法的性質をめぐっては、それが権利であると認められるか否かや、仮に権利であるとして親の権利であるか子の権利であるか等について、なお議論が分かれている。そこで、本改正法においては、親子交流を親又は子の権利として規定することはしていない。

もっとも、親子交流の法的性質についていかなる見解を採るにせよ、父母の協議又は審判によって具体的に親子交流の定めがされた場合には、父母間に具体的な権利義務が発生することとなる。そして、その権利の行使又は義務の履行に関して、父母は、子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならないこととなるものと考えられる（新民法第817条の12第2項）。

From:03 3515 7308　2026/09/18 16:57　#178 P.153/180

即時抗告権者（父母以外の親族と子との交流）……157

◇　た行

（養子縁組の）代諾……162
他に適当な方法がないとき……155
担保権実行としての差押え等……111, 121
（考慮要素としての）父と母との関係……38
中絶手術……67, 72
定期金債権……109, 110
同意に代わる許可……163
特定の事項（親権行使者の指定）……73, 74, 98
取決率（養育費・親子交流）……1, 2

◇　な行

日常の行為→監護及び教育に関する日常の行為
ニュートラルフラット……150
認知……61

◇　は行

表見代理……85
附帯決議（衆議院・参議院）……13, 15
附帯決議（平成23年）……5〜7, 30
附帯決議（法制審議会家族法制部会）……6, 7, 18, 20
附帯処分……79, 84, 89, 96, 132, 140, 171
（考慮要素としての）父母と子との関係……38
父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき……41
父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるとき……39, 54
父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための関係府省庁等連絡会議……187
扶養義務……22
扶養的要素……168, 169
法制審議会家族法制部会……5〜7, 9, 11
法定代理（権）……67, 85, 99
法務省令（先取特権）……109
法務省令（法定養育費）……117, 119

◇　ま行

民事執行手続のワンストップ化……128
民法の一部を改正する法律案要綱（平成8年）……170, 173, 174
黙示的な同意……63

◇　や行

養育……21
養育計画……175, 176
養育費不払い解消に向けた検討会議……5
養育費勉強会……5
養子の離縁後にその親権者となるべき者……165

◇　ら行

履行率（養育費・親子交流）……1, 2
離婚後養育講座……175, 176
離婚と子育てに関する世論調査……30
離婚の届書……34〜36

一問一答 令和6年民法等改正
——家族法制の見直し（親権・養育費・親子交流等）

2025年9月10日　初版第1刷発行
2025年10月30日　初版第2刷発行

編著者　北村治樹
発行者　石川雅規

発行所　㈱商事法務
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-6-2
TEL 03-6262-6756・FAX 03-6262-6804〔営業〕
TEL 03-6262-6769〔編集〕
https://www.shojihomu.co.jp/

落丁・乱丁本はお取り替えいたします。　印刷／広研印刷㈱
© 2025 Haruki Kitamura　Printed in Japan
Shojihomu Co., Ltd.
ISBN978-4-7857-3185-4
＊定価はカバーに表示してあります。

JCOPY <出版者著作権管理機構 委託出版物>
本書の無断複製は著作権法上での例外を除き禁じられています。
複製される場合は、そのつど事前に、出版者著作権管理機構
（電話 03-5244-5088、FAX 03-5244-5089、e-mail: info@jcopy.or.jp）
の許諾を得てください。

From:03 3515 7308
2026/09/18 16:57 #178 P.154/180

第７回　子の監護者指定・引渡調停・審判事件の審理

石垣智子
重髙啓

第１　はじめに―子の監護者指定・引渡事件の概要及び事件動向等

１　子の監護者指定・引渡事件の概要等

(1)　概要

民法766条１項は，父母が協議上の離婚をするときは，子の監護をすべき者，父又は母と子との面会及びその他の交流，子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は協議で定め，この場合においては子の利益を最も優先して考慮しなければならないものとし，同条２項は，協議が調わないとき，又は協議することができないときは家庭裁判所がこれらを定める（子の監護に関する処分。家事事件手続法（以下「家事法」という。）39条，別表第二の３の項）ものとしている。

家庭裁判所は，子の監護に関する処分としては，子の監護者の指定のほか，「子の監護について必要な事項」（民法766条１項）として子の引渡しも定め得ると解されており，家事法154条３項も，家庭裁判所は子の引渡し等の給付を命ずることができるとしている。実際にも，現に子を監護していない親（非監護親）から子の監護者指定の申立てがされる場合には，併せて子の引渡しの申立てがされることが通常である。また，家事法157条１項３号は，子の監護に関する処分に係る審判前の保全処分について規定しているところ，後に詳述するとおり，子の監護者指定・引渡事件においては，審判前の保全処分が併せて申し立てられることも多い。

さらに，民法766条は，その文言上，離婚の際の子の監護に関する処分を定めるにとどまるが，婚姻中の夫婦の場合も，民法766条を類推適用して子の監護に関する処分をすることができると解されており[50]，実際にも，家庭裁判所に係属する子の監護者指定・引渡事件の多くは，離婚前の夫婦間における監護権の帰属が未だ定まっていない段階や，いったん監護権の帰属が定められた段階における紛争である。

(2)　人身保護手続等との関係

子の奪い合いをめぐる紛争では，本稿で論ずる子の監護者指定・引渡しと人身保護手続，あるいは民事訴訟手続との関係（棲み分け）が従前から問題とされてきた。もっとも，実情としては，家庭裁判所調査官（以下「家裁調査官」という。）や医師である裁判所技官といった専門的知見を有する職種が置かれている家庭裁判所における家事審判・調停手続が広く活用されているといえるように思われる[51]。

この点に関し，人身保護手続との関係について敷衍すると，まず，離婚前の夫婦間については，最高裁平成５年10月19日第三小法廷判決・民集47巻８号5099頁が，夫婦の一方が他方に対し，人身保護法に基づき共同親権に服する子の引渡しを請求した事案において，拘束の違法性が顕著である（人身保

50　最高裁平成12年５月１日第一小法廷決定・民集54巻５号1607頁は，面会交流についての事例であるが，婚姻関係が破綻して別居状態にある夫婦間において，（平成23年法律第61号による改正前の）民法766条が類推適用されるとした。

51　例えば，離婚時に親権者又は監護者と定められた親から非親権者又は非監護者とされた親に対する子の引渡請求が民事訴訟事項か家事審判事項であるかについては争いがあるが，実務では，家庭裁判所における家事審判・調停手続が活用されている（安倍嘉人・西岡清一郎監修「子どものための法律と実務」119，120頁参照）。

From:03 3515 7308
2026/09/18 16:58 #178 P.155/180
乙第７号証

From:03 3515 7308

10号118頁も，親権又は監護権を有する親の親権の行使又は監護が子の幸福の観点から著しく不当なものでない限り，親権又は監護権を有しない親による拘束の違法性は顕著であると判示しているところである。しかし，このような離婚後の夫婦間における紛争においても，離婚前の夫婦間における紛争と同様，家庭裁判所における調停・審判手続が広く活用されているのが実情ではないかと思われる。[53]

2　事件動向等

以上を踏まえた上で，子の監護者の指定・引渡しに係る審判・調停事件の事件動向について俯瞰する。まず，子の監護に関する処分事件一般が大幅な増加傾向にあることについては，既に第１回の論稿小田正二「家事事件手続法の趣旨と新しい運用の概要（家事審判事件を中心に）」（以下「小田論文」という。）において指摘されている（本誌５頁）ところであり，これは，面会交流調停・審判事件の申立てが激増していることのみならず，[54] 子の監護者指

53　子の奪い合いの場面としては，以上の父母間における紛争のほか，親権者又は監護者である親が第三者に対して子の引渡しを求める場面も想定される。この場合，人身保護請求のほか，第三者が民法766条による当事者間の協議や家庭裁判所の調停等により監護者として定められているのであれば家事審判事項となり得るが，そうでない場合には，親権又は監護権の行使に対する妨害排除の手段として民事訴訟手続による子の引渡請求によることになるとする見解が有力である（阿部徹・島津一郎編「新版注釈民法（22）・親族（２）」（以下「注釈民法」という。）130頁以下，中山直子「第三者に対する子の引渡請求」判例タイムズ1100号180頁，最高裁昭和35年３月15日第三小法廷判決・民集14巻３号430頁等参照）。

54　面会交流事件の新受件数は，平成21年は，調停事件が537件，審判事件が99件であったが，平成26年には調停事件が886件，審判事件が165件と，５年間でいずれも1.6倍以上に増加している（第６回の論稿水野有子・中野晴行「面会交流の調停・審判事件の審理」（以下「水野・中野論文」という。）本誌189頁）。

護規則４条）というためには，拘束している親の監護が子の福祉に反することが明白であることを要するとする，いわゆる明白性の要件の考え方を示し，その補足意見でも家庭裁判所における審判前の保全処分の活用が示唆され，さらに，最高裁平成６年４月26日第三小法廷判決・民集48巻３号992頁が，上記明白性の要件について，①一方の親の親権の行使が家庭裁判所の仮処分又は審判により実質上制限されているのに当該親（拘束者）がこれに従わない場合（審判違反事例）と，②拘束者の子に対する処遇が親権行使という観点からみてもこれを容認することができないような例外的な場合（親権濫用事例）を挙げた。[52] そして，離婚前の夫婦間における紛争においては，上記各最高裁判例の趣旨に沿って，家庭裁判所における子の監護者の指定・引渡しの手続が審判前の保全処分とともに積極的に活用されてきたものといえる。

他方で，離婚後の夫婦間においては，上記明白性の要件の趣旨は及ばないものと考えられ，現に，最高裁平成11年５月25日第三小法廷判決・家月51巻

52　一方，最高裁平成６年７月８日第二小法廷判決・家月47巻５号43頁は，離婚調停において調停委員会の面前でその勧めによってされた合意により，夫婦の一方が他方に対し，期間を限って幼児を預けたが，他方の配偶者が，上記合意に反して約束の期日後も幼児を拘束し，上記幼児の住民票を無断で自己の住所に移転したなどの事実関係の下で，上記拘束に顕著な違法性があるとした。上記最高裁判決は，拘束者が，裁判所が関与した合意に反する明白な手続違反を犯しているということ自体に，人身保護規則４条に規定する拘束の顕著な違法性があると捉えたものと考え得る（最高裁判所判例解説民事篇平成５年度933，934頁注釈10参照）。そのほか，調停手続の遂行過程で当事者の協議により形成された合意に基づき実施された面会交流時に実力を行使して子を連れ去ったという事案につき，上記最高裁判決に沿って人身保護規則４条所定の顕著な違法性があるとした最高裁判例として，最高裁平成11年４月26日第一小法廷判決・判例タイムズ1004号107頁がある。

2026/09/18 16:58 #178 P.156/180

定・引渡事件が増加していることもその一因となっているものといえる。

なお，子の監護に関する処分のうち，東京家庭裁判所本庁（以下「東京家裁」という。）における平成21年から平成26年までの子の監護者指定・引渡事件の新受件数の推移は次のとおりである（平成26年の数値は速報値である。）。

【子の監護者指定】

	調停事件	審判事件
平成21年	69	107
平成22年	124	138
平成23年	148	123
平成24年	145	166
平成25年	190	164
平成26年	177	195

【子の引渡し】

	調停事件	審判事件
平成21年	42	94
平成22年	59	96
平成23年	88	102
平成24年	80	130
平成25年	115	124
平成26年	108	170

以上の新受件数には，調停事件については審判から調停に付された事件（家事法274条１項）が，審判事件については調停不成立により審判に移行した事件（家事法272条４項）がそれぞれ含まれるため，厳密な分析は困難ではあるが，いずれにせよ，全体的な傾向としては子の監護者指定・引渡事件の新受件数は増加傾向にあり，６年間で調停事件は2.5倍以上，審判事件は２倍近くに増加している。また，子の監護者指定・引渡事件では，別居や監護親が子を連れ去った事実経緯等をめぐり当事者が激しい対立下にあったり，

申立人において子の連れ去りや監護状況が子の福祉に反すること等を理由に迅速な処理を求めたりすることもあり，当初から調停手続を選択せず，審判事件として申立てをし，その際に併せて審判前の保全処分事件（子の仮の監護者指定・仮の引渡し）を付随して申し立てることも多いのが特徴である。そして，全国の事件概況から子の監護に係る子の引渡しを命ずる仮処分の新受件数を比べてみると，平成15年度は353件であるのに対し，平成24年度は1045件，平成25年度は973件と，約10年間で３倍近くに増加している。

さらに，平成25年１月に施行された家事法では本案係属要件が緩和され，調停事件が係属していれば審判前の保全処分を申し立てることができるようになった（家事法105条１項，157条１項３号）。そして，東京家裁にも，平成25年以降，子の監護者指定・引渡調停事件の申立てに付随して審判前の保全処分が，数は少ないながら申し立てられている。もっとも，審判前の保全処分について注意すべきは，既済件数の内訳であり，平成24年度は，既済件数934件のうち，認容が176件（約18.8％），却下が144件（約15.4％），取下げが571件（約61.1％），平成25年度は，既済件数1053件のうち，認容が187件（約17.7％），却下が203件（約19.2％），取下げが622件（約59.0％）と，認容率が低くなっている[55]。この点については，後に分析を加える。

以上を前提に，以下では，子の監護者指定・引渡しに係る紛争の中で最も申立てが多い別居中の夫婦間における審判・調停事件を主に念頭に置き，まず子の監護者指定（引渡し）の考慮要素がどのようなものであるのか，裁判例の傾向等を簡単に確認した後（第２），子の監護者指定（引渡し）の審判事件及び調停事件の審理・進行の実情（第３，第４）について論じる。なお，意見にわたる部分は執筆者の私見であることをあらかじめお断りしておく。

55　なお，平成25年度における審判前の保全処分全体の認容率は36.7％である（小田論文（本書６頁）参照）。

From:03 3515 7308　2026/09/18 16:59　#178 P.157/180

第2　子の監護者指定（引渡し）の判断の実情

1　子の監護者指定（引渡し）の考慮要素

民法766条1項は，子の利益を最も優先して考慮しなければならないことを明記しており，子の監護者指定（引渡し）の一般的・抽象的基準が「子の利益」に合致するか否かであることはいうまでもない。[56]

上記「子の利益」に合致するか否かを具体的に判断するに当たっては，従前の監護状況，現在の監護状況や父母の監護能力（健康状態，経済状況，居住・教育環境，監護意欲や子への愛情の程度，監護補助者による援助の可能性等），子の年齢，心身の発育状況，従来の環境への適応状況，環境の変化への適応性，父又は母との親和性，子の意思等，父母の事情や子の事情を実質的に比較考量して父母のいずれが監護者として適格であるかが検討される。[57][58] そして，上記の各事情をもとに比較考量を行う際には，従前から，以下の点が考慮されると解されている。[59]

56　平成23年の民法改正前の民法766条1項には，現行法のような「子の利益」が考慮要素になる旨の明文の規定はなかったが，一般的に子の利益が一般的・抽象的な判断基準になると解されていた（注釈民法123頁以下，中山直子「子の引渡しの判断基準」判例タイムズ1100号182頁，若林昌子「親権者・監護者の判断基準と子の意見表明権」新家族法実務大系第2巻388頁等参照）。

57　注釈民法124頁参照

58　その結果，申立人ではなく相手方が監護者として適格であるとの判断に至った場合には，相手方からの子の監護者指定の申立てがない場合であっても，子の福祉の観点から，相手方を監護者として指定する旨の審判がされる（注釈民法123頁，広島高裁平成19年1月22日決定・家月59巻8号39頁及び東京家裁平成22年5月25日審判・家月62巻12号87頁等参照）。

59　各々に係る裁判例の詳細な分析については，松本哲泓「子の引渡し・監護者指定に関する最近の裁判例の傾向について」（家月63巻9号1頁）を参照されたい。

(1)　乳幼児期[60]における「主たる監護者」による監護について

従前，乳幼児については，母親の存在が情緒的成熟のために不可欠であり，特別の事情がない限り，母親の監護養育に委ねることが子の福祉に合致するとして，母親を優先すべしとする考え方が主張されてきた。実際，アメリカでも10歳くらいまでの子については母親が監護者となるのが子の利益に適うとするTender Years Doctrineという原則が絶対的な基準とされていた時代もあったようである。

しかし，このような考え方は，家庭における父母の役割が多様化した現代においては硬直化した考えであるとの批判もあり，最近では，子の健全な成長・発達のために不可欠である養育者との愛着関係や心理的絆を満たす者は生物学的母や女性に限定されるものではないとの発想から，性別を問わない「主たる監護者」による監護継続の必要性を検討するアプローチに転換されている傾向にあるといえる。すなわち，子の出生以来，主として子を監護養育してきた者の監護実績を実質的に検討し，主たる監護者と子との間に親密な親和関係が形成されているか，他方で，主たる監護者といえる場合であってもその監護態勢や生活環境が顕著に劣っていないか，主たる監護者による監護に看過できない問題があって，それが将来に継続する可能性がないか等が実質的に考慮される傾向にあるといえる。

(2)　監護環境の変化について

従前，監護の継続性の考え方は，監護親の下で子が安定していれば，子の生活環境を変化させることは子の心理的不安定をもたらすとして，これを避けるために監護環境の継続性を重視する考え方であると捉えられていたようである。しかし，このような考え方は，子の奪い合いを助長し，また，その結果を追認しかねないとして非難されてきた。

現在では，監護環境の変化については，出生以来の生育歴全体の中で考慮

60　本稿では，主に1，2歳程度までを想定している。

From:03 3515 7308　2026/09/18 16:59　#178 P.158/180

し，特に子が幼少の場合は，主たる監護者に戻すための環境変化を避けることよりも，主たる監護者との精神的つながりを継続することが重視され，一方で就学後は，監護環境（住居や学校，友人関係等）の継続性がより尊重される傾向にある。

(3) 子の意思について

子の意思については，これを重視することは結論に関する責任を子に負わせることになりかねないこと等から，従来は消極的に考える向きもあったようであるが，次第に，子も自己の意思を表明することができる権利主体であるという考え方が広く受け入れられるようになり，子の意思を検討することの重要性が認識されるようになっている。

そして，家事法152条２項も，子の監護に関する処分の審判（子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判を除く。）をする場合には，15歳以上の子の陳述を聴かなければならないとして，家事審判法下の規律を維持している。また，家事法65条は，家庭裁判所は，子がその結果により影響を受ける家事審判の手続においては，子の陳述の聴取，家裁調査官による調査その他の適切な方法により，子の意思を把握するように努め，審判をするに当たり，子の年齢及び発達の程度に応じて，その意思を考慮しなければならないとも規定しており，同条は，家事法258条１項により，調停手続にも準用されている。

もっとも，実際の事案において，当該子の意思をどのように把握し，また，それをどの程度評価するかについては，当該子の年齢や発達の程度，言語・表現能力の程度，当該子の置かれている現在の立場，これまでの生育歴等を踏まえた上，子の最善の利益という観点からの個別具体的な判断が必要である。とりわけ，子の年齢によっては，子の非言語的表現等をも踏まえた上でその意思を把握することが必要とされる場合もあろうし，当該子の置かれている状況によっては，当該子が表面上表出させる言動だけでなく，子の真意や心情について，前後の事実関係等を丹念に整理しつつ合理的に推論・

分析し，検討する作業が必要となってくる場合もある。そして，このような場面では，家裁調査官による行動科学の知見を活用した事実の調査が有用である。家裁調査官の活用や調査の概要については後で述べる。

(4) 面会交流の許容性について

子は，父母双方と交流することにより人格的成長を遂げることから，婚姻関係が破綻した後も，子が父母双方から愛情を受けていると実感しながら育つことは，子の健全な成長にとって必要であると考えられる。このような観点から，他方の親をどれほど信頼して寛容となれるか，子との面会交流を認めるかといった点も，監護者指定の考慮要素となり得る。

もっとも，面会交流を禁止・制限すべき事由がある場合もある上，別途調停手続等によって解決を図る途もある。そして，子の監護者の指定（引渡し）が，様々な要素を総合的に考慮した上で子の福祉の観点から判断されるものである以上，面会交流を拒否するということだけで監護者としての適格性に欠けるという結論が直ちに帰結されるわけではない。

(5) きょうだい不分離について

きょうだいの心理的な結びつきが強い場合は，きょうだいの分離がきょうだい間に不平等感や亀裂を招くこともあり，同一の親の下で監護されることが望ましいといえる。しかし，きょうだいの不分離は，必ずしも原則として運用されているものではなく，監護状況及びその態勢，子の年齢や意思等の総合的考慮の中で飽くまで一要素として判断されることに注意を要する。

(6) 監護開始の態様について

法律や社会規範を無視するような態様で監護が開始されたことは，監護者としての適格性に疑義が生じる一要素となり得る。例えば，別居後の離婚調停中に，調停委員等からの事前の警告に反して周到な計画の下に実力によって子を奪取した場合や，特段の事情の変更もないのに面会交流に係る約束に違反して子を返さないなど，監護開始の態様の悪質性が強い場合には，それ自体が監護者としての適格性を疑わせるから，これを主な理由として原状回

From:03 3515 7308
2026/09/18 17:00
#178 P.159/180

復としての子の引渡しが肯定されることもあると思われる。

もっとも，子の監護者の指定（引渡し）が子の福祉の観点から判断されるものである以上，法律や社会規範を無視するような態様で監護が開始されたということから，それだけで常に監護者としての適格性が欠けるという結論が帰結されるわけではない。また，そもそも，監護の開始が相手方の承諾を得ていなくても，その具体的な経緯及び態様，子の年齢や意思等によっては，それだけでは直ちに法律や社会規範を無視するような態様で監護が開始されたとまではいえない場合もある。

2　近時の裁判例の傾向

そして，最近の裁判例をより具体的にみると，離婚前の夫婦間の子の監護権の帰属に係る紛争事案では，主たる監護者が父母のいずれであったか，その者による従来の監護はどうであったか，他方の監護状況はどうであったか，父母以外の者による監護補助の状況はどうであったか，当該監護補助者と父母との関係はどうであったか等，過去の監護実績をまず確定し，現在の監護状況や子の意思，互いの監護能力や監護態勢等をも検討した上，これらの要素を踏まえ，子の福祉の観点から，父母のいずれを監護者とするのが適当かという検討が行われている傾向にあるといえる。もっとも，近時は，夫婦の生活スタイルの多様化や共働き夫婦の増加等に伴い，父母の監護が拮抗し，父母のいずれが主たる監護者であるのかを確定することが容易ではない事案や，そもそも，夫婦の別居後も父母による交互監護の形態での監護が継続して行われ，父母のいずれか一方を監護者として確定すること自体が困難な事案など，複雑な事案も少なくない。いずれにせよ，今後は，当該事案における個別具体的な事実関係をより具体的に掘り下げた上での緻密な検討がより一層要求される場面も多くなるであろう。

なお，以上は別居中の夫婦間における裁判例の傾向を念頭に置いたものであるが，離婚後，既に親権者又は監護者と定められた者からの非親権者又は非監護者に対する引渡請求の場合には，共同親権者である別居中の夫婦間に

おける紛争の場合とは異なり，権利者から非権利者に対する引渡請求であるため，既に指定された親権者又は監護者に子を監護させることが子の福祉に反することが明らかな場合等の特段の事情が認められない限り，原則として申立てが認容されるというのが裁判例の傾向である（東京高裁平成15年３月12日決定・家月55巻８号54頁参照）。

第３　家事法下における審判事件（審判前の保全処分を含む。）の審理・進行

1　はじめに

前述のとおり，子の監護者指定・引渡事件は，別居や子の連れ去りの経緯等をめぐり当事者間の感情的な対立が激しいことに加え，子をとにかく早く取り戻したいという心情も働いているためか，申立時において調停手続ではなく審判事件が選択され，その際には併せて審判前の保全処分も申し立てられる場合が少なくない。東京家裁では，後に述べるとおり，別表第二に掲げる事項についての審判事件（以下「別表第二審判事件」という。）の申立てにおいても，申立人には調停手続と同様に，進行に関する照会回答書（以下「進行照会回答書」という。）の提出を求める扱いとしており，各裁判官が申立書や進行照会回答書等の記載内容，家裁調査官による手続選別（後記２(1)オ(ｱ)参照）時の意見等を勘案した上で付調停（家事法274条１項）とするか否かを判断しているが，子の監護者指定・引渡事件については，他の別表第二審判事件と比べると，まずは審判手続を先行させ，紛争の事実経緯等について争点整理をし，実情を把握した上で，審判手続としての進行を続けるか，付調停として話合いによる解決を図るかどうかの見極めをしていることも少なくないと思われる。そこで，このような実態も踏まえ，本稿では，審判事件が先行する場合の家事法下における審判事件の審理・進行について論じ，その中で，審判前の保全処分の審理・進行等についても触れる。

2　家事法下での運用の実情

From:03 3515 7308　2026/09/18 17:00　#178 P.160/180

(1) 家事法下での審判手続遂行の概要

家事法における審判や審判前の保全処分に係る制度の概要等の詳細は，小田論文７頁以下のとおりである。子の監護者指定・引渡審判事件は別表第二審判事件であることから，家事法66条から72条までの特則が適用されることになるが，以下では，子の監護者指定・引渡審判事件の運用を踏まえた上での若干の補足を述べる。

ア　申立書の写しの送付等

家事法67条１項は，別表第二審判事件については，申立てが不適法であるとき又は申立てに理由がないことが明らかな場合を除き，原則として，申立書の写しを相手方に送付しなければならないとし，家事事件手続規則（以下「家事規則」という。）47条は，申立書に相手方の数と同数の写しを添付しなければならないとしている。

「申立書」の記載事項は，当事者及び法定代理人のほか，申立ての趣旨及び理由（申立てを特定するのに必要な事実）並びに事件の実情である（家事法49条２項，家事規則37条１項）。また，申立ての理由及び事件の実情についての証拠書類があるときは，その写しを申立書に添付しなければならないものとされている（家事規則37条２項）。家事法上は，「証拠」資料（例えば，収入資料のような，いわゆる事実を裏付けるための資料）については，相手方への写しの送付を定める規律はないが，東京家裁においては，審判前の保全処分が併せて申し立てられている場合には，当事者双方の迅速かつ充実した主張反論の要請等から，申立書に添付される証拠資料についても，資料説明書とともに相手方の数と同数の写しを添付していただき（家事規則３条２項参照），申立書の写しと併せて証拠資料及び資料説明書の各写しも相手方に送付していることが多い。

ところで，東京家裁における調停事件についての定型書式等の整備状況は，第２回の論稿本多智子「家事調停の一般的な審理～夫婦関係調整（離婚）調停を中心に～」（以下「本多論文」という。）のとおりである（本書32頁

以下）が，東京家裁では，別表第二審判事件についても，これらの書式の利用が想定されている。具体的には，子の監護者指定・引渡審判事件でも，申立時には，申立書や証拠資料とともに，連絡先等の届出書（以下「連絡先届出書」という。）及び進行照会回答書を提出していただくこととしている。また，例えば，当事者が連絡先等を秘匿することを希望する場合には，連絡先届出書に非開示の希望に関する申出書（以下「非開示申出書」という。）を添付していただくこととしている。これらの書式の趣旨及び利用方法については，本多論文を参照いただきたい。

イ　当事者双方立会いの下での審問の実施

(ア) 家事法68条は，家庭裁判所は，別表第二審判事件の手続において，申立てが不適法であるとき又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き，当事者の陳述を聴かなければならず，この陳述の聴取は，当事者の申出があるときは，審問の期日においてしなければならないと規定している（当事者の陳述聴取）。そして，東京家裁では，子の監護者指定・引渡審判事件においては，当事者双方の主張反論を十分に尽くさせるため，当事者双方立会いの下での審問を行うことが通常である。

実際の審問においては，子の従前及び現在の監護状況や，別居に至った事実経緯について，当事者双方から提出された「主張」書面（訴訟における準備書面のように当事者の主張・言い分を記載した書面）や証拠資料を踏まえて，争点整理の意味での審問を行う場合もある。また，事実関係等について当事者間で争いがあるなどの場合には，証拠調べに類する形で当事者双方に審問を行うこともあり，必要に応じて，審問のスタイルを使い分けている。とりわけ，審判前の保全処分が審判と併せて申し立てられている場合には，一般的には，審判前の保全処分における審判期日と併せ，本案の第１回審判期日を申立てから早い時期に指定し，争点整理的な審問を行いながら，緊急性の有無や家裁調査官の調査の要否やタイミング，調査命令の内容等を見極めている。そして，この場合，事実の調査の通知（家事法70条）やその記録化

From:03 3515 7308
2026/09/18 17:01 #178 P.161/180

(家事規則５条において準用する民事訴訟規則４条２項）は，審判期日において，裁判官が当事者双方への通知を行い，その旨を期日調書に記載する方法によることが通常である。

(イ) ところで，家事法69条は，他の当事者の審問立会権を定めているが，子の監護者指定・引渡事件では，同居中のDV等を理由に，当事者の一方が他方当事者の立会いを拒絶する場合も少なくない。もとより，単に相手に対する嫌悪感から顔を合わせたくないというだけで他方当事者の立会いを認めないとすることは相当ではないが，個別の事案に応じ，現に事実の調査に支障が生ずるおそれがあると認められる場合には（同条ただし書），当該当事者本人の立会いを認めない場合や，遮へい措置を講ずるなどして対処することもある。ただし，仮に当該当事者本人の立会いが難しいと判断される場合であっても，当該当事者に手続代理人が選任されているときは，その手続代理人のみを審問に立ち会わせることが可能であり，実際にもそのような措置がとられることが通常である。[61]

ウ　主張書面・証拠資料等の取扱いと閲覧謄写の実際

先に述べたとおり，家事法は，申立書については相手方への写しの送付について規律を設ける一方で，その余の主張書面や証拠資料については，他方当事者への写しの送付を定めておらず，当事者が裁判所に提出した書面のうち，裁判官が事実の調査を行ったものについては，まず，事実の調査の通知をして，他方当事者に閲覧謄写の機会を与えることにより，その内容を把握させるという基本的手続を設計している。もっとも，東京家裁では，別表第二審判事件では，担当裁判官の判断により，当事者双方の主張反論を十分かつ迅速に尽くさせる観点から，当事者が提出する主張書面及び証拠資料につ

61　手続代理人が選任されていない事案においては，審問に立ち会わなかった当事者に対しては，他方当事者の審問終了後に，裁判官がその概要を告知している。

いては，裁判所用のみならず，他方当事者交付用も準備していただき（家事規則３条２項参照），これを他方当事者に送付する扱いをしていることも少なくない。そして，子の監護者指定・引渡審判事件では，当事者双方に手続代理人が選任されることが大半であることもあって，審判期日前に当事者双方の手続代理人の間で事実上，主張書面や証拠資料等の直送が行われ，裁判官及び当事者双方が主張書面等に目を通した上で審判期日に臨み，審判期日では，裁判官による事実の調査の通知を経て争点整理等が行われることが実情として少なくないと思われる。

ところで，当事者の一方が他方当事者には秘匿を希望する書面を裁判所のみに提出する場合もあり得る。この場合，東京家裁では，当該書面に非開示申出書を添付して同申出書に非開示を希望する理由を記載していただく扱いとしている。しかし，この場合であっても，当該書面を裁判所が事実の調査の対象とする場合には，裁判所としては，当該書面を非開示とすることが相当か否かにかかわらず，他方当事者に対する閲覧謄写請求の機会を確保する観点から，当該書面について事実の調査の通知を行うことになるため，資料説明書には，非開示申出書が添付された書面であっても，秘匿の趣旨を損なわない程度で書面の特定を求めている。[62] もっとも，審判事件においては，家事法47条４項所定の事由がない限りは，当事者への閲覧謄写が許可されることになるため，担当裁判官において，同項所定の事由がなお存在しないと考える場合には，審判期日や期日外において当事者にその旨の心証を伝えた上，任意に資料を提出していただくよう促したり，当該書面に一部非開示とする部分が含まれる場合であっても，その部分を絞り込んでいただいた上，その余の部分はできるだけ他方当事者にも任意に開示していただく方向で調整したりして，閲覧謄写をめぐる無用な紛議を避けるよう配慮することもあ

62　小田正二「東京家裁における家事事件手続法の運用について－東京三弁護士会との意見交換の概要と成果を中心に－」判例タイムズ1396号34頁参照

From:03 3515 7308
2026/09/18 17:02
#178 P.162/180

る。

エ　子の陳述聴取

家事法152条２項は，家事審判法下における規律を維持し，子の監護に関する処分の審判（子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判を除く。）の子に与える影響の重大性にかんがみ，当該審判をする場合には，家事法68条の規定により当事者の陳述を聴くほか，15歳以上の子の陳述を聴かなければならないと規定している。もっとも，15歳未満の子であっても，家庭裁判所は，適切な方法により子の意思の把握に努め，子の年齢及び発達の程度に応じてその意思を考慮する必要があるとされる（家事法65条参照）。

具体的な子の陳述聴取や意思把握の方法としては，裁判官の審問のほか，家裁調査官による調査，陳述書の受領，書面照会等の方法が考え得るが，子の年齢や事案の性質等に応じ，適切な方法で子の意思を把握することが求められ，家裁調査官の調査の活用が期待される。家裁調査官の調査の概要については，次のオで述べる。

オ　家裁調査官の活用

先に述べたとおり，子の監護者指定・引渡事件では，子の従前の監護状況や実績に加え，現在の監護状況や子の意思等を把握しながら，子の福祉の観点から父母のいずれを監護者とするのが相当かを見極めることになるが，その見極めのためには，家裁調査官による行動科学の知見を活用した事実の調査（家事法58条）が有用である。そこで，審判手続における家裁調査官の関与の概要を，手続の流れに従って簡単に説明する。

(ア)　手続選別等

家裁調査官は，審判事件においても，申立書や添付資料等から，家裁調査官の関与や付調停の要否のほか，審判前の保全処分についての同時審理の有無等を含む審判手続の進行に関する意見を述べる（手続選別ということが多い。なお，調停手続における手続選別については，本多論文（本書48頁）を参照されたい。）。例えば，審判前の保全処分が併せて申し立てられている事案で

は，先に述べたとおり，本案の審判期日と審判前の保全処分における審判期日を同時に並行して進めることが通常であるが，申立時の情報から虐待やネグレクト等の蓋然性が認められるような事案では，家裁調査官による手続選別等をも参考にしながら，審判前の保全処分の審理を先行させることもある。

(イ)　審判期日立会い

先に述べたとおり，実際の審判手続では，裁判官は，当事者双方から提出された主張書面や証拠資料を踏まえて，子の従前及び現在の監護状況のほか，紛争や別居に至った経緯を把握し，必要に応じて審問において争点整理をし，その上で，今後の審理方針をも念頭に置きながら，家裁調査官による事実の調査の要否やその内容を明確にしていくことになる。そして，事実の調査が想定される事案においては，家裁調査官も審判期日に立ち会い，当事者双方から提出された主張書面や証拠資料，あるいは，裁判官による審問等で明らかにされる当事者からの陳述内容等も聴取した上で，裁判官に対し，家裁調査官による調査の要否，調査命令の内容等を判断するに当たっての意見を述べる（命令補佐）（家事法59条１項，２項[63]）。そして，裁判官・書記官と家裁調査官との間で，上記意見を踏まえて，調査命令の趣旨や調査事項を特定し，その上で，調査対象，調査方法，調査期間等についての協議を経て，調査命令が発令される。

なお，審判期日において調査命令が発令される場合には，裁判官によって

63　家事審判法下においても，家事審判規則７条の４に同様の規定があったが，家裁調査官の審判手続期日への立会いは，当事者や子の言動の観察を通じた事件の問題点の把握や解決方法の見極め等，裁判官にない専門的知見を活用して行われるものであることや，その結果は審判事件の解決方針に資するものであること等を考慮して法律事項として規定することが相当であるとされ，家事法59条において規定化されたものである（金子修編著「逐条解説家事事件手続法」（以下「逐条解説」という。）203，204頁参照）。

From:03 3515 7308
2026/09/18 17:02
#178 P.163/180

当事者双方に対して発令趣旨等の説明がされ，その後，家裁調査官からも，当事者に対して，調査の趣旨（裁判官の補足），調査計画等について説明が行われることが通常である。

(ウ) 行動科学の知見を活用した事実の調査

子の監護者指定・引渡事件の場合の調査事項としては，「子の監護状況」，「子の意向（心情）」，「親子交流場面の観察」等が一般的であり，調査命令はこれらを組み合わせて発令されることもある。

「子の監護状況」調査においては，家裁調査官が，監護親（同居親）による子の監護の実情，監護親の下での子の生活状況や心身の状態，監護親と子との関係，さらには，非監護親（別居親）と子との関係や交流状況等を調査し，現在の子の監護状況が子の福祉に合致するものかどうか，監護環境上の問題がないかどうか等を評価する。事案によっては，非監護親が予定している監護態勢が調査事項に含められることもある。また，「子の意向（心情）」調査においては，子が両親の紛争をどのように受け止め，両親に対してどのような心情を抱き，今後の生活についてどのような希望を抱いているか等を子の年齢や発達の程度等に応じた方法で把握することが目的になる。「親子交流場面の観察」調査では，家庭裁判所内に設けられている児童用の調査室（東京家裁では「児童室」という名称が付けられている。以下「児童室」という。）等において，監護親と子，非監護親と子との交流場面を各々観察し，それぞれの親の子に対する態度や接し方，子の親に対する態度や接し方等から，それぞれの関係性を評価することが目的となる。

家裁調査官は，こうした調査を行う際には，必要に応じて，監護親，非監護親，子との面接調査のみならず，家庭訪問による環境調査や，事案によっては，監護補助者（祖父母等）や関係機関（保育園，幼稚園，小学校，児童相談所など）等の周辺関係者の調査も行って，より客観的な情報の収集に努めている。また，家裁調査官の調査によって子の意思や状況を把握するに当たっては，家裁調査官がその専門的知見を活用して，子の言語的な表現のみならず，非言語的な表現や子が置かれている状況等について，子の年齢や発達状況といった視点を踏まえて分析し，評価することになる。

(エ) 調査結果の報告

家事法58条３項は，家裁調査官は，事実の調査の結果を書面又は口頭で家庭裁判所に報告するものと規定するが，家裁調査官による調査結果は調査報告書という形で提出され，裁判官が事実の調査をした後，審判期日前に書記官から当事者双方に対して事実の調査がされた旨を通知し，当事者双方が調査報告書を閲覧謄写の上，審判手続に臨むことが通常である。なお，この場合，調査報告書の記載の一部に，閲覧謄写により，事件の関係人である未成年者の利益を害するおそれがある（例えば，子による父母の選好が記載されており，父又は母が閲覧すると父子関係又は母子関係に影響を与え，ひいては子の利益に悪影響を及ぼすおそれがある場合等が考えられる。），当事者又は第三者の私生活又は業務の平穏を害するおそれがある（例えば，当事者がDVを理由に別居し，他方当事者から身を隠している事案において，子の通う幼稚園名等が記載され，住所等を推知させるおそれのある場合等が考えられる。）など家事法47条４項所定の事由に該当する情報が含まれる場合には，当該情報部分については閲覧謄写を不許可とすることもある。

(2) 審判前の保全処分の審理遂行の概要

家事法157条１項３号は，家庭裁判所は，子の監護に関する処分についての審判又は調停の申立てがあった場合において，強制執行を保全し，又は子その他の利害関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは，当該申立てをした者の申立てにより，当該事項についての審判を本案とする仮差押え，仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができると規定している。審判前の保全処分に対しては，即時抗告ができるが（家事法110条），当然には執行停止の効力はなく，裁量的に執行停止の裁判がされる余地があるだけである（家事法111条１項）。なお，審判前の保全処分の執行は，債権者（審判における申立人）に審判書が送達されてから２週間を経過するとできなく

From:03 3515 7308
2026/09/18 17:03 #178 P.164/180

なる（家事法109条３項において準用する民事保全法43条２項）。

ところで，前述のとおり，家事法下では本案係属要件が緩和され，子の監護に関する処分についての審判事件のみならず，調停事件の申立てがあった場合においても，審判前の保全処分を命ずることができるようになった（家事法157条１項３号）。これは，事案によっては，一時的には保全処分を求めつつも，最終的な本案の解決は可能な限り話合いによりたいとする当事者の一定のニーズに対しても柔軟に応え得ることなどが考慮されて制度設計がされたものである[64]。そして，調停事件と併せて申し立てられた審判前の保全処分事件における審理や保全処分審理後の調停手続については，このような立法趣旨にかんがみ，手続の各過程において，調停申立ての経緯や当事者の意向等に十分配慮しながら遂行していく必要があると思われ，今後，この種の事案の手続遂行の在り方については，事例の集積を待った上での改めての分析が必要であると思われる。もっとも，本稿では，家事法施行後も，審判前の保全処分の圧倒的多数が審判事件と併せて申し立てられるものであるという現状にかんがみ，以下では審判事件と併せて申し立てられた事件類型を想定した上で，審判前の保全処分についての審理の概要を述べることとする。

ア　仮の地位を定める仮処分をする場合の必要的陳述聴取

家事審判法下では，仮の地位を定める仮処分のための必要的陳述聴取について，原則として債務者（審判における相手方）が立ち会うことができる審尋の期日を経ることが要件とされていた（家事審判法15条の３第７項において準用する民事保全法23条４項）が，家事法107条は，「審判を受ける者となるべき者の陳述を聴かなければ，することができない。」と規定し，陳述聴取の方法についての限定を取り除き，事案に応じて書面等によることもできるようになった。

子の監護者指定・引渡しに係る審判前の保全処分事件では，実務上，申立

64　逐条解説342頁参照

ての趣旨を子の仮の引渡しや子の監護者の仮の指定とするものが多くみられ，このような申立ては仮の地位を定める仮処分に該当するといえるが，東京家裁では，当事者双方の主張反論の充実という観点から，家事審判法下と同様に，審判前の保全処分事件において債務者が立ち会うことができる審判期日を指定し，これと併せて本案の審判期日を指定していることが一般的に多いと思われる。もっとも，陳述を聴く手続を経ることにより保全処分の目的を達することができない事情があるときなどにおいては，この限りではなく，保全処分のみを先行させ，又は陳述聴取の機会を経ることなく保全処分を発令することもあり得るが（家事法107条ただし書参照），このような審理を行う事案はさほど多くないというのが現場の感覚である。

また，審判前の保全処分については，申立書の写しの相手方への送付を定める家事法67条１項の準用はなく，家事法上，申立書の写しの送付は想定されていない。また，家事法108条は，保全処分の密行性の見地から，審判前の保全処分の事件における審判を受ける者となるべき者に対し，当該事件が係属したことを通知し，又は審判前の保全処分を告知するまでは，飽くまでも，相当と認めるときに限り，記録の閲覧謄写を認めるものとしている。もっとも，実際の審理では，個別事案によるが，迅速かつ充実した主張反論を確保する観点から，期日呼出しをする場合に申立書及び疎明資料の各写しを送付することがむしろ通常であり，申立時に，相手方の数と同数の申立書及び疎明資料の各写しが提出されることも少なくない。

イ　保全処分を求める事由の疎明

申立人は，保全処分を求める事由を疎明しなければならず（家事法106条２項），この枠組みは家事審判法下と同様に維持されている。そして，「保全処分を求める事由」としては，家事審判法下では，次のとおり，本案認容の蓋然性と保全の必要性の両方であると解されており，この解釈は家事法においても同様であるとの前提で運用されている。

(ア)　本案認容の蓋然性

From:03 3515 7308
2026/09/18 17:04
#178 P.165/180

本案においては，一定の請求権の客観的内容の存否が審理の対象となるのではなく，本案に関する権利義務関係の形成の当否及びその内容が審理の対象となることから，審判前の保全処分の要件としても，本案の審判において一定の具体的な権利義務関係の形成がなされることについての蓋然性が必要とされる。

そして，子の監護者指定・引渡しの事案の実情という観点からこれをみると，心証の程度は疎明で足りる（家事法106条２項）とはいえ，数次の裁判において異なった判断がされる都度子の引渡しの強制執行[65][66]がされると，子に対して著しく大きな精神的緊張と精神的苦痛を与えることになり，このこと自体が子の福祉に反することになるとの配慮から，本案と審判前の保全処分とで結論が実質的には異なることのないようにされる傾向にある。そのため，後記(イ)の保全の必要性の箇所で述べるとおり，例えば，子に対する虐待やネグレクト等が認められる場合や，別居後にその一方の親の下で監護されていた未成年者を他方の親が実力を行使して連れ去るような場合など，本案認容の蓋然性が比較的容易に認められやすい事情があればともかく，本案における権利義務関係の形成の状況を一応見極められる段階まで，かなりの実質的審理を必要とする場合も少なくないのが実情である。

65　従前の実務においては，間接強制のみを認める運用がなされていたが，直接強制をおよそ否定することは自力救済を誘発する危険を招きかねないことや，子の人格への配慮は，直接強制の可否の問題としてではなく，子の人格に配慮した妥当な執行方法による実現が可能であること等の指摘がなされるようになり，子の引渡しの審判の実効性を確保する観点から，現在の実務は，直接強制が可能であることを前提として，債務者と子との関係が，動産の所持者の占有関係と類似の物理的心理的支配関係にある場合にのみ直接強制を認め，子の意思能力の有無によって個別に直接強制の可否を判断している（遠藤真澄「子の引渡しと直接強制－主に家裁の審判，保全処分と直接強制の在り方について－」家月60巻11号１頁参照）。

66　平成26年４月１日に施行された国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律（平成25年法律第48号）には，執行時における子の福祉に配慮した種々の規定が設けられ（140条１項柱書，３項，５項等参照），国内の子の引渡執行事案でもこれらの規定を参考にした運用が検討されることも考えられるが，いずれにせよ，強制執行が子の負担になり得るとの本質が変わるものではないであろう。

(イ)　保全の必要性

家事法157条１項３号は，保全の必要性について，「子その他の利害関係人の急迫の危険を防止するため必要があるとき」と規定している。つまり，家事法は，本案認容の蓋然性が認められるだけでは審判前の保全処分の発令要件としては足りず，さらに，保全の必要性が必要であるとしている。そして，この場合，本案認容の蓋然性でも述べたとおり，子の監護者指定・引渡しの事案では，子の福祉の観点から，できる限り数次の強制執行を避けることへの配慮も必要であり，この観点からも必要性の充足性が判断されるべきことになる[67]。

例えば，子に対する虐待やネグレクト等，子の生活に対して危険が伴う父

67　このような観点から，保全の必要性について「審判前の保全処分として子の引渡しを命ずる場合には，監護者が子を監護するに至った原因が強制的な奪取又はそれに準じたものであるかどうか，虐待の防止等の子の福祉のために子の引渡しを命じることが必要であるかどうか，本案の審判の確定を待つことによって子の福祉に反する事態を招くおそれがあるといえるかどうかについて審理し，これらの事情と子をめぐるその他の事情とを総合的に検討した上で，審判前の保全処分により子について引渡しの強制執行がされてもやむを得ないと考えられるような必要性があることを要するものというべきである。」とし，この要件を満たさない審判前の保全処分を取り消した裁判例（東京高裁平成24年10月18日決定・判例タイムズ1383号327頁）がある。その他に，保全の必要性について判断した裁判例として，東京高裁平成15年１月20日決定・家月55巻６号122頁がある。

From:03 3515 7308
2026/09/18 17:04 #178 P.166/180

母の態度が認められたり，父母の監護に起因して子が情緒不安を起こしたりしているような場合，あるいは，別居後にその一方の親の下で監護されていた未成年者を他方の親が実力を行使して連れ去るような場合[68]など，監護開始の悪質性が顕著な事案などは，保全の必要性が認められやすい傾向があるといえよう。

もっとも，実情をみると，既に争点整理の段階において，あるいは，家裁調査官による調査を経た段階において，保全の必要性がないことが明らかになる事案も多く，裁判官による心証開示を経て申立てが取り下げられる事案も少なくない。そして，このような審理の実情が，少なからず，冒頭に述べた仮処分における認容率の低さや取下げ率の高さと関係しているのではないか

68 例えば，別居中の夫婦間において，非監護親である母が，代理人に交渉を任せていた面会交流が実現しないとして，当該代理人等に相談することなく子の通う保育園内に無断で侵入し，園内で遊んでいた子を連れ出したため，監護親である父が，当該母に対し，速やかに子の監護者指定・引渡しを本案とする審判前の保全処分を申し立てた事案において，東京高裁平成20年12月18日決定・家月61巻7号59頁は，「従前監護していた親権者による監護の下に戻すと未成年者の健康が著しく損なわれたり，必要な養育監護が施されなかったりするなど，未成年者の福祉に反し，親権行使の態様として容認することができない状態となることが見込まれる特段の事情がない限り，その申立てを認め，しかる後に監護者の指定等の本案の審判において，いずれの親が未成年者を監護することがその福祉にかなうかを判断することとするのが相当である」とした上，上記事案では特段の事情は認められないとして，当該母に対し，子の仮の引渡しを命じた。上記決定は，上記説示に際して，当該事案における連れ去りの違法性を注釈3で触れた人身保護請求に係る最高裁平成11年4月26日判決と比較しても顕著であるとした上，「申立ての根拠とする法令の選択によって裁判規範が著しく異なることとなれば，結局，人身保護請求に先んじて審判前の保全処分が活用されるべきであるとする最高裁判例の趣旨が没却され」るとしており，その考え方は保全の必要性の分水嶺を考える上で参考になると思われる。

かと推察される。

なお，保全の必要性の判断に際しても，家裁調査官による子の監護状況の調査の活用が考えられるが，ここでの調査は，飽くまでも，保全の必要性という見地から，子に対する虐待やネグレクトがないか，子が情緒不安を起こしていないか，といった観点からの調査であり，調査の具体的な内容は，本案における子の監護状況調査とは相違するであろう。

ウ　子の陳述聴取

家事法157条2項は，子の監護に関する処分について，仮の地位を定める仮処分（子の監護に要する費用の分担に関する仮処分を除く。）を命ずる場合には，当該仮処分が一般に子に重大な影響を与えるものであることにかんがみ，原則として15歳以上の子の陳述を聴かなければならないと規定している。

具体的な陳述聴取の方法については，基本的に前記2(1)エで述べたのと同様である。

(3)　審理の実情

以上，審判事件（本案）と審判前の保全処分それぞれの審理遂行の概要について述べてきたが，両者が申し立てられる場合においては，裁判所としては，審判前の保全処分の認容の可能性を見極めながら，本案と審判前の保全処分のいずれに軸足を置いた審理を行うか，家裁調査官の事実の調査を，限定的にであっても，とりあえず審判前の保全処分の帰趨を迅速に判断するための調査とするか，むしろ，本案の帰趨をも見据えた上での幅広い調査とするか，あるいは，連れ去りの違法性が顕著な事案であるなど，敢えて家裁調査官の調査を行うまでもなく速やかに審判前の保全処分を発令すべきと見極めるか等について，当事者双方の意向を踏まえつつ，審理方針の策定を行っているのが実情である。そして，審判前の保全処分をいち早く発令し，子の救済を図るべき事案においては，前述した子の引渡しを命じる審判前の保全処分の執行期間（家事法109条3項において準用する民事保全法43条2項）をも

From:03 3515 7308　2026/09/18 17:05　#178 P.167/180

勘案し，審判前の保全処分を出すタイミングや送達方法を，個別の事案の事情を踏まえつつ慎重に吟味しながら，発令を行っている。[69]

もっとも，審理を進める中で，裁判所が子の引渡しが相当であるとの心証を得た場合であっても，子が強制執行手続にさらされること自体が子に対して大きな精神的緊張と精神的苦痛を与えることは否定できないのであり，事案によっては，ひとまず，裁判所から，当事者に対して，任意の引渡しのための説得をし，実際に任意の引渡しが実現されることも少なくない。そして，先に述べたとおり，このような裁判所による働き掛けを契機とする任意の子の引渡しの実現もまた，冒頭で述べた審判前の保全処分の認容率の低さや取下げ率の高さと関係していることが推察されるといい得る。しかし，いずれにせよ，この場合，子の任意の引渡しだけで当事者双方の紛争が抜本的に解決されるものではなく，むしろ，子を任意で引き渡した親と子との面会交流等によるその後の関係構築の在り方は，検討課題として残る。同様に，保全の必要性や本案を認容することが困難と考えられる事案であっても，なお，監護者と指定されない者と子との面会交流の在り方等を調整すべき事案も少なくない。

また，審理を進めてみると，当事者双方の紛争の真の実質は，離婚までの当面の監護権の帰属を決めるということよりも，夫婦の離婚問題そのものや親権の帰属，あるいは，面会交流の具体的な取決めの在り方ではないかと思われる事案も少なくなく，むしろ，調停手続の中で，家裁調査官をも関与させ，じっくりと話合いによる解決を図ることこそが紛争の抜本的な解決に資すると思われる事案に直面することもある。そして，実際のところも，裁判

69　申立人に手続代理人がついている場合には，執行期間との関係のほか，保全の密行性から，実効性のある執行を行うために，手続代理人において，事前に東京地方裁判所民事第21部代替執行係（霞が関庁舎・民事第９部内）に相談に行くこともあるようである。

官による一定の心証開示をも踏まえた上，事件が調停に付される事案も少なくないのであり，むしろ，事後的にみれば，申立て当初から，調停手続を選択することも選択肢の一つとして十分あり得たのではないかと感じられる事案を経験することもある。

要するに，子の監護者指定・引渡事件においても，調停手続の有用性は他の事件といささかも変わることはないのである。そこで，次項では，子の監護者指定・引渡しに係る調停事件の進行について簡単に触れることにする。

第４　調停事件の進行の概要

１　子の監護者指定・引渡調停事件の特徴

子の監護者指定・引渡調停事件では，別居や子の連れ去りの事実経緯等をめぐり感情的な対立が激しい事案が少なくない。その上，子の監護者指定や子の引渡しだけが調停手続における話合いのテーマになることはむしろ少なく，例えば，夫婦関係調整調停事件が進められる中で親権が争点として顕在化した際に，子の監護者指定・引渡調停事件が併せて申し立てられたり，さらには面会交流調停事件が申し立てられたりする場合も多い。また，非親権者又は非監護者である親が子を監護している場合に，親権者又は監護者から子の引渡調停事件が申し立てられるのに対し，非親権者又は非監護者からはその対抗手段として親権者変更や監護者変更等の調停事件が申し立てられるなど，要するに，子の監護者指定・引渡調停事件では，同時に関連事件が係属することもあり，これらの関連事件との一括解決に向けた話合いが課題になることも少なくない。そのため，調停委員会としては，複雑に絡み合った対立点を当事者双方の感情面にも配慮しながら整理し，どの論点に力点を置くか，どの論点から調整を図っていくか，柔軟に進行方針を策定しつつ，合意形成に向けた取組を行うことになる。

いずれにせよ，この種の調停事件の進行に際して，まず，第一に念頭に置かれるべきはやはり子の福祉であり，裁判官を主宰者とする調停委員会とし

From:03 3515 7308　2026/09/18 17:05　#178 P.168/180

ても，前記第２で述べた子の監護者指定（引渡し）の考慮要素を踏まえつつ，従前の監護状況，別居に至った経緯，現在の監護状況等について，客観的証拠資料をもとに事実関係を把握し，さらに，子の年齢及び発達の程度に応じてその意思を把握した上，両当事者が協力して子の監護養育を続けていく態勢を構築していけるよう，心理的調整等を図りながら，当事者双方の紛争解決意欲を高め，妥当な解決を目指すことになる。

2　主張書面・証拠資料等の取扱いと閲覧謄写の実際

東京家裁における家事調停に関する定型書式の活用，情報共有の在り方（主張書面・証拠資料等の提出方法，閲覧謄写の規律とその取扱い等）等，調停事件の進行の概要については，既に本多論文（本書32頁以下）で述べられているとおりである。

東京家裁では，子の監護者指定・引渡調停事件については，婚姻費用分担や養育費等と比較すると件数が少ないこともあり，同事件についての申立書や事情説明書，答弁書の書式を独自に作成することはしていないが，手続の流れのほか，申立書の写しの送付（家事法256条１項本文），書類提出のルール（開示等も含む。），第１回調停期日までに提出すべき資料（申立書，答弁書，連絡先届出書，進行照会回答書等）について説明した手続説明書面を作成し，調停手続の進め方について，当事者にわかりやすい説明を心掛けている。

なお，子の監護者指定・引渡事件では，別居や子の連れ去りの事実経緯等をめぐり感情的な対立が激しい事案が少なくなく，そのような事案において，当事者の陳述書等すべての提出書類を調停段階から明るみにすることが，当事者の感情的な対立を深め，円滑な調停の進行を妨げ，結果的に子の福祉を損なうおそれもある。そこで，養育費等の経済事件とは異なり，調停段階においては，申立書以外の資料については，相手方交付用の写しの提出を求めてはいない。

3　家裁調査官の活用

子の監護者指定・引渡調停事件における家裁調査官の活用については，夫婦関係調整（離婚）調停を中心に家事調停の一般的な審理について整理した本多論文（本書52頁以下）と基本的には同じであるが，以下では，子の監護者指定・引渡調停事件の特徴に触れながら，その概要について述べる。

(1)　調停期日立会い

子の監護者指定・引渡調停事件では，当事者双方において，別居や子の連れ去り等に至る経緯をめぐり感情的な対立が激しい事案が少なくない。また，子の監護状況等に係る事実の調査が調停手続の早期の段階から想定されることも少なくない。そのため，子の監護者指定・引渡調停事件では，家裁調査官が調停手続の早期の段階から期日に立ち会い，専門的見地から当事者に助言や働き掛けを行い当事者の紛争解決意欲を引き出して，その主体的な関与を促したり，期日間の調査（事実の調査）の必要性について調停委員会に意見を述べたりするなどして，調停の進行を補佐する途が選択されることも少なくないといえる。

(2)　事実の調査，調整

家裁調査官は，調停委員会において家裁調査官による事実の調査が必要であると判断される場合には，裁判官の命令により，調停の期日間に事実の調査を行うことになる（家事法261条１項，２項）。

調停手続における家裁調査官の調査についても，調査事項，調査対象，調査方法等は基本的に審判手続における場合と同様である。もっとも，審判手続における家裁調査官の調査が監護者指定に係る裁判官の判断に資するための調査であるのに対し，調停段階においては，どちらかというと，当事者双方の紛争解決意欲を高め，合意の形成をより指向することに向けられた調査であるところに相違があるといえる（ただし，調停不成立により審判に移行した場合には，その調査結果が審判のための判断資料として扱われる可能性が高いことはいうまでもない。）。

そのため，調停段階においては，事実の調査を行う過程の中で，併せて子

From:03 3515 7308
2026/09/18 17:06
#178 P.169/180

の福祉に目を向けた解決策を検討できるよう当事者（父母）に働き掛けるという調整活動が行われることもある。そして，この調整活動を行う際には，例えば，最高裁判所作成のDVD[70]を当事者に視聴していただいたり，面会交流の実現による最終的な合意形成の可能性がある事案において，面会交流実施の可否を検討するに当たり，家庭裁判所内に設けられている児童室等を使用した「試行的面会交流[71]」の実施が試みられたりすることもある。

4　調停事件の終了

子の監護者指定・引渡しについて，調停委員会による働き掛けや家裁調査官の調査結果等を踏まえ，当事者間において合意が成立した場合には，その内容を確認し，調停成立により事件は終了する（家事法268条1項）。調停手続において，一方の親と子との面会交流に関する取決めをすることで子の監護者指定・引渡しについても円満な解決を図ることができる場合もあり，その場合は，面会交流等も含めた調停が成立することもある。

一方，当事者間において合意が成立する見込みがないと判断される場合には，調停不成立として審判手続に移行することが一般的である（家事法272条1項，4項）。なお，家事法下においては，別表第二に掲げる事項についての調停事件についても調停に代わる審判をすることが可能となり（家事法284条），子の監護者指定・引渡調停事件においても，子の監護者指定・引渡し及び面会交流を行うことに合意ができているが，面会交流の具体的条件の細部について合意に至らない場合などに活用されることが考えられる。

70　最高裁判所のウェブサイト（http://www.courts.go.jp/video/kodomo_video/index.html）にも，同内容の動画が配信されている（最高裁判所「離婚をめぐる争いから子どもを守るために」）。

71　試行的面会交流については，水野・中野論文を参照されたい。

第5　まとめ

以上，子の監護者指定・引渡事件における審判事件・調停事件及び審判前の保全処分の審理の実情について概観した。

一口に子の監護者指定・引渡事件といっても，その紛争の実相や当事者の心理的葛藤の程度，あるいは，当事者の紛争解決に向けたニーズは，個々の事案ごとに様々であり，結局は，手続代理人や裁判官が，前述した各々の手続の特性や利点等を踏まえて，その効果的かつ適切な使い分けを行っていくことがまずもって肝要である。

もっとも，いずれの手続が選択される場合であっても，一番に配慮されるべきは子の福祉の実現である。子の監護者指定・引渡事件では，裁判官，手続代理人，家裁調査官及び書記官，さらには，調停委員が，まさに，それぞれ各々の役割を見定め，子の福祉の実現に向けて一丸となって連携を図りながら，審理・調停の充実を図ることが望まれるのである。

【参考文献】

1　斎藤秀夫ほか編「注解家事審判法（改訂）」青林書院
2　斎藤秀夫ほか編「注解家事審判規則（特別家事審判規則）（改訂）」青林書院
3　金子修編著「一問一答家事事件手続法」商事法務
4　金子修編著「逐条解説家事事件手続法」商事法務
5　阿部徹・島津一郎編「新版注釈民法（22）・親族（2）」有斐閣
6　梶村太市ほか「子の引渡し保全処分事件の処理をめぐる諸問題」家月47巻7号1頁
7　遠藤真澄「子の引渡しと直接強制ー主に家裁の審判，保全処分と直接強制の在り方についてー」家月60巻11号1頁
8　松本哲泓「子の引渡し・監護者指定に関する最近の裁判例の傾向につい

From:03 3515 7308　2026/09/18 17:06　#178 P.170/180

From:03 3515 7308

て」家月63巻9号1頁

9　安倍嘉人・西岡清一郎監修「子どものための法律と実務」日本加除出版

10　瀬木比呂志「子の監護紛争と家事保全・人身保護請求」新家族法実務大系第2巻351頁

11　若林昌子「親権者・監護者の判断基準と子の意見表明権」新家族法実務大系第2巻383頁

12　小田正二「子の監護紛争における裁判所内外の専門家の役割」新家族法実務大系第2巻368頁

13　松村徹「子の監護に関する処分事件の制度およびこれに関連する裁判例」判例タイムズ1376号29頁

14　吉村真幸「子の引渡しと人身保護請求」判例タイムズ1100号176頁

15　中山直子「別居中の夫婦間の子の引渡請求」判例タイムズ1100号172頁

16　中山直子「第三者に対する子の引渡請求」判例タイムズ1100号180頁

17　中山直子「子の引渡しの判断基準」判例タイムズ1100号182頁

18　林賢一「子の奪い合いをめぐる紛争事件における家庭裁判所調査官の役割」判例タイムズ1100号184頁

19　山崎恒「子の引渡しの強制執行―直接強制の可否」判例タイムズ1100号186頁

20　小田正二「東京家裁における家事事件手続法の運用について―東京三弁護士会との意見交換の概要と成果を中心に―」判例タイムズ1396号25頁

石垣智子　裁判所職員総合研修所教官（前東京家庭裁判所判事）
重髙啓　神戸地方家庭裁判所洲本支部判事補（前東京家庭裁判所判事補）

※　本稿中，家裁調査官の事務に関しては，椎野肇東京家裁次席調査官から家裁調査官の中核的役割と調査事務の実情等を踏まえた貴重なご意見を頂いた（244頁のオ及び256頁の3）。

2026/09/18 17:07 #178 P.171/180

● 高等裁判所 ●

東京高裁昭和38年9月3日決定・家月16巻1号98頁 ……350
東京高裁平成15年1月20日決定・家月55巻6号122頁……251
東京高裁平成15年3月12日決定・家月55巻8号54頁 ……239
大阪高裁平成15年3月27日決定・家月55巻11号116頁……353
名古屋高裁平成18年5月31日決定・家月59巻2号134頁……112
広島高裁平成19年1月22日決定・家月59巻8号39頁 ……234
東京高裁平成20年12月18日決定・家月61巻7号59頁 ……252
東京高裁平成23年5月9日決定・家月63巻11号60頁 ……355
大阪高裁平成24年9月6日決定・家月65巻5号84頁 ……305
東京高裁平成24年10月18日決定・判例タイムズ1383号327頁……251
東京高裁平成25年6月25日決定・判例タイムズ1392号218頁……297

● 家庭裁判所 ●

東京家裁昭和47年3月22日審判・家月25巻4号46頁 ……299
和歌山家裁平成16年11月30日審判・家月58巻6号57頁 ……354
釧路家裁北見支部平成17年1月26日審判・家月58巻1号105頁……354
福島家裁平成19年10月31日審判・家月61巻4号101頁……354
京都家裁平成20年2月28日審判・家月61巻4号105頁……355
東京家裁平成20年7月31日審判・家月61巻2号257頁 ……90
神戸家裁伊丹支部平成20年10月17日審判・家月61巻4号108頁……355
東京家裁平成22年5月25日審判・家月62巻12号87頁 ……234

本文中等書籍の略語として，家月，集民，民集とあるのは以下の略である。
家月…家庭裁判月報
集民…最高裁判所裁判集民事
民集…最高裁判所民事判例集

家事事件・人事訴訟事件の実務
～家事事件手続法の趣旨を踏まえて～　　書籍番号302705

平成27年6月30日　第1版第1刷発行
平成29年2月10日　第1版第4刷発行

編　集　東京家事事件研究会
発行人　平　田　　豊

発行所　一般財団法人　法　曹　会

〒100-0013　東京都千代田区霞が関1-1-1
振替口座　00120－0－15670
電　話　03－3581－2146
http://www.hosokai.or.jp/

落丁・乱丁はお取替えいたします。　印刷製本／大日本法令印刷

ISBN 978-4-908108-27-3

From:03 3515 7308
2026/09/18 17:07 #178 P.172/180

研究 Study

子の監護者指定・引渡しをめぐる最近の裁判例について

東京地方裁判所判事 山岸秀彬

第1 はじめに

子の監護事件に関しては，民法等の一部を改正する法律（平成23年法律第61号）により，民法766条が改正され，「子の監護について必要な事項」として，面会及びその他の交流並びに子の監護に要する費用の分担が明記されるとともに，これらを定めるに当たっては，子の利益を最も優先して考慮しなければならない旨が定められた。子の監護について必要な事項を子の利益の観点から定めることは，改正前の民法においても理念とされていたと考えられるが，子の監護に関する事項は，離婚をする当事者間の利害の対立が大きいことなどから，改めてこの理念を明記したものとされている[1]。また，こうした子の福祉への配慮を手続上も担保するため，家事事件手続法65条は，「家庭裁判所は，親子，親権又は未成年後見に関する家事審判その他未成年者である子（未成年被後見人を含む。以下この条において同じ。）がその結果により影響を受ける家事審判の手続においては，子の陳述の聴取，家庭裁判所調査官による調査その他の適切な方法により，子の意思を把握するように努め，審判をするに当たり，子の年齢及び発達の程度に応じて，その意思を考慮しなければならない。」と規定している（同条は調停手続にも準用される（家事事件手続法258条1項）。）。

こうした民法の改正や，家事事件手続法の定めは，家族をめぐる社会の状況や国民の法意識が大きく変化したことに伴うものであると考えられるが，そうした社会状況の変化に応じて，子の監護事件（監護者の指定，養育費請求，面会交流，子の引渡しの各事件）は近年増加しており，子の監護事件の調停・審判事件の新受件数は，平成22年には3万4913件であったのが，平成31・令和元年には4万4778件となっている[2]。このうち，監護者の指定事件は，平成22年には2557件であったのが，平成31・令和元年には5044件となっており，子の引渡し事件は，平成22年には2075件であったのが，平成31・令和元年には3826件となっている。こうした事件においては，当事者の主張が激しく対立し，解決が困難な事件も少なくない。前記のとおり，民法766条1項は，子の監護に関する事項を定めるに当たっては，「子の利益」を最も優先して考慮しなければならないとしているが，個別具体的な事情の下で，どのような解決が子の利益に適うといえるのかをめぐって，当事者の意見が激しく対立することが多い。

そこで，本稿では，子の監護事件のうち，子の監護者指定や子の引渡しが問題となった事件について，最近の公刊された裁判例を取りまとめて紹介し，「子の利益」に関して具体的にどのような事情が考慮されているのかを明らかにすることとしたい。なお，本稿中意見にわたる部分は筆者の個人的な見解である。

第2 先行研究の概要

子の監護者指定・引渡し事件における考慮要素については，既に優れた先行研究があるので，始めにその一端を紹介することとしたい。以下は，年代順に紹介しているが，その内容を見ると，時代の変化に応じた変遷もあるように思われる。

まず，梶村太市元判事らは，一般的に「子の福祉」を実現させるため，過去の裁判例等では次のような一般的基準が用いられていると分析している[3]。すなわち，①子の現状を尊重する（継続性），②乳幼児については母を優先する（母親優先），③子の意思を尊重する（子の意思），④子について物質面より精神面を優先する，⑤育ての親より，血のつながりのある親を重視する（血縁），⑥きょうだいは原則として分離せず，同一の親にまとめる（きょうだい不分離），⑦婚姻中に不貞があったなどの有責性はあまり重視しない（有責性の排除），⑧子に関する諸般の要因を考慮する，とされている。

上記の考慮要素に関しては，①継続性について，現状を追認するものであって，いわゆる「連れ去り得」を認めるものである[4]，②母親優先については，性別役割分担の発想に基づくものであるとして，かねて批判されてきたところである。このような批判も踏まえ，中山直子判事は，子の引渡しの判断基準として，①乳幼児期における母性優先の原則，②継続性の原則，③子の意思の尊重，④面接交渉の許容性，⑤有責性，⑥きょうだい不分離を掲げた上で，①母性優先の原則については，「生物学上の母親ということだけではなく，子と母性的なかかわりを持つ養育者と理解して，父母のいずれがそのような役割を担ってきたかについて検討する」としている。また，②継続性の原則については，「継続性の始期を奪取時を始点とするのではなく，乳幼児期であれば，監護親との心理的な継続性が重要であるので，子の出生時からの生育歴を全体的に見て判断する」としている[5]。

以上の議論の進展を踏まえ，松本哲泓元判事は，裁判例を詳細に分析し，①母親優先の原則，②主たる監護者，③現状の監護の継続性，④監護態勢，⑤監護補助者，⑥違法な監護の開始，⑦異性関係，⑧子の意思，⑨きょうだい不分離，⑩面会交流拒否，⑪暴力という考慮要素に分けて裁判例を紹介している[6]。ただし，①については，母性優先と言い換えるというのにとどまらず，母性的な養育のニーズを満たす者が誰かという検討は，②の主たる監護者による監護の継続の必要性において判断されるとして，独立の考慮要素としては適切でないとしている[7]。その上で，「最近の主な裁判例は，子の福祉について判断するに当たり，子の精神的かつ身体的なニーズを満たす存在としての適格性を備えた主たる監護者による監護の継続が子の成長に重要であるという考え方を基本に展開していることが分かる。つまり，主たる監護者であった者による従来の監護に問題がなく，その監護能力や監護態勢等に問題がなければ，今後の監護は主たる監護者であった者に委ねるのを，基本的な姿勢とし，主たる監護者であった者以外の者を監護者とした事例では，その他に重視すべき事情が存在するものであったといえる。」と分析している[8]。ここでの「主たる監護者」の考慮要素は，中山判事が「子の出生時からの生育歴を全体的に見て判断」すべきとしているところの「継続性」におおむね対応するものということができるように思われる。

以上のような考慮要素の整理は，民法766条の改正や家事事件手続法の制定後もおおむね維持されていると考えられ，石垣智子判事らは，子の利益についての考慮要素として，①乳幼児期における「主たる監護者」，②監護環境の変化，③子の意思，④面会交流の許容性，⑤きょうだい不分離，⑥監護開始の態様を掲げている[9]。その上で，主たる監護者については，「近時は，夫婦の生活スタイルの多様化や共働き夫婦の増加等に伴い，父母の監護が拮抗し，父母のいずれが主たる監護者であるのかを確定することが容易ではない事案や，そもそも，夫婦の別居後も父母による交互監護の形態での監護が継続して行われ，父母のいずれか一方を監護者として確定すること自体が困難な事案等，複雑な事案も少なくない。」として，家族をめぐる社会の状況の変化を踏まえた問題点を指摘している[10]。

From:03 3515 7308 2026/09/18 17:08 #178 P.173/180

乙第8号証

第3　最近の裁判例の傾向

以上のような先行研究による整理も踏まえ，改正民法766条の施行後であり前掲松本論文の公表後である平成24年以降の裁判例のうち，公刊されたものを取り上げて紹介したい。以下では，前掲松本論文による整理を踏まえ，主たる監護者が監護者として指定された事案（下記1），主たる監護者でない方の親が監護者として指定された事案（下記2），主たる監護者がいずれであったかが決し難い事案（下記3）に分けて整理するとともに，その余の特徴的な類型についても紹介する（下記4から7まで）（なお，以下の裁判例の引用における〔　〕内の記載は，いずれも筆者による注記である。また，子の年齢は審判時の年齢を記載したが，公刊された審判例は子の出生の月日が伏せられているので，1歳の誤差が生じている可能性がある。）。

1　主たる監護者が監護者として指定された事案

(1)　裁判例の概観

【1】さいたま家川越支審平成24年4月26日判時2152号46頁は，母が子らを連れて父と別居した後，父が面会交流の機会に子らを連れ去ったとして，母が父に対し，監護者の指定及び子らの引渡しを求めた事案である。裁判所は，父母の同居中，子らの主たる監護者は専業主婦であった母であり，会社勤務の父による監護は補助的であったとして，「父である相手方よりも母である申立人の監護の継続性を優先させることが子の福祉に適う」とした。また，父による「現在の〔監護〕状態は，相手方〔父〕の違法な未成年者らの連れ去りによって作出されたものであ」るとして，母の申立てをいずれも認めた。抗告審である**【2】東京高決平成24年6月6日**判タ1383号333頁・判時2152号44頁は，原審判の判断を是認して抗告を棄却したものであるが，母による当初の監護開始の態様も違法であるのに父による連れ戻し行為のみを非難すべきではないとの父の主張について，母は父の同意を得ずに子らを実家に連れて行った（にとどまる）のに対し，父は「面会交流の機会に未成年者らを抗告人〔父〕の下に連れ帰ることを計画し……両親や親戚に協力を依頼し，車3台で相手方〔母〕の両親宅に赴き，相手方やその父の抵抗を排除して未成年者らを車に乗せて連れ去った」ものであるとして，母による連れ去りは監護者の指定において重大視する点とはいい難いとした原審判の判断を是認した。

【3】水戸家下妻支審平成28年1月8日D1-Law.com判例体系判例ID28243564は，一旦，子らを連れて父と別居した母が，父が面会交流後に子らを留め置いているとして，父に対し，監護者の指定及び子らの引渡しを求めた事案である。裁判所は，子らの従前の主たる監護者は母であったとして，「主たる監護者による監護の継続が幼い子〔7歳，5歳〕の成長に有益であることから，主たる監護者による従来の監護状況に特段の問題がなければ，今後の監護も主たる監護者に担当させるのが子の福祉にかなう」とした。また，子らは母と愛着関係を形成しており，母は監護態勢の点でもわずかに優るとされた。さらに，別居時には，母が子らを監護することに父も合意していたにもかかわらず，面会交流後に父が母の同意なく子らを留め置いたことは不相当であると指摘し，母の申立てをいずれも認めた。抗告審である**【4】東京高決平成28年3月29日**D1-Law.com判例体系判例ID28243566は，原審の判断を是認して抗告を棄却したものであるが，父が，「未成年者らを引き取りに訪れた相手方〔母〕に対し，口論の末とはいえ，暴力を用いて未成年者らの引渡しを拒み，その結果，相手方が未成年者らを連れ帰ることができず，現在まで抗告人〔父〕が未成年者らの監護を続けているのであり，抗告人による未成年者らの監護は，不適切な態様により開始されたものといわざるを得ない」とし，父による現在の監護期間は，ほとんどが調停やその後の審理に要した時間であることからしても，父が子らを監護していた期間が1年以上にわたっていることを父に有利に解することはできないとした。

【5】静岡家審平成28年8月5日D1-Law.com判例体系判例ID28243057は，父が，子らを連れて父と別居した母に対し，監護者の指定及び子らの引渡しを求めた事案である。裁判所は，子らの出生以来，その監護は主として母により行われてきたものであり，子らは年齢相応の健全な成長を遂げている上，母は父と子の面会交流にも積極的な姿勢を示しているとして，子らの監護者を母と定めるのが相当であるとした。父は，母が子らを違法に連れ去ったと主張したが，裁判所は，①子らの年齢（12歳，9歳），②子らが出生以来，主として母により監護養育されてきたこと，③母が子らを連れて家を出るに当たり，子らを奪い去る等の暴力的行為があったわけではないこと，④母は別居後も父と子の面会交流の実現に積極的であることから，母が子らを連れて家を出た行為を違法と評価することはできないとした。また，自ら（父）の経済的基盤や居住環境が優れているとの父の主張に対し，母の経済的不安は婚姻費用や養育費により解消し得るものであることから，経済的要因のみを重視すべきではないとして，子らの監護者を母と定め，父による子の引渡しの申立てを却下した。抗告審である**【6】東京高決平成28年10月17日**D1-Law.com判例体系判例ID28243925は，以上の判断をおおむね是認し，抗告を棄却した。

【7】横浜家横須賀支審平成28年11月9日LLI/DB判例秘書登載判例番号L07160030は，母が，子を連れて母と別居した父に対し，監護者の指定及び子の引渡しを求めた事案である。裁判所は，子の出生後，その監護は専業主婦であった母がそのほとんどを行っており，母の監護の態様は非常に熱心だったとした上で，父は「共同で監護していた未成年者を，申立人〔母〕の同意なく，予期できない時期に突然，一方的に連れ出し，所在さえ明らかにしなかったものであり，このような相手方〔父〕の連れ去り行為は，申立人の監護権を著しく侵害するものとして違法というほかない」とした。また，子の心情について，「未成年者は，現在の〔父の下での〕環境に適応するため，無理に申立人〔母〕を意識から閉め出そうとしていることが窺われるのであり，このような状況は，3歳の幼児である未成年者にとって過酷というほかない」として，母の申立てをいずれも認めた。抗告審である**【8】東京高決平成29年2月21日**D1-Law.com判例体系判例ID28250941は，原審判の判断を是認して抗告を棄却したものであるが，父が子を連れて家を出た行為につき，「未成年者に環境を激変させる負担を与えたほか，相手方〔母〕との連絡を絶っていることも，未成年者の成育に極めて不適切である」として，父の監護者の適格性に疑問を抱かせるものであるとして，父による監護の実績や継続性を尊重することはできないと判断した。

【9】福岡家審平成28年12月16日LLI/DB判例秘書登載判例番号L07160045は，単身で家を出て父と別居した母が，父に対し，監護者指定及び子らの引渡しを求めた事案である。裁判所は，父母が同居していた際，母が主として子らの監護養育を担っていたとした。その上で，子らの意向・心情につき，5歳の長女は母を求める気持ちを表しており母との愛着関係が窺われる一方，12歳の長男は，母不在の状況が続く中で，母に捨てられたなどの思いを強くし，そのことが原因で母との関係が悪化しているとの分析・評価を踏まえ，父は母と長男の関係性の改善に目を向けられておらず，母と子らの面会交流も拒んでいる一方，母は父と子らの面会交流に応じる構えを示していることや，きょうだい不分離が望ましいことも指摘し，母の申立てをいずれも認容した。

【10】京都家審平成29年2月17日LLI/DB判例秘書登載判例番号L07260003は，母の不貞行為が判明したことから夫婦仲が悪化し，父が子を連れて自宅を出て別居した事案において，母が父に対し，監護者の指定及び子の引渡しを求めた審判前の保全処分の事案であり，**【11】京都家審平成29年2月17日**LLI/DB判例秘書登載判例番号L07260002は，同日に審判がされたその本案であるが，裁判所は，「未成年者は，出生から父母の別居に至るまでの約7年間，一貫して母である申立人により監護養育されてきており，母である申立人が主たる監護者であるこ

From:03 3515 7308　2026/09/18 17:09　#178 P.174/180

とは明らかである」とし，「その間に形成された母子間の精神的・情緒的結びつきは深いものであるところ，……こうした関係が断ち切られることは，子の成長に看過し難い影響を及ぼすことになる」とした。また，母の不貞行為については，「そのために未成年者の監護養育が不十分になったかどうか〔は〕……判然としないところであ」り，「未成年者の心身の成育に問題のないことや母子関係が良好であること，申立人〔母〕も不貞行為について真摯に反省していることからすると，申立人の不貞行為が未成年者の成育に悪影響を及ぼしたということはできないし，今後の監護養育に支障があるともいえ」ないとして，母の申立てをいずれも認めた。

【12】奈良家審平成28年５月31日判タ1434号128頁・家判11号93頁は，父が子らを連れて母と別居したとして，母が父に対し，監護者の指定及び子らの引渡しを求めた事案である。裁判所は，別居時までは，主として母が子らを監護してきたと認められるが，母が「長男及び二男を自宅に残して，複数の男性と会うために夜間外出や外泊を繰り返していたことからすれば，そのころの申立人〔母〕による監護は，適切さを欠くものであったといわざるを得ない」とした。また，父は，母の明確な同意なく子らを連れて家を出たものであるが，上記の点で「申立人の監護養育に看過できない問題があっての別居であると認められるから，相手方〔父〕による監護の開始に違法性があるとは認められない」とした。その上で，子らが，「現在の〔父の下での〕環境に十分適応しながら，健康で順調に発育しており，未成年者らの現状を変更する必要性があるとは認められないことからすれば……現状の監護態勢を維持することが未成年者らの福祉に資するというべきである」として，母の申立てをいずれも却下した。これに対し，抗告審である【13】大阪高決平成28年８月31日判タ1434号127頁・家判11号90頁は，母の不適切な行為について，これ「が未成年者らの監護に具体的にどのような悪影響ないし問題を生じさせたのかは明らかでな」く，「これのみで抗告人〔母〕による監護が将来的にも適切さを欠くとし，未成年者らを主たる監護者である抗告人から引き離し，相手方〔父〕による単独監護に委ねるのは，子の福祉の点からは十分な検討を経たものとはいえない」とし，また監護態勢についても，母による監護と比較して父による監護の方が子らの福祉の点で優れているということも明らかにされていないとして，原審判を取り消し，審理を差し戻した。

(2)　裁判例の傾向について

以上の裁判例を概観すると，近時の裁判例は，前掲松本論文が整理したとおり，主たる監護者による監護の継続（ただし，必ずしも現状の維持を意味するものではなく，後記のとおり出生以来の監護の状況を総合的に考慮するものである。）が子の成長に重要であるという考え方を基本にしているものと考えられる。それとともに，現状の監護開始の態様，双方の監護態勢，監護意欲，子の意思，面会交流の許容性，父母の異性関係が子の監護に与える影響，きょうだい不分離等の要素を考慮して子の監護者指定・引渡しについて判断しているものと見て取れる。

前掲【1】から【8】までによれば，主たる監護者がいずれであったかということ以外の考慮要素の中では，現状の監護開始の態様が重視されているということができ，不適切な子の連れ去りにより現状の監護が開始された場合にも現状の監護状況を盲目的に追認するような，いわば「連れ去り得」を容認する判断はされていないものと考えられる。この点，父母の関係が悪化して別居せざるを得ない場合において，主たる監護者が家を出るときは，子の健全な養育監護を図るためには子を連れて家を出ざるを得ないという場合もあろう。そうした場合には，子を連れて家を出たことのみによりそれが違法と評価されるわけではなく，子を連れて家を出た際の事情，他方の親の同意の有無，手段やその後の面会交流の許容性をも加味して慎重に違法性の評価がされている（前掲【3】，【5】，【6】）。他方，主たる監護者ではない親が子を連れて家を出た場合には，子を連れ出して主たる監護者と切り離すこと自体が，子の環境を激変させるものと評価されている（前掲【7】，【8】）。父母の一方が子を連れて別居した後に他方が子を連れ戻すといった，いわば子の奪い合いが生じている事案もあるが（前掲【1】から【4】まで），そうした事案においては，子の出生以降を通じて，子の主たる監護者がいずれであったかを検討するとともに，それぞれの子を連れ出した態様をも比較考慮し，子を連れ出すに際して暴行等の有形力が行使された場合には，子の福祉を害する程度が大きく，監護者の適格性にも疑問を抱かせるものであると評価されているということができる。

なお，その余の考慮要素に関して，前掲【11】，【13】からすると，父母の異性関係については，それ自体が監護者としての適格性に疑問を抱かせるものと捉えられているわけではなく，異性関係のために子の監護に具体的な悪影響が生じており，又は生じ得る場合に，その者の監護者としての適格性に疑問を抱かせるものであると理解されているものと思われる。

子の意思については，その意思に必ず従って審判をしなければならないのではなく，子の年齢及び発達の程度に応じて，考慮しなければならないものである[11]（家事事件手続法65条）。前掲【7】，【9】では，子が申立人に対して拒否的な態度をとっていたことが窺われるが，そうした拒否的な態度を示すに至ったメカニズムについて，家庭裁判所調査官による調査も踏まえて丁寧な検討を加えた上，結論としては申立てを認容するに至っている。

2　主たる監護者でない方の親が監護者として指定された事案

(1)　裁判例の概観

【14】福岡家審平成26年３月14日判タ1412号387頁・判時2256号71頁・家判２号82頁は，母が子らを連れて実家に戻り，父との別居を開始したところ，父が監護者の指定と子ら（６歳，４歳）の引渡しを申し立てた事案である。裁判所は，母は，別居時までは子らの主たる監護者であり，特段の問題なく監護を行っていたとしたが，その後に精神状態が悪化して対話性幻聴があるようであり，「別居後は，約半年以上にわたり，未成年者らの監護をもっぱら相手方〔母〕家族に任せて，自らはほとんど関わっていない状態にあり，監護意欲が著しく低下している」上，母の家族による監護についても「未成年者らの生活全体を通してその世話や躾をしている者はな」いとした一方，父は「適切な監護態勢を具体的に整えており，その監護意欲も高い」上，長女（６歳）が「申立人〔父〕との同居に積極的な意向を示している」として，父の申立てをいずれも認容した。

【15】横浜家川崎支審平成27年11月20日D1-Law.com判例体系判例ID28252565は，父が子らを連れて母と別居したところ，母が監護者の指定及び子らの引渡しを申し立てた事案である。裁判所は，父母の「監護体勢には優位な差はなく，双方とも監護者としての適格性についても大きな問題があるとはいえず，また，現在の相手方〔父〕の監護状況に特に問題となる状況は見られない」としたが，「未成年者らの年齢〔３歳，２歳〕や現状からすると，未成年者らの心情の安定を図ることが重要であるといえ，長男の状況（家庭裁判所調査官の家庭訪問調査時には，父にも母にもべたべたとまとわりつき，親を独占したがる傾向が見られた）等を考慮すると，愛着対象であり，主たる監護者であった申立人〔母〕との継続的かつ安定した関係を維持することが必要である」として，母の申立てをいずれも認容した。これに対し，抗告審である【16】東京高決平成28年５月13日D1-Law.com判例体系判例ID28252567は，「別居時までの未成年者らの主たる監護者は相手方〔母〕であるといえるが，相手方が……職場復帰して以降は，抗告人〔父〕の関わりが増え……未成年者らとの愛着関係に関しては，抗告人と相手方との間において圧倒的な差異があるということはできない」とした上で，母は，育児休業中に父の反対を押し切ってキャバクラ店で夜間のアルバイトをしたり，生後間もない長男を連れて既婚男性とカラオケやホテルに行ったりしたことがあることや，母の両親による監護補助について，その受入れに消極的な言動をしていることなどを指摘し，「監護姿勢等に未熟さや不安要素があ

From:03 3515 7308　2026/09/18 17:09　#178 P.175/180

り，これを払拭し得るだけの具体的事情が認められない相手方に未成年者らの監護を委ねるよりも，安定していて指摘すべき問題の見当たらない抗告人による監護を継続することが，未成年者らの福祉にとって望ましい」と判示し，原審判を取り消して子らの監護者を父と指定し，母による子の引渡しの申立てをいずれも却下した。

【17】福岡家八女支審平成28年11月30日消費者法ニュース111号305頁は，父が，子を連れて別居した母に対し，監護者の指定及び子の引渡しを申し立てた事案である。裁判所は，子の主たる監護者は母であり，17歳である子が母の下での監護を強く希望する意思を示しているとしたが，母は，特定の教義に基づく宗教的活動を目的とした法人格なき団体の活動に熱心に参加し，そこで子はその中間的リーダーによる母らへの暴行行為を度々目にしており，かかる環境が未成年者の福祉を害することは明らかであるとし，17歳の「未成年者の意思は尊重されるべきである」し，「未成年者が精神的に頼りにしている存在は，申立人〔父〕ではなく相手方〔母〕であるところ，このような濃密な母子関係と申立人との希薄な父子関係は，申立人との同居時から長い年月をかけて形成された強固なものである」が，上記の「未成年者の福祉を害する相手方の監護環境は，もはや看過できぬ程度にまで至ってしまっている」として，「かかる問題が解消されるまでの間は，ひとまず申立人の下で監護がなされた方が未成年者の利益に合致するというべきである」として申立てをいずれも認容した。抗告審である【18】福岡高決平成29年３月30日消費者法ニュース112号334頁も原審判の判断を是認し，抗告を棄却した。

(2)　裁判例の傾向について

以上の裁判例を概観すると，前掲松本論文が「主たる監護者であった者以外の者を監護者とした事例では，その他に重視すべき事情が存在するものであった」としているとおり[12]，主たる監護者でない方の親が監護者として指定された事案は，別居後に主たる監護者が精神疾患を抱えて監護意欲が著しく低下したり（前掲【14】），主たる監護者が子の福祉を害する活動をしている団体の活動に熱心に参加していたりする（前掲【17】，【18】）など，子の利益の観点から主たる監護者でない方の親を監護者として指定すべき事情があった事案であると考えられる。

前掲【16】は，母の夜間のキャバクラ店でのアルバイト等，母の監護姿勢の未熟さや不安要素を重視したものであるが，他方で，母は父の在宅中にアルバイトをしていたのであり，子らを危険な状態に放置したわけではないともしており，母の夜間のアルバイトが子の監護に具体的にどのような悪影響を及ぼしていたのかは必ずしも明らかでない。父母の異性関係については，前掲【11】，【13】のとおり，異性関係のために子の監護に具体的な悪影響が生じている場合に，その者の監護者としての適格性に疑問を抱かせるものであると理解されていると考えられるが，前掲【16】で問題となったのは，母の監護姿勢そのものであり，子の監護に具体的な悪影響が生じていないとしても，監護者としての適格性に疑問を抱かせる事情として考慮すべきであると考えられたものと思われる。

3　主たる監護者がいずれであったかが決し難い事案

(1)　裁判例の概観

【19】東京高決平成24年10月５日判タ1383号330頁は，父が，子を連れて別居した母に対し，監護者の指定を求めた事案である（父の申立てによる審判前の保全処分の執行により，子（４歳）は母から父に引き渡されている。）。裁判所は，「抗告人〔母〕と相手方〔父〕が同居していた当時は共稼ぎをしており，勤務時間等の労働条件も同程度であり，乳児期はともかくとして，いずれかが主たる監護者であったといえるものではなかった」とし，「このような中で，抗告人と相手方のいずれを監護者と定めるかを決定することは，なかなか困難なことであるが……抗告人及び相手方の経済状態，抗告人の監護環境が突然形成されたものであること，抗告人と相手方の従来の監護の状況等からすれば……相手方を未成年者の監護者に指定するのが相当である」として，父の申立てを認めた原審判を維持し，抗告を棄却した。判断に当たっては，母が父の実家の２階から子を連れ出し，それまでの居住地であった静岡県から埼玉県内の実家に連れて行ったことが，「決して平穏なものではなく，未成年者の生活環境を急変させたものであって，配慮に欠けるものであったと評さざるを得ない」とした上，審判前の保全処分の執行後の子の現在の監護状況が安定したものであることも指摘している。

【20】大阪家審平成26年８月15日判タ1418号394頁・判時2271号111頁・家判４号116頁は，母が父に対し，監護者の指定を申し立てた事案であるが，裁判所は，現在は父母がほぼ同じ程度に子らの養育監護をしており，共同監護のような状態であって，子の状態はそれなりに安定していると評価した上，父の２人の連れ子を含むきょうだいの不分離も考慮し，「こうした子らの心情や現在の共同監護のような現状からすると，現時点において，未成年者らの監護者として申立人〔母〕と相手方〔父〕のいずれかを指定することは，未成年者らが申立人と相手方の双方と触れ合える現状を壊しかねず，相当でない」として，父母のいずれか一方を監護者と定めることをせずに，申立てを却下した。

【21】金沢家七尾支審平成28年２月８日審判判タ1431号123頁・家判10号96頁は，母が父に対し，監護者の指定を申し立てた事案であるが，裁判所は，前掲【20】と同様に，子らは，同一市内にある父宅と母宅を行き来しながら，父母が互いに分担協力しながら，ほぼ同じ程度に子らの養育監護に関わる一種の共同監護のような状態にあり，子らも毎日双方の監護を受ける現在の状態の継続を強く望み，どちらかを監護者として生活環境が変わることに強く反対しているとして，「監護者を父母いずれかに指定することは未成年者らの福祉の見地から相当でないと言うべきであるから，現時点において未成年者らについて，監護者を指定する必要性はない」として，申立てを却下した。これに対し，抗告審である【22】名古屋高金沢支決平成28年４月７日判タ1431号121頁・家判10号92頁は，一般論として「父母の別居にもかかわらず共同監護が適切に行われていて，それを継続することが子の福祉の観点から最良と認められるのであれば，監護者を指定しないことも選択肢としてはあり得る」としつつ，原審判後に父母の対立が激化し，子ら同士の喧嘩の程度が以前より激しくなったりするなど，子らの心身にも変調が見られることからすると，現時点では監護者指定の必要性が生じていると考えられるとして，「原審判後の状況も踏まえた当事者双方の監護状況及び監護者としての適格性，両者間の紛争の現状及び未成年者らに与える影響，未成年者らの意向・心情等について，特に家庭裁判所調査官の専門的な視点による調査も含めて，更に審理を尽くし，その上で監護者指定の要否等を認める必要がある」として，原審判を取り消し，審理を差し戻した。

(2)　裁判例の傾向について

前記のとおり，前掲石垣ほか論文は，「近時は，夫婦の生活スタイルの多様化や共働き夫婦の増加等に伴い，父母の監護が拮抗し，父母のいずれが主たる監護者であるのかを確定することが容易ではない事案や，そもそも，夫婦の別居後も父母による交互監護の形態での監護が継続して行われ，父母のいずれか一方を監護者として確定すること自体が困難な事案等，複雑な事案も少なくない」と指摘しているところ[13]，前掲【19】から【22】までは，まさにそうした事案における判断として参考となるものである。

そして，前掲【19】は，父母のいずれかが主たる監護者であったといえるものではなかった場合において，監護開始の態様の不適切さが判断を分けるポイントとなったと考えられ，このような判断手法は，前記１(2)で見た判断傾向にも沿うものであると考えられる。

これに対し，前掲【20】から【22】までは，父母交互での監護が継続していたという状況において，監護者指定の申立て自体を却下することの当否が問題となったものである。前掲【22】が判示するとおり，「父母の別居にもかかわらず共同監護が適切に行われていて，それを継続

From:03 3515 7308　2026/09/18 17:10　#178 P.176/180

することが子の福祉の観点から最良と認められるのであれば，監護者を指定しないことも選択肢としてはあり得る」と考えられるが，審判事件として申し立てられているような事件は，紛争性が高く，父母交互での監護の継続を期待することが実際上は困難な事案も多いのではないかとも思われ，その場合にはいずれか一方を監護者として指定するということになるものと思われる。

4　外国法を準拠法として詳細な監護計画が定められた事案

(1)　裁判例の概観

【23】東京家審平成28年12月19日家判12号67頁は，カナダ国籍を有する父母が，同国ノバスコシア州法を準拠法として，子らの監護者指定を申し立てた事案であり，母は，自らを「主たる監護者」として指定するよう求めたのに対し，父は，分割身上監護を採用すべきであり，分割の形態としては，完全に平等な分割監護を採用すべきであると主張した。裁判所は，同州法において，父母は子の共同後見人であり，原則として子の保護及び監護を平等に行う権利があり，子はそれぞれの親とできる限りの接触を持つべきとされていることを踏まえ，同州法の分割身上監護を採用し，平日と週末のいずれにも双方の親と接触の機会を与えることを相当とし，毎月第1，3，5金曜日の午後5時から翌週火曜日の登校時までは父，その余の時間は母が監護するとしたほか，祝日や休暇期間中等についても詳細な監護計画を定め，父による子の引渡し等の申立ては却下した。抗告審である【24】東京高決平成29年5月19日家判12号58頁は，原審判をおおむね是認しつつ，父が「子らを監護する時間がおおむね40パーセントを下回らないこととなるような監護計画を定めるのが相当である」として，休暇期間中等における父の監護を拡充する形で監護計画を定め，その限度で原審判を変更した。

(2)　裁判例の傾向について

前掲【23】，【24】は，外国法を準拠法とするものであり，当該外国法の定めを踏まえて詳細な監護計画を定めたものである。日本民法の下でも，民法766条1項の「子の監護について必要な事項」として詳細な監護計画を定めることも不可能ではなかろうが，審判においては，離婚の場合に父母の一方を親権者と定めることとされていること（同法819条）との均衡から，監護者についても父母の一方を指定し，後は別居親と子との面会交流の問題として捉えていることが多いと思われる。

5　婚姻中でない父母の間で子の監護者指定・引渡しが問題となった事案

(1)　裁判例の概観

【25】福岡家審平成26年11月14日LLI/DB判例秘書登載判例番号L06960046は，母の子を認知した父が，母及び祖父に対し，児童福祉施設に措置されている子につき，監護者を仮に父と定める審判前の保全処分を求めた事案であり，【26】福岡家審平成26年11月14日LLI/DB判例秘書登載判例番号L06960045は，同日に審判がされたその本案であるが，裁判所は，子を認知した父は，民法788条及び766条により，子の監護者の指定を求めることができるとした上で，「相手方A〔母〕は，申立人〔父〕と同居中は未成年者の日常的な世話を担っていたものの……未成年者を置いて家を出て以降，未成年者を養育せず……申立人の下から未成年者を連れ去り……〔その後も〕未成年者を不安定な環境に置いて」いるなど，養育監護は著しく不適切である一方，父の監護態勢や監護補助能力に問題はなく，子（9歳）も父との生活を望む旨を具体的理由を挙げて述べていることなどから，父の申立てをいずれも認容した。

【27】大阪家審平成29年10月31日家判18号67頁は，父からの強い要望により子の親権者を父として離婚したが，離婚後も母が子を監護していたところ，父と子の面会交流をした際に父が子を母の下に返さず，その後父が子を監護養育していたという事案において，離婚後の非親権者であるはが，親権者である父に対し，子の監護者の指定及び子の引渡しを求めたものである。裁判所は，離婚に至るまでの当事者間のやり取りなどから，離婚時に当事者双方が，離婚後も母が子を監護養育することを合意したと認めることはできないとし，そうすると，「未成年者を申立人〔母〕が監護する方が，相手方〔父〕が監護する場合に比べて，子の福祉に適うことが明らかであると認められるような場合」に限り子の監護者を母とする必要があるというべきであるが，父の下での現在の子の生活状況等に照らし，上記のような場合に該当するとは認められないとして，申立てをいずれも却下した。これに対し，抗告審である【28】大阪高決平成30年3月9日家判18号63頁は，母が子の出生時から5年2か月余りの間，主たる監護者であったこと，その間の母の監護状況に特段の問題はなかったこと，子が父の下にいるのは，「監護者について協議が調っていなかった状況の下，相手方〔父〕が，抗告人〔母〕に対し，未成年者を引き取って監護する意図を秘し，ゴールデンウィーク期間中には返還する旨の虚偽の説明をして行われたものであり，その態様は著しく相当性を欠いて」おり，子が「一方的に従前の主たる監護者と切り離されており，未成年者の福祉の見地からも問題が大きい」として，原審判を取り消し，母の申立てをいずれも認めた。

【29】福岡家審平成26年12月4日判時2260号92頁は，離婚後の非親権者である父が，親権者である母に対し，子との面会交流が母により妨害されているとして，親権者の変更及び子の引渡しを申し立てた事案において，母の言動により子が面会交流に応じない事態となっており，母を親権者と指定した前提が損なわれているとして，親権者を父に変更する一方，子の監護を母から父に移すことを躊躇すべき事情が認められるから，親権と監護権とを分属させることが子の福祉に適うといえる特段の事情があるとして，子の監護者を母と指定し，子の引渡しの申立ては却下した事案である。

【30】最三小決平成29年12月5日民集71巻10号1803頁・判タ1446号62頁・判時2365号67頁・家判15号97頁は，離婚した父母のうちその長男の親権者と定められた父が，法律上監護権を有しない母を債務者として，親権に基づく妨害排除請求権を被保全権利として，長男の引渡しを求める仮処分命令の申立てをした事案である。最高裁は，①子が7歳であり，母は，父と別居してから4年以上，単独で子の監護に当たってきたものであって，母による上記監護が子の利益の観点から相当なものではないことの疎明がない，②母は，父を相手方として子の親権者の変更を求める調停を申し立てている，③父が，子の監護に関する処分としてではなく，親権に基づく妨害排除請求として子の引渡しを求める合理的な理由を有することはうかがわれないといった事情の下においては，上記申立ては権利の濫用に当たるとした。なお，木内裁判官の補足意見は，「家庭裁判所は，子の利益のために後見的な役割を果たすことがその職責とされて」おり，「父と母の間における子の引渡請求という紛争においては，子の利益という観点から，また，当事者の負担及び手続の実効性の観点からも，家庭裁判所における手続こそが本来的なものとして設けられている」と指摘している。

(2)　裁判例の傾向について

前掲【25】，【27】，【28】からすると，父母が婚姻中でない場合であっても，基本的な判断枠組は，婚姻中の父母の間で子の監護者指定・引渡しが問題となる場合と変わらず，子の福祉の観点から，従前の子の主たる監護者がいずれであったかを検討するとともに，父母の監護態勢，監護意欲のほか，子の意思や現状の監護状況がどのような態様により開始されたかを丁寧に認定して判断がされているものと考えられる。前掲【30】の木内裁判官の補足意見は，「父と母の間における子の引渡請求という紛争においては，子の利益という観点から，また，当事者の負担及び手続の実効性の観点からも，家庭裁判所における手続こそが本来的なものとして設けられている」と指摘しているが，このような指摘からしても，家庭裁判所の審理においては，上記のような丁寧な分析・評価が求められているということができる。前掲【29】は，面会交流についてその実効性を確保するための手段が限定されている現状を踏まえ，いわば苦渋の判

From:03 3515 7308　2026/09/18 17:11　#178 P.177/180

断をしたものではないかと推測されるが，上記の裁判例の傾向からするとやや特殊な事案であったようにも思われる。

6　子の監護者指定・引渡しの審判前の保全処分の事案

(1)　裁判例の概観（保全の理由について）

審判前の保全処分事件において，保全の理由については本案と同様の基準により判断がされている。心証の程度は疎明で足りるものの（家事事件手続法109条１項），「数次の裁判において異なった判断がされる都度子の引渡しの強制執行がされると，子に対して著しく大きな精神的緊張と精神的苦痛を与えることになり，このこと自体が子の福祉に違反することになるとの配慮から，本案と審判前の保全処分とで結論が実質的には異なることのないようにされる傾向がある」とされる[14]。

前掲【10】及び【25】は，本案の審判と同日に同内容の審判前の保全処分を命じたものであり，上記の傾向を表すものといえる。

(2)　裁判例の概観（保全の必要性について）

前掲【10】は，「相手方〔父〕が未成年者を連れ出してから既に４か月以上が経過しており，相手方の監護養育状況が直ちに不適切であるとはいえないにしても，わずか７歳の未成年者にとって，主たる監護者〔母〕から引き離される状況がこれ以上継続することは，過度の精神的負担を強いることになるのであって，子の福祉の観点から容認できないものである」として，保全の必要性を認めた。

前掲【25】は，「未成年者は現在施設において安定した生活を送っている」ものの「未成年者の施設における生活は，未成年者が申立人〔父〕の養育環境下から連れ去られたことにより，申立人と未成年者との日常生活が突如として遮断された状態が現在に至るまで継続しているものであって，未成年者について，従前より監護者であった申立人との日常生活を早期に取り戻してその環境を安定させる必要がある」として，申立てを認めた。審判書からは明らかでないものの，父は非親権者であることから児童福祉施設において子と面会したりすることが困難であったとも推測されるところであり，早期の親子再統合を図る見地から保全の必要性が認められたのではないかとも推測される。

【31】前橋家太田支審平成24年８月９日判時2164号59頁は，母が子を連れて自宅を出て父と別居した後，父が子との面会交流の終了時に子が「パパがよい」と泣きながら言ったため，そのまま子を連れ戻ったとして，子（４歳）の監護者指定と引渡しの審判前の保全処分を求めた事案である。裁判所は，「未成年者の主たる監護者は，生後一貫して申立人〔母〕であ」り，「別居期間中の監護者について申立人とすることが申立人及び相手方〔父〕間で了解され」ていたとし，父による面会交流後の留め置きが「連れ去りに等しい状況」にあること，子が４歳と幼く母親による養育を必要としていることなどから，本案認容の蓋然性を認め，これらによれば子を母に引き渡す「緊急の必要が認められる」として，申立てをいずれも認容した。これに対し，抗告審である【32】東京高決平成24年10月18日判タ1383号327頁・判時2164号55頁は，「審判前の保全処分としての未成年者の引渡しを命じる場合には，監護者が未成年者を監護するに至った原因が強制的な奪取又はそれに準じたものであるかどうか，虐待の防止，生育環境の急激な悪化の回避，その他の未成年者の福祉のために未成年者の引渡しを命じることが必要であるかどうか，及び本案の審判の確定を待つことによって未成年者の福祉に反する事態を招くおそれがあるといえるかどうかについて審理し，これらの事情と未成年者をめぐるその他の事情とを総合的に検討した上で，審判前の保全処分により未成年者について引渡しの強制執行がされてもやむを得ないと考えられるような必要性があることを要する」とし，本件においてそのような必要性は認められないとして原審判を取り消し，申立てを却下した。

【33】福島家郡山支審平成24年８月22日D1-Law.com判例体系判例ID28263011は，別居時の口論をきっかけに，父が「暴行という不法な有形力を行使して申立人〔母〕に入院加療を要する傷害を与え，監護養育を困難な状況に陥らせたことにより出生時から事件本人の監護養育を担っていた母子関係を違法に断絶させた」こと，「事件本人はいまだ満２歳になったばかりの乳幼児であって，母親である申立人の監護養育が欠かせない年代である」として，母による子の監護者の指定及び引渡しの審判前の保全処分の申立てを認めた事例であり，抗告審である【34】仙台高決平成24年10月31日D1-Law.com判例体系判例ID28263014は，原審の判断を是認して抗告を棄却したものである。前掲【32】にいう「監護者が未成年者を監護するに至った原因が強制的な奪取又はそれに準じたものである」との要素を満たすものとして保全の必要性が認められたものと理解することができる。

【35】東京高決平成27年２月26日判タ1423号199頁・判時2307号76頁・家判８号83頁は，母が父に対し，２歳の子の監護者を母と定める審判を申し立てるとともに，子の引渡しを求める審判前の保全処分を申し立てた事案において，「別居するまで，相手方〔母〕が未成年者の監護養育を主に担っていたと認められ」，「相手方には，監護の意欲や能力があり，その環境も整っている」としつつ，父の「監護状況に格別の問題があることは窺えず，未成年者に対する急迫の危険が現在していると認めるに足りる証拠もない」として，母と子の面会交流が実現されたものと窺われることも踏まえ，仮の引渡しを認めた原審判を取り消し，母の申立てを却下した。

【36】東京家審平成28年４月７日判タ1446号139頁・家判12号95頁は，父が母の留守中に書き置きを残して子らを連れて家を出たところ，母が父に対し監護者の指定及び子らの引渡しの審判前の保全処分を申し立てた事案において，「申立人〔母〕は，子らが出生してから，相手方〔父〕が子らを連れ去るまで，子らの主たる監護者であ」ったが，父は，「申立人と相手方との間で別居ないし離婚を前提として話し合いをしていた状況の中で，突然，子らを連れ去っている」として，「相手方による子らの連れ去りは，子らの福祉を著しく害するものといわざるを得ず，本案審判認容の蓋然性及び保全の必要性は十分疎明されている」として，母の申立てをいずれも認容した。これに対し，抗告審である【37】東京高決平成28年６月10日判タ1446号136頁・家判12号91頁は，父が子らを連れて家を出た行為につき，「未成年者らを強制的に奪取したとか，それに準じて強制的に連れ去ったとの評価を受けるものではない」とした上で，現在の父の下における子らの生育環境について，「虐待がされているとか，従前との対比で生育環境が劣悪なものとなったとは認められない」として，「未成年者らの監護者を仮に相手方〔母〕と定め，また，抗告人〔父〕に対し，未成年者らを相手方に引き渡すよう命じなければならない緊急の必要性を認めるに足りる疎明はない」として，原審判を取り消し，申立てを却下した。

(3)　裁判例の傾向について

従前の裁判例を振り返ると，東京高決平成15年１月20日家月55巻６号122頁は，「子の引渡しを求める審判前の保全処分の場合は，子の福祉が害されているため，早急にその状態を解消する必要があるときや，本案の審判を待っていては，仮に本案で子の引渡しを命じる審判がされてもその目的を達することができないような場合がこれ〔家事審判規則52条の２〕に当たり，具体的には，子に対する虐待，放任等が現になされている場合，子が相手方の監護が原因で発達遅滞や情緒不安を起こしている場合などが該当するものと解される。」として，保全の必要性を厳格に解する立場を取っており，その背景には数次にわたる強制執行等により子が父母間を行き来することを避けるための配慮があると考えられる。そして，東京高決平成20年12月18日家月61巻７号59頁は，母が父の下で監護されていた子につき，父に断りなく保育園から連れ去った事案に関するものであるが，「共同親権者である夫婦が別居中，その一方の下で事実上監護されていた未成年者を他方が一方的に連れ去った場合において，従前未成年者を監護していた親権者が速やかに未成年者の仮の引渡しを求める審判前の保全処分を申し立てたときは，

From:03 3515 7308　2026/09/18 17:12　#178 P.178/180

従前監護していた親権者による監護の下に戻すと未成年者の健康が著しく損なわれたり，必要な養育監護が施されなかったりするなど，未成年者の福祉に反し，親権行使の態様として容認することができない状態となることが見込まれる特段の事情がない限り，その申立てを認め，しかる後に監護者の指定等の本案の審判において，いずれの親が未成年者を監護することがその福祉にかなうかを判断することとするのが相当である。」と判示して，保全の必要性が認められ得る場合として，違法な子の連れ去りがあった場合を付加している。前掲【32】はこれらの考慮要素を総合したものと理解することができるだろう。もっとも，これらの事情は，保全の必要性が認められる典型的な場合を列挙したものであって，これらの事情が認められなければ保全の必要性が認められないという関係にあるわけではないと考えられる。特に，幼少の子が主たる監護者から引き離される状況が継続することの影響については，行動科学の知見も踏まえて慎重に検討する必要があると思われ（前掲【10】参照），一審と抗告審との判断が分かれた事例は，その点についての評価が分かれた事案と見ることができるようにも思われる。

7　親権者から第三者に対する子の引渡しを求めた事案

(1)　裁判例の概観

【38】大津家彦根支審平成29年９月15日審判判タ1451号125頁・家判16号85頁は，離婚後の単独親権者である母が，その母（母方祖母）に対し子の引渡しを求めた事案である。裁判所は，母は，離婚後実家に身を寄せて母方祖母と同居していたが，その後実家を出て現在の夫の実家で暮らし始め，以後，子の監護養育は母方祖母が行っていたという経緯を認定し，本件を家事審判事件として扱うのが相当であるとした上，母は親権者として子の引渡しを求めることができるのが原則であり，母が親権者としておよそ適格を欠くといった事情も見当たらないとして，申立てを認容した。抗告審である【39】大阪高決平成29年11月29日判タ1451号123頁・家判16号82頁も，「本件は，親権者が第三者に対して子の引渡しを求めるものであるが，家庭裁判所において，第三者であっても監護受託者等については子の監護者に指定し得るとされている以上，民法766条１項所定の子の監護に関する事項に準じて家事審判の対象（家事事件手続法別表第２の３項）となると解するのが相当である」との一般論を示して，原審判を是認し，抗告を棄却した。

【40】静岡地浜松支判平成27年12月２日判時2292号79頁は，イタリアに居住していた母が，がん治療のため，父の同意の上で子を連れて日本に帰国したが，その後母が死亡したため，父が，子を事実上監護している母方祖母に対し，親権及び監護権に基づき子の引渡しを求めた事案である。本件は，地裁に民事訴訟として提起されたものであるところ，裁判所は，父は親権及び監護権に基づき，子を事実上監護する者に対し，その引渡しを求めることができるとして，請求を認容した。控訴審である【41】東京高判平成28年８月30日D1-Law.com判例体系判例ID28243359も，原審を是認した上，父による親権の濫用に関する母方祖母の主張を排斥して，控訴を棄却した。

(2)　裁判例の傾向について

親権者が子の祖父母等の第三者に対して子の引渡しを求める場合，当該第三者が民法766条による当事者間の協議や家庭裁判所の調停等により監護者として定められているのであれば家事審判事項となり得るが，そうでない場合には，親権に対する妨害排除の手段として民事訴訟手続による子の引渡請求によることになるとする見解が有力であるとされる。[15] 前掲【38】は，母と母方祖母との間で，母方祖母を監護者とする旨の合意があったことを前提に，母による子の引渡請求を家事審判事項と認めたものとも思われるが，前掲【39】は，一般的に親権者の第三者に対する子の引渡請求を家事審判事項と認めたようにも思われる。

他方，東京高決平成20年１月30日家月60巻８号59頁は，親権者の第三者に対する子の引渡請求は家事審判事項には当たらないとしており，前掲【40】，【41】はこの判断を前提に地裁に訴えが提起されたもののようにも思われる。

いずれにしても，裁判例によれば，親権者の第三者に対する引渡請求は，親権者がその適格性を欠くような事情がない限り認容されているといえ，父母間の子の監護者指定・引渡しの事件とは異なり，当事者双方の監護態勢，監護意欲等を比較衡量するという判断手法はとられていないものと考えられる。

8　裁判例のまとめ

(1)　裁判例の傾向のまとめ

ここまで，子の監護者指定・引渡しをめぐる最近の裁判例を紹介してきたが，改めて裁判例の傾向をまとめると，次のとおりである。

すなわち，裁判例は，子の出生以来の主たる監護者が父母のいずれであったかを重視しており，主たる監護者による監護態勢に問題がなければその者による監護を継続することが子の福祉に適うものとして，主たる監護者が監護者として指定され，主たる監護者による子の引渡しの申立てが認められる傾向にある。逆に主たる監護者でない方の親が監護者として指定された事案は，子の利益の観点から当該親を監護者とすべき事情があった場合であるといえる。

従前，子の利益の考慮要素として母親優先ということが言われ，[16] そのような考え方については性別役割分担に基づくものであるとの批判があったところである。この点については，実質に着目して，「母性」優先の原則ということが言われてきたが，[17] 近時の裁判例においては，母親優先という原則はもとより，母性優先の原則についても触れるものはあまり見受けられない。もっとも，両親と子との情緒的な結びつきや親密な関係は，父母のいずれかにかかわらず子の健全な成長にとって重要であると考えられ，これらは愛着理論ないしアタッチメント理論として精緻化が試みられてきているように思われる。[18] そして，この愛着関係は，主たる監護者とされている親と子との関係性を評価するに当たって，家庭裁判所における判断の上でも重要視されているのではないかと思われる。例えば，前掲【３】，【９】，【10】，【11】では，主たる監護者が認定された上で，その主たる監護者と子との間の愛着関係ないし精神的・情緒的結びつきが指摘されている。

このように見てくると，裁判例が，子の主たる監護者がいずれであったかを重視しているといっても，監護者の判断は，単に父母が子と過ごしてきた時間を数量的に評価して行われるものではなく，主たる監護者と認められる親が子のニーズに応え，その親と子との愛着関係が十分に形成されているかという観点から，家庭裁判所調査官による調査等も踏まえて分析・評価がされているものと考えられる。

この点，前掲【16】は，（数量的に見ると）母が主たる監護者であったといい得るものの，愛着関係という点では父母間に圧倒的な差はないという評価の下で，他の考慮要素も含めて検討し，結論として父を監護者として定めたものであり，これまで述べてきたところに沿う判断ということができるように思われる。

(2)　「継続性の原則」について

ところで，前記第２でも触れたとおり，従前は，「継続性の原則」が子の利益についての重要な考慮要素であると言われることが多かった。前掲梶村ほか論文が明示的に「子の現状を尊重する（継続性）」としているのが代表的であるが，[19] その後も，前掲中山論文は，子の引渡しの判断基準として「継続性の原則」を掲げており，[20] 前掲松本論文も，「現状の監護の継続性」を考慮要素の一つとして掲げ，「生活環境の変化が子の生活や精神の安定に影響を与えることは否定できないから，子の年齢や子が置かれている環境，その変化による子への影響の度合い等を具体的に検討する必要がある。」としている。[21]

もっとも，前掲松本論文において紹介されている高裁の裁判例は，いずれも現状の監護の継続性を理由として子の引渡しの申立てを却下したものではない。

また，前記１から７までで紹介した裁判例の中でも「継続性の原則」を重視する例はあまり見当たらない。前掲【12】は，現状の監護を継

From:03 3515 7308　2026/09/18 17:13　#178 P.179/180

続することが子の福祉に資するとして，監護者指定の申立てを却下したが，抗告審である前掲【13】は，子の主たる監護者による監護を重視して原審判を取り消し，差し戻している。むしろ，前掲【4】は，現状の監護は不適切な態様により開始されたものである上，その監護期間はほとんどが調停や審判に要した期間であることから，現状の監護状況の継続を重視すべきではないとしている。

以上のような状況を踏まえ，「継続性の原則」について，これまでの議論の状況を簡単に振り返っておくこととしたい。

旧来の家庭裁判所の実務においては，子の利益の考慮要素として，双方の親の①経済力，②居住条件・居住環境，③心身の健康・性格，④子に対する愛情・熱意，⑤養育能力，⑥監護補助者その他のサポートシステムの有無，⑦監護の継続性といった項目が提唱されていたが，実務的な観点から考慮要素の重点化が進み，「『子の生活の継続的状況を最重要視して，子の利益を害する虞れのない限りは，子の現状を尊重する』とする審判がかなり出てきた」といわれていた。[22]

そのような中，昭和48年５月10日から６月４日まで，家庭裁判所調査官研修所（当時）において，米国イェール大学のゴールドシュタイン教授を招聘したセミナーが開催された。[23] ゴールドシュタイン教授による講義は，要約すると，国家が家族の生活に介入するのはプライバシーの侵害であり，また長期の将来予測は困難であることなどからすると，監護権の濫用等の事情がない限り，現実に監護している親が適当であると推定すべきであって，現実に監護している親の監護の継続性を断ち切ることは子の最善の利益に反するというものであり，家庭裁判所関係者には，「『子の現状尊重』の実務的基準の理論化として受けとめられ」たようである。[24]

以上のような家庭裁判所の実務に対しては，家裁実務における「継続性」は現状肯定がその内容であって，心理学的親子関係が中心的意味内容である「継続性」とは別個のものであり，このような継続性を判断基準とすることは「子の利益」の観点からは疑問が多いとの批判があった。[25] また，このような現状尊重の実務的基準は，子の奪い合いの結果を追認するものとして多くの批判があったところである。ただし，その後も，家庭裁判所実務においては，現監護者による監護開始の態様が違法な場合であっても，現監護者との間に心理学的な親子関係が作り上げられた場合については，その心理学的親子関係の継続性を尊重するとの意見が強かったようである。[26]

もっとも，以上のような批判も踏まえて，「継続性の原則」は，単に現状を追認するものではないとし，より分析的に，「継続性の原則」について，出生時からの監護者との情緒的結びつきを重視する「監護者との継続性」と「監護環境の継続性」とに区別し，特に乳幼児期の子については，「監護者との継続性」を重視し，奪取時を始点とするのではなく，子の出生時からの生育歴を全体的に見て判断すべきものであるとの見解が唱えられるようになっていった。[27]

このような整理を踏まえて，この「監護者との継続性」という意味における継続性が，「主たる監護者」による監護を重視するものとして，[28] 子の出生以来，主たる監護者として子を継続的かつ適切に監護してきたのがいずれであったかを重視する今日の見解[29] に至っていると考えられる。そして，従来の「継続性」の概念（「監護環境の継続性」）は，今日では，前記の「生活環境の継続性」を意味するものと捉えられていると考えられ，子が年長である場合等に，主たる監護者との精神的なつながりよりも子自身の交友関係などを継続することが子の成長にとって好ましい場合等に重視されるものとして位置づけられているといえる。[30]

そして，このような意味での「継続性の原則」（生活環境の継続性）を重視する裁判例があまり見当たらないことは，前記のとおりであり，結局のところ，今日では，「継続性の原則」はかなり整理され，限定的に考えられているということができると思われる。

第4　おわりに

ここまで，子の監護者の指定・引渡しをめぐる最近の裁判例を紹介し，「子の利益」についての考慮要素について振り返ってきた。もっとも，各考慮要素については，心理学や社会学等の行動科学の知見を踏まえてより精緻な分析が必要であると考えられるし，考慮要素の総合考慮の在り方についても，行動科学の知見や，紛争の類型（父母の婚姻中の紛争か，離婚後の紛争か，あるいは第三者との間の紛争かなど）等も踏まえて更なる分析が必要であると思われる。こうした点につき，今後，議論・研究が深まることを期待したい。

注

1）飛澤知行編著『一問一答 平成23年民法等改正—児童虐待防止に向けた親権制度の見直し』（商事法務，2011）10頁。
2）数値はいずれも司法統計による。平成31・令和元年の数値は速報値である（以下も同じ。）。
3）槇村太市ほか「子の引渡し保全処分事件の処理をめぐる諸問題」家月47巻７号47頁（1995）。
4）この点については，後記第３の３(2)において改めて触れる。
5）中山直子「子の引渡しの判断基準」判タ1100号182頁（2002）。
6）松本哲泓「子の引渡し・監護者指定に関する最近の裁判例の傾向について」家月63巻９号１頁（2011）。
7）前掲・松本（注６）５頁。
8）前掲・松本（注６）52頁。
9）石垣智子・重高啓「第７回　子の監護者指定・引渡調停・審判事件の審理」東京家事事件研究会編『家事事件・人事訴訟事件の実務～家事事件手続法の趣旨を踏まえて～』（法曹会，2015）228頁。
10）前掲・石垣ほか（注９）238頁。
11）金子修編著『逐条解説 家事事件手続法』（商事法務，2013）225頁。
12）前掲・松本（注６）52頁。
13）前掲・石垣ほか（注９）238頁。
14）前掲・石垣ほか（注９）250頁。
15）前掲・石垣ほか（注９）231頁，阿部徹・島津一郎編『新版注釈民法(22)』（有斐閣，2008）130頁以下〔槇村太市〕，中山直子「第三者に対する子の引渡請求」判タ1100号180頁（2002）。
16）前掲・槇村ほか（注３）47頁。
17）前掲・中山（注５）182頁。
18）愛着理論については，例えば，遠藤利彦「アタッチメント理論における基点と現代的展開」こころの科学198号10頁（2018）。
19）前掲・槇村ほか（注３）47頁。
20）前掲・中山（注５）182頁。
21）前掲・松本（注６）17頁。
22）前沢智恵子「子の奪い合いと家庭裁判所調査官の役割」岡垣學・野田愛子監『講座・実務家事審判法２』（日本評論社，1988）207頁。
23）家庭裁判所調査官研修所「ゴールドシュタイン・セミナー結果報告（その１）」調研紀要25号１頁（1974）。
24）前掲・前沢（注22）208頁。
25）小川栄治「子の引渡に関する判例の法理—その２(3)完」金沢法学25巻１号（1982）。
26）「平成７年度家事事件担当裁判官協議会における協議結果の概要」家月48巻11号21頁（1996）。
27）前掲・中山（注５）182頁。
28）「主たる監護者」の概念については，五島京子「主たる養育者と監護者の決定」判タ628号135頁（1987）が「主たる養育親（primary caretaker parent）優先の推定則」を宣言した米国裁判例を紹介したことなどから広まっていったのではないかと思われる。
29）前掲・松本（注６）52頁，前掲・石垣ほか（注９）238頁。
30）前掲・松本（注６）17頁。

From:03 3515 7308　2026/09/18 17:14　#178 P.180/180